

1
GENARO R. CARRÍO

Profesor Titular Investigador Adscripto al Instituto de Investigaciones Jurídicas "Ambrosio L. Gioja". Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires.

2
**NOTAS
SOBRE DERECHO
Y LENGUAJE**

4
TERCERA EDICION AUMENTADA

página

**FUNDACION FERNANDO FUEYO LA
BIBLIOTECA**



ABELEDOPERROT

BUENOS AIRES

1986

© by ABELEDO-PERROT S. A. E. e I.
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Todos los derechos reservados
Lavalle 1280 - 1328, 1048 - Buenos Aires - Argentina

1ª Edición	1965
1ª Edición - 1ª Reimpresión	1967
1ª Edición - 2ª Reimpresión	1969
1ª Edición - 3ª Reimpresión	1971
1ª Edición - 4ª Reimpresión	1972
1ª Edición - 5ª Reimpresión	1975
1ª Edición - 6ª Reimpresión	1976
2ª Edición	1979
3ª Edición aumentada	1986

I.S.B.N. 950-20-0309-8

A MARTHA

"Sobre los límites del lenguaje normativo".

© Editorial Astrea.

"Sentencia arbitraria".

© Revista Jurídica de Buenos Aires.

"Los conceptos jurídicos fundamentales de W. N. Hohfeld".

© Centro Editor de América Latina.

El derecho de propiedad de esta obra comprende para su autor la facultad de disponer de ella, publicarla, traducirla, adaptarla o autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma, total o parcial, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información; por consiguiente nadie tiene facultad a ejercitar los derechos precitados sin permiso del autor y del editor, por escrito.

Los infractores serán reprimidos con las penas del artículo 172 y concordantes del Código Penal (arts. 2, 9, 10, 71, 72, ley 11.723).

IMPRESO EN ARGENTINA

PROLOGO A LA PRIMERA EDICION

Este es un trabajo de divulgación. Quien recorra sus páginas en busca de contribuciones originales se sentirá defraudado. Los temas que aquí se abordan son susceptibles, sin duda, de una elaboración mucho más profunda. Además, el criterio que apliqué, al elegirlos, excluyó cuestiones muy importantes que, en otras circunstancias, hubiera sido imperdonable omitir. A modo de justificación quiero decir dos palabras sobre el origen de estas notas.

En julio de 1963 tuve el honor de participar en los Cursos Internacionales de Temporada, organizados por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Dicté entonces tres clases sobre derecho y lenguaje. Aquí ofrezco al lector el texto completo de ellas; en otra parte se publicará, según entiendo, una versión resumida.

La índole del ciclo y su brevedad imponían limitaciones obvias. Pensé que lo más provechoso era circunscribir la exposición a aquellos tópicos en los que la relación entre ciertas características salientes del lenguaje natural o espontáneo, por un lado, y ciertos problemas que preocupan a los prácticos del derecho y a los juristas, por otro, fuese a la vez más directa y más evidente. Con esa idea, elegí dos temas centrales: el de la interpretación, vinculado a la práctica cotidiana del derecho, y el de las discrepancias que dividen a los juristas, ligado (negativamente) al avance de la teoría jurídica. Ellos ocupan la segunda y la tercera parte, respectivamente, de este volumen. La primera, de carácter general e introductorio, suministra las bases para los desarrollos que se hacen en las otras dos. He agregado un apéndice con referencias bibliográficas que estimo de interés.

Tal vez debí haber dicho algo sobre otras dos cuestiones, o familias de cuestiones, que revisten capital importancia dentro de una teoría jurídica que podríamos llamar de segundo nivel: 1) las que suscita el análisis de expresiones de gran generalidad,

tales como "acto ilícito", "derecho subjetivo", "deber jurídico", etc., que los juristas manejan a diario sin mayores dificultades; y 2) las que aparecen cuando procuramos elucidar las complejas relaciones que hay entre las normas de un ordenamiento y los múltiples y heterogéneos enunciados que, con base en ellas o acerca de ellas, formulan los juristas. No creí oportuno transitar por esas honduras en una exposición de carácter elemental, ni creo que hubiera podido decir nada útil en un tiempo tan breve.

Ha pasado más de un año desde que dicté aquellas clases; hoy advierto que cometí unos cuantos errores. No me ha parecido apropiado enmendarlos, pues eso fue lo que dije. Por añadidura, no estoy seguro de poder hacerlo satisfactoriamente.

Los argumentos que constituyen el primer capítulo de la Segunda Parte ("Lenguaje jurídico y lenguaje natural") no fueron expuestos en la versión oral. Los he incorporado a la presente a raíz de una oportuna y justificada observación de Gastón Dassen. En esa Segunda Parte el lector hallará reiteradas referencias críticas a la obra del profesor Sebastián Soler y, en especial, a su último libro La interpretación de la ley. Un factor circunstancial y una razón de fondo hicieron que me ocupara de aquel libro con especial énfasis. El factor circunstancial es que esa obra se conoció en Buenos Aires cuando estaba preparando las clases; ellas reflejan el impacto que me produjo su lectura. La razón de fondo es que, en nuestro medio, Soler es uno de los pocos juristas dogmáticos de primera línea que escribe con rigor sobre temas de teoría general del derecho.

Agradezco a la Revista Jurídica de Buenos Aires su autorización para reproducir mi artículo "Los jueces crean derecho" (Tercera Parte, III) publicado originariamente en ella (Vol. 1961-IV). Para concluir quiero expresar mi gratitud hacia Eugenio Bulygin, que me ayudó a preparar las clases y después las escuchó con resignada entereza, y hacia Roberto J. Vernengo, Eduardo A. Vázquez, Horacio J. Solari, Eduardo A. Rabossi, Carlos E. Alchourrón, Gastón Dassen y Ernesto Garzón Valdés, que leyeron parte de los originales sin horrorizarse o, por lo menos, sin dar muestras de ello. ¿Será necesario agregar, según es de estilo, que la mención de sus nombres no importa atribuirles participación alguna en mis errores?

G. R. C.

Buenos Aires, setiembre de 1964.

PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION

En los casi quince años transcurridos entre la primera edición de este libro y la presente, aparecieron varias reimpresiones de él. Me he decidido a publicar una segunda edición por dos razones.

La primera razón es ésta. La forma como el libro llegaba hasta ahora al lector adolecía de un manifiesto defecto, sólo imputable a mí: las notas y comentarios que complementan el texto principal estaban colocados al final del volumen, impresos en un tipo de letra muy pequeño. Dichas notas y comentarios son tan importantes como el texto. Esto no significa atribuir a éste o a aquéllos algún grado especial de importancia. Puede ser que tengan muy poca. En todo caso, la que tienen es la misma. Pues bien, estoy convencido de que como consecuencia de la ubicación y tipo de letra mencionados, la mayor parte de los lectores del libro jamás se asomaron a ese material complementario. Ahora he procurado evitar que tal cosa siga ocurriendo.

La segunda razón es la siguiente. En su libro Las palabras de la ley el Profesor Sebastián Soler formuló severas críticas a algunas de las ideas centrales expuestas por mí en Notas sobre derecho y lenguaje. Contesté a esas críticas en un pequeño volumen titulado. Algunas palabras sobre las palabras de la ley. Allí procuré aclarar algunos de los desarrollos censurados por Soler y moderar ciertos excesos que padecían deducirse de aseveraciones hechas en Notas sobre derecho y lenguaje. Dadas esas circunstancias, considero que las aclaraciones y morigeraciones incluidas en Algunas palabras..., así como el resto de la exposición allí hecha, deben publicarse junto con el texto originario de las Notas...

Tales son las únicas modificaciones introducidas en la segunda edición. He dejado prácticamente intactos los dos textos

que forman este volumen. Si hoy tuviera que escribir sobre los mismos temas lo haría, sin duda, de manera distinta. A pesar de ello no me he creído con derecho a enmendar ensayos que, cualesquiera sean sus aciertos o errores, integran un intercambio de ideas fructífero, que conserva interés.

Aquellos que deseen conocer los puntos de vista de Soler acerca de cuestiones importantes examinadas en Algunas palabras sobre las palabras de la ley los encontrarán en su artículo "El Juez y el súbdito", La Ley, t. 142, pág. 1094.

G. R. C.

Buenos Aires, mayo de 1979.

PROLOGO A LA TERCERA EDICION

El presente volumen recoge algunos de los trabajos que he ido publicando con el correr de los años. Pienso que pueden ser razonablemente incluidos bajo el título general que lleva el libro. Eso y la ventaja de presentar reunidos ensayos que, bien o mal, responden al mismo interés del autor me han determinado a publicar esta nueva edición.

Creo conveniente hacer aquí las precisiones que siguen.

a) El ensayo "Principios jurídicos y positivismo jurídico", aparecido inicialmente en 1970, reproduce una conferencia que pronuncié en diciembre de 1969 en el acto de clausura de los cursos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

Mi objetivo principal fue cuestionar una crítica al positivismo jurídico formulada por Ronald Dworkin. Según ella el positivismo jurídico —y muy especial H. L. A. Hart, uno de sus adalides contemporáneos— concibe el derecho con arreglo a un obsesivo "modelo de reglas" que no deja ver el papel central que en la práctica de aquél desempeñan los principios jurídicos. Estos son pautas o criterios muy distintos de las reglas. Para hacer justicia al papel de tales principios no queda otra alternativa que demoler el positivismo jurídico desde sus cimientos. Tal es la labor que Dworkin auspicia y que cree haber realizado, al menos en parte.

Mi ensayo arranca con la presentación de un modelo tomado de las reglas de un juego. No se me escapa que pese a la existencia de analogías estructuralmente reveladoras, existen importantes diferencias entre las normas jurídicas y las reglas de los juegos. Pero estoy persuadido de que esas diferencias, por grandes que sean, no afectan en nuestro caso la utilidad del modelo.

b) La primera parte de "Sobre los límites del lenguaje normativo" reproduce una conferencia que pronuncié en noviembre de 1972 en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF). A ella agregué luego las notas y comentarios de la segunda parte que complementan el texto principal. Ambas partes fueron publicadas más tarde en la forma de una monografía, (Editorial Astrea, 1973).

Mi intención al preparar el trabajo no fue, por cierto, mostrar con ningún grado de precisión los límites externos e inter-

nos del lenguaje normativo, sino sólo indicar dónde y cómo hay que mirar para comenzar a verlos. A tal fin me valgo de la noción de "sinsentido", usada con el alcance amplio que resulta del texto, para mostrar, con la ayuda de algunos ejemplos, de qué modos diversos se puede transgredir esos límites. La presencia de un sinsentido funciona como una señal de alarma: nos avisa que hemos traspuesto, sin advertirlo, algunas de esas fronteras. De tal modo podemos ver por dónde se encuentra el deslinde que, al precio del absurdo, de la irrelevancia ridícula o de la emisión de series de palabras que no transmiten información alguna, hemos ignorado o desatendido.

El ejemplo del uso del concepto de "poder constituyente originario", allí examinado, configura un caso claro de violación de los límites extremos.

Frente al concebible cargo de que el examen de ese concepto usurpa un lugar demasiado grande en un ensayo demasiado breve, sólo puedo ofrecer una excusa y un atenuante. La Primera es ésta: el uso de dicho concepto en el campo de la teoría constitucional muestra una transgresión documentada y pública, por decirlo así, de los límites del lenguaje normativo, en un área donde muchos no se sentirían naturalmente inclinados a esperar desafueros lingüísticos. Por eso me pareció un ejemplo muy accesible y dotado de gran interés. El atenuante es que soy abogado.

c) El breve ensayo "Sentencia arbitraria" fue inicialmente publicado en la Revista Jurídica de Buenos Aires, 1965, tomos I, II.

Ese artículo anticipa en algo el contenido de mi libro: Recurso extraordinario por sentencia arbitraria cuya primera edición apareció en 1967.

d) Por último la contribución "Los conceptos jurídicos fundamentales de W. N. Hohfeld" vio la luz hace ya más de quince años, sin título y como nota preliminar de mi traducción del opúsculo de Hohfeld (Centro Editor de América Latina, 1968).

Agradezco a la Editorial Astrea, a la Revista Jurídica de Buenos Aires y al Centro Editor de América Latina su autorización para incluir en este volumen los ensayos mencionados precedentemente.

G. R. C.

Buenos Aires, julio de 1985.

I

LENGUAJE, INTERPRETACION Y DESACUERDOS EN EL TERRENO DEL DERECHO

PRIMERA PARTE

SOBRE LOS LENGUAJES NATURALES

En esta primera parte recordaré cosas elementales, destinadas a facilitar la comprensión de los temas que abordaré en las otras dos. Examinaré aquí algunas características salientes de los lenguajes naturales (el castellano, el inglés, el francés) que son conocidas por todos, pero también frecuentemente desatendidas u olvidadas. Como resultado de tal negligencia se multiplican los obstáculos ficticios, tanto en el campo de la teoría jurídica como en el de la práctica del derecho.

I. UNA SITUACIÓN SIMPLE Y DOS PREGUNTAS

El lenguaje es la más rica y compleja herramienta de comunicación entre los hombres. No siempre, empero, esa herramienta funciona bien. Una comunicación lingüística puede resultar frustrada: el destinatario de ella puede sentirse perplejo ante el alcance de las expresiones que ha escuchado o leído.

Vale la pena distinguir dos fuentes principales de posible frustración. Me limitaré, claro está, a las fuentes interesantes. Excluiré, por ello, los casos de errores de percepción, así como los de confusiones originadas en un conocimiento deficiente del idioma.

Imaginemos una situación simple. Estoy frente a un amigo; tras un silencio éste dice algunas palabras, que oigo bien. Mi aparato auditivo es normal y la acústica excelente. La comuni-

cación ha sido hecha en un idioma que conozco a la perfección. No obstante ello me siento perplejo o desconcertado. No sé qué es lo que mi amigo ha querido transmitirme.

Quizá se pueden resumir en dos preguntas distintas, aunque relacionadas, las dos principales fuentes de posible perplejidad. La primera pregunta puede ser formulada de una de estas dos maneras equivalentes: ¿Cómo *debo* tomar la expresión de mi amigo? o ¿cuál es su *fuerza*? La segunda pregunta es esta otra: ¿Qué *quiere decir* lo que mi amigo dijo?

a) La primera pregunta refleja perplejidad o desconcierto acerca de la "naturaleza", por decir así, del *acto* verbal que mi amigo acaba de protagonizar, ¿Cómo debo tomar sus palabras? ¿Cómo una orden, un consejo, una advertencia, una amenaza, una súplica, un pedido, una instrucción, una exigencia, una aserción, una pregunta, una expresión de deseos, una sugerencia, un saludo, una invitación, un elogio, una broma, una justificación, una excusa, una recomendación, una censura, una atribución de responsabilidad, una oferta, una aceptación, una admisión de responsabilidad, un juramento, una promesa, una maldición, una predicción, un veredicto, una conjetura, una autorización, una prohibición, un insulto, un mero acto de cortesía, etc.?

No sé si la lista de tipos de actos que se pueden *hacer* con palabras es infinita, pero sí que es enormemente más larga que esta tediosa enumeración. Cuando me pregunto cómo debo tomar la expresión de mi amigo, o cuál es su fuerza, me estoy preguntando qué cosa, de las tantas que se pueden hacer con palabras, acaba de hacer mi interlocutor al decir lo que dijo, en las circunstancias y en la forma en que lo dijo.

b) La segunda pregunta es distinta de la anterior. No sé el caso ahora de que no sé cómo tomar lo que me han dicho. Yo sé que es una pregunta o una sugerencia, pero no sé qué es lo que me han preguntado o sugerido. Ya sé que es un pedido o una prohibición, pero no sé bien qué es lo que me piden o prohíben.

Estas son las principales fuentes de perplejidad o, en todo caso, las que por las razones que más adelante se verán me interesan examinar aquí. Ambas formas de perplejidad pueden presentarse unidas, pero eso no impide que las distingamos en

análisis. Al hacerlo se abren ante nuestros ojos dos panoramas distintos de problemas, que conviene tratar por separado.

II. LA PRIMERA PREGUNTA: ¿QUÉ HIZO FULANO AL DECIR "X"?

1. SOBRE LOS USOS DEL LENGUAJE

Los problemas conectados con la primera pregunta son tratados, comúnmente, bajo el rótulo "los usos del lenguaje". Se trata de una problemática que en muchos aspectos no ha sido aún suficientemente explorada. La lista parcial de actos que se pueden hacer con palabras, que nos demoró hace un momento, muestra, incluso a los ojos del menos alerta, la prodigiosa riqueza y flexibilidad del lenguaje. Este es una herramienta que sirve para los fines más variados. Es un exceso de simplificación (o de dogmatismo) tratar todos esos usos o funciones del lenguaje como si todos tuvieran (o tuvieran que tener) las mismas características.

Nada más que para orientarnos en un territorio frondoso voy a recordar aquí una clasificación corriente, que procura parcelar el área cubierta por estos múltiples usos del lenguaje. No es una clasificación rígida; tampoco es muy satisfactoria. Está armada en torno a ciertos casos paradigmáticos y deja sin iluminar extensas zonas donde proliferan los casos dudosos. Con todo, aunque bastante tosca, es una brújula que ayuda a evitar los extravíos más comunes.

a) En ocasiones usamos el lenguaje con un propósito primordialmente descriptivo: para informar acerca de ciertos fenómenos o estados de cosas. Hay, pues, una función o uso *descriptivo* del lenguaje. Las unidades lingüísticas son aquí aserciones; de ellas —y sólo de ellas— tiene sentido pleno preguntarnos si son verdaderas o falsas. Este es *el test* del uso descriptivo de las palabras, cuyo paradigma es el lenguaje científico.

Claro está que no siempre nos valemos de las palabras para describir o informar; con suma frecuencia las usamos para hacer otras cosas.

b) Solemos valernos de ellas como vehículo o medio para expresar nuestros sentimientos, no en el sentido de describirlos sino de exteriorizarlos; de darles, por decir así, salida o escape. O bien las usamos para provocar en el prójimo ciertos sentimientos, solidarios o no con los nuestros; para despertar en él compasión, admiración, envidia, encono o ira; para justificarnos ante sus ojos; para modificar su actitud frente a algún suceso o persona; para infundir en él resignación u optimismo, etcétera.

En relación con estos casos se habla de una función o uso *expresivo* de las palabras. El paradigma es aquí el lenguaje poético. No tiene sentido preguntarnos si las expresiones que aparecen en una poesía son verdaderas o falsas, ni pretender juzgar el mérito de ella utilizando los cánones adecuados para juzgar una obra científica.

c) Otras veces nuestro propósito central al usar ciertas fórmulas verbales es *dirigir* el obrar de otras personas. Nos valemos del lenguaje para inducir a otro a *hacer* tal o cual cosa, a comportarse de determinada manera. Se habla, por ello, de una función o uso *directivo del lenguaje*. Una orden militar es, quizás, el ejemplo más claro de esta función de las palabras. No tiene sentido preguntarse si una orden es verdadera o falsa. Para destacar sus méritos o defectos no apelamos a esos calificativos. Tampoco tiene sentido afirmar que una ley penal, por ejemplo, es verdadera o falsa. Sí lo tiene, en cambio, decir que es justa o injusta, oportuna o inoportuna, progresista o retrógrada.

d) Se habla también de un uso "operativo" (*performative*) del lenguaje, que ofrece características muy especiales. Cuando al otorgar su testamento ológrafo el testador escribe: "Instituyo como heredero universal de mis bienes a X", está usando palabras de una manera no asimilable a los otros usos del lenguaje hasta aquí aludidos. Ese enunciado no es, obviamente, una descripción de lo que el testador está haciendo, ni de ninguna otra cosa. Si bien exterioriza un cierto estado de ánimo (el deseo de beneficiar a X), su función central no es esa, sino la de beneficiar a X (lo que no impide que, en los hechos, pueda resultar un intento frustrado de ello).

Al formular ese enunciado el testador está haciendo una cosa específica, que presupone la existencia de un sistema de

reglas vigentes: está instituyendo un heredero. Del mismo modo, cuando digo a otro "lo saludo cordialmente", o "le prometo que iré", estoy realizando con palabras actos que, según ciertas convenciones en vigor, constituyen un saludo o una promesa, cualquiera sea el grado de sinceridad que haya detrás de ellos. Para aludir a esta función de las palabras —que tanta importancia tiene en el campo del derecho— se puede hablar de un uso *operativo* del lenguaje.

Dejemos a un lado esta clasificación rudimentaria y recordemos la nutrida lista de actos de lenguaje que mencioné, a título de ejemplo, al tratar de precisar el alcance de las preguntas. ¿Cómo debo tomar una expresión lingüística? o ¿Cuál es su fuerza?

Dada la enorme variedad de actos de lenguaje, ¿qué guía tenemos para no equivocarnos al "interpretar" lo que hemos llamado la fuerza de una expresión? Lo cierto es que las más de las veces no erramos, pero no es insólito que ocurra lo contrario o, al menos, que nos sintamos inicialmente desconcertados a ese respecto.

La forma gramatical de la expresión no es, ciertamente, una guía segura. No siempre las órdenes, por ejemplo, se dan usando el modo imperativo. Si le digo a mi empleado "mañana llevará esta carta al correo", el contexto y la situación indican con claridad que se trata de una orden y no de una profecía, a pesar de que la frase está en futuro del indicativo y no en imperativo. Y hasta sería una insolencia, o signo de una alarmante estupidez, que al día siguiente el empleado me dijera: "Señor, se equivocó, no llevé su carta al correo". Es una deliberada confusión de ese tipo, precisamente, la que confiere un grato sabor de sorpresa a la frase "el juez le vaticinó, con toda verdad, diez años de cárcel".¹

Si generalmente no nos equivocamos es porque manejamos muy bien, aunque no sepamos hacer explícito, el complejo sistema de reglas implícito en el uso de las palabras. Tales reglas,

¹ Jorge Luis BORGES, *Historia Universal de la Infamia*, Emecé, Buenos Aires, 1962, pág. 62.

que relacionan ciertos giros y expresiones con situaciones sociales o interindividuales típicas, determinan con claridad, en la mayoría de los casos, qué clase de acto verbal es el que se ha efectuado.

2. SOBRE EL LLAMADO "SIGNIFICADO EMOTIVO" DE LAS PALABRAS

Una de las causas que hacen que la forma gramatical sea una guía segura es que existen numerosas palabras que, en margen o con independencia de lo que podríamos llamar su significado descriptivo, tienen la virtud, por decir así, de provocar sistemáticamente determinadas respuestas emotivas en la mayoría de los hombres.

Los ejemplos son, por cierto, abundantes. Las palabras que se usan con mayor frecuencia y brío en la oratoria política pertenecen a esa copiosa familia. Algunas de ellas tuvieron inicialmente, quizás, un significado claro, que con el correr del tiempo se fue haciendo cada vez más borroso. Otras han ido cambiando de significado descriptivo, sin cambiar su tonalidad, ennobiliándose o peyorativa, según el caso. Se trata de palabras que son usadas, en forma ostensible o encubierta, para exteriorizar, despertar o agudizar ciertas actitudes de aprobación o desaprobación. "Libertad", "democracia", "imperialismo", "oligarquía", "comunista", "nacionalista", son sólo un puñado de las numerosas palabras que, en determinados contextos, desempeñan tal función.

Entre esas palabras, que ordinariamente se manejan con tremenda imprecisión y que son utilizadas como dardos en las luchas ideológicas, se encuentran, por desdicha, el término "derecho" y buena parte de las expresiones derivadas de él o emparentadas con él. Esta es una de las causas que explican por qué el positivismo jurídico, que ha pretendido redefinir "derecho" en las palabras satélites en términos desprovistos de carga emotiva, ha suscitado tantas incomprendiones, cuando no reacciones airadas. Resulta difícil eliminar el halo emotivo de una palabra por vía de una redefinición de su contenido descriptivo. No basta

con anunciar que en adelante la palabra se usará con tal o cual sentido, y que en ese sentido ella carece de implicaciones emotivas. Estas no pueden suprimirse por decreto, máxime si se trata de términos incorporados desde tiempo inmemorial al lenguaje cotidiano.

Frente a esta dimensión del lenguaje se habla del "significado emotivo" de ciertas palabras, como cosa distinta del significado descriptivo de ellas. Aunque tal modo de hablar no puede aceptarse sin reservas —que no puedo desarrollar aquí—, no veo inconvenientes mayores en usar esa fórmula verbal, que hace referencia a ciertas características disposicionales de algunos términos o expresiones.

En algunos casos, frente al uso de ciertas palabras, resulta tarea poco menos que imposible señalar con qué estados de cosas se hallan conectadas. Si un desconocido nos dice que tal película es un "opio", o si una jovencita sostiene que un disco es "brutal" o "fabuloso", o si un filósofo afirma que una tesis es "plausible", es muy probable que no sepamos qué propiedades constituyen el criterio de aplicación de esas palabras. Solo sabremos que ellas exteriorizan aprobación o desaprobación, tal como podrían exteriorizarlas un aplauso, una silbatina o cualquier otro movimiento o gesto dotado de uno u otro valor convencional.

Claro está que con palabras como "democracia" o "derecho" no ocurre necesariamente lo mismo. Esas palabras pueden tener, según las ocasiones, un significado descriptivo aceptablemente claro. Pero no siempre es ese el caso. No lo es cuando tales términos aparecen en contextos pertrechados de alta carga emotiva; por ejemplo, en las campañas políticas. Todos los partidos reivindican para sí el uso del término "democracia"; todos pretenden ser voceros de la "verdadera" democracia. Aquí nos topamos con otro fenómeno lingüístico frente al cual hay que estar precavidos.

Supongamos que A dice que el "verdadero significado" de la expresión "enseñanza libre" es "régimen de enseñanza liberado de todo dogmatismo, incluso el religioso". Supongamos que B le contesta que el "verdadero significado" de dicha expresión no es ese sino "régimen de enseñanza que acuerda a los padres

el derecho de educar a sus hijos en la fe de sus mayores, si lo desean". A primera vista parecería que A y B se han limitado a definir de distinta manera "enseñanza libre" y que su desacuerdo, por lo tanto, es puramente verbal. Pero lo que uno y otro han hecho con esa expresión, que en el uso corriente tiene un significado nebuloso, o una imprecisa acumulación de ellos, adjudicarle significados descriptivos distintos, con el propósito de aprovechar su indudable valor emotivo para dirigir el comportamiento ajeno según cierto rumbo.

Cuando intentamos redefinir el significado de un término o expresión procurando mantener intacto su valor emotivo estamos dando lo que Stevenson ha llamado una *definición persuasiva*².

3. "SIGNIFICADO EMOTIVO" BAJO ROPAJE DESCRIPTIVO

Puede ocurrir que en un contexto aparentemente descriptivo esas palabras grávidas de carga emotiva nos jueguen una mala pasada. Es posible "describir" un mismo conjunto de hechos utilizando un lenguaje neutro o un lenguaje con distintas connotaciones emotivas.

Podemos decir, por ejemplo, "los abogados piden la actualización de su arancel de honorarios". O bien, "los avenegados pretenden ganar todavía más". O, por último, "los auxiliares de la justicia estiman que la compensación de sus servicios profesionales no está de acuerdo con la jerarquía de los mismos". Son tres maneras de "describir" un mismo hecho, a saber, que los abogados piden una mayor retribución. Mediante el empleo de ciertos giros, se capta de describir una determinada pretensión, la presenta como absurda o inaceptable, o bien como digna de ser acogida.

Una coalición política puede ser "descripta" como "un acuerdo inter-partidario que es índice de madurez cívica y de espíritu de conciliación" o como un "contubernio". El uso de esta última palabra revela una clara actitud denigratoria.

² Charles L. Stevenson, *Ethics and Language*, Yale University Press, 7ª edición, 1958, Cap. IX.

Estos ejemplos pueden parecer demasiado toscos y quizás lo sean. Pero el disfraz suele presentarse en formas mucho más sutiles y menos ostensibles. Ello ocurre cuando se usan palabras bivalentes; esto es, términos que en algunos contextos funcionan descriptivamente y en otros emotivamente. En tales casos es posible que pasemos por alto la duplicidad funcional y seamos inducidos a error por ella.

4. SOBRE LAS DISCREPANCIAS ENTRE LOS JURISTAS: REMISION

Pienso que en parte no desdeñable las disputas entre los juristas están contaminadas por falta de claridad acerca de *cómo deben tomarse* ciertos enunciados que típicamente aparecen en la teoría jurídica. Mientras no se ilumine este aspecto del problema quedará cerrada toda posibilidad de superar los múltiples desacuerdos que tales enunciados generan. Si no tenemos en claro cuál es el fondo o la raíz de las discrepancias, vale decir, por qué se discute, será estéril todo esfuerzo de argumentación racional y las disidencias persistirán, quizás agravadas. Obtener claridad acerca de esto no es, por cierto, condición suficiente para eliminar el desacuerdo, pero sí condición necesaria.

Frente a cualquier enunciado que aparece en un texto de teoría jurídica y que no nos satisface, antes de salir a buscar argumentos para refutarlo debemos hacernos una serie de preguntas. ¿Qué es esto? ¿Es una aserción, es decir, un enunciado que se propone describir un cierto estado de cosas? ¿O es una recomendación disfrazada bajo la forma de una aserción, esto es, un enunciado que disimuladamente trata de ensalzar cierto estado de cosas "describiéndolo" con lenguaje aprobatorio? ¿O es un anuncio o advertencia de que tal palabra será utilizada exclusivamente con determinado sentido? ¿O es una definición que simplemente recoge el uso central o típico de un vocablo? ¿O es una definición persuasiva, esto es, un recurso técnico que emplea el autor para obtener que el lector apruebe sus tesis, colocándolas bajo el manto protector de alguna palabra rica en carga emotiva y pobre en significado descriptivo? ¿O es otro tipo de aser-

ción o de definición, caracterizado por el uso de afirmaciones paradójicas que no tienen otro fin que el de subrayar algo importante que hasta ese entonces los teóricos habían desatendido?

Este tipo de investigación o examen previo es fundamental para los juristas, por lo común, prescinden de él y al abrigo de esa actitud negligente prosperan muchas polémicas claramente prescindibles.

En la tercera parte trataré de demostrar, con un ejemplo, la importancia que tiene ese tipo de análisis para clarificar muchas disputas entre juristas³. No pretendo que él proporciona una receta para solucionar o superar todas las discrepancias. Al menos permite ubicarlas en el plano adecuado y, en algunos casos, puede mostrar que la polémica, tal como está planteada, se limita a recorrer, en interminable vaivén, una vía muerta.

III. LA SEGUNDA PREGUNTA: ¿QUÉ QUIERE DECIR "X"?

Spongamos ahora que no tengo dudas acerca de la fuerza de una expresión: se cómo debo tomarla. Se trata, claramente, de un *encargo*; mi mujer me ha dicho: "Si vas al centro, comprame un Y", y la palabra "Y" alude aquí a cierto tipo de objetos. O se trata, claramente, de una *instrucción*; un amigo que está por salir de vacaciones me ha pedido que me quede al cuidado de su casa y, antes de partir, me dice: "Si ocurre W, haz Z", y aquí las palabras "W" y "Z" aluden, respectivamente, a un cierto tipo de evento y a cierto tipo de acción humana.

Los problemas que quiero presentar ahora no se vinculan, pues, con la fuerza de la expresión, sino con estos otros interrogantes, que expresan una distinta perplejidad o duda: "¿Es este objeto individual que tengo frente a mí un Y (lo que mi mujer me encargó que le comprara)". O bien, "¿Es este hecho concreto, que acaba de ocurrir, un W (el hecho ante el cual mi amigo me indicó que adoptara ciertas medidas)". O si no, "¿Es esta acción que tengo en mira una conducta Z (la que mi amigo me instruyó que siguiera si ocurría tal suceso)?"

³ Ver *infra*, pág. 90 y sigs.

Este es un tipo de perplejidad independiente de la anterior. Los problemas conectados con ella tienen singular relevancia en la práctica cotidiana del derecho. Se justifica, por lo tanto, que los examinemos en forma somera.

1. EL USO DE PALABRAS GENERALES

Una de las principales funciones de las palabras —aunque no la única— es hacer referencia a objetos, propiedades, fenómenos, estados de ánimo, actividades, etc. Como nuestro equipo lingüístico no es lo suficientemente rico, ni habría ventaja alguna en que lo fuera tanto, no disponemos de una palabra para cada objeto individual, para cada hecho concreto, para cada propiedad de cada objeto individual o hecho concreto, etcétera. Que yo sepa, sólo Ireneo Funes, filólogo y pensador de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, concibió seriamente y terminó por desechar, si bien por motivos estrictamente personales, un lenguaje de esas características. El nuestro está armado en base a palabras generales que sirven para aludir a grupos o familias de objetos, hechos o propiedades, y no en base a nombres propios de objetos, hechos o propiedades individuales.

Es aquí, en el uso de palabras generales, que son palabras clasificadoras, donde se halla la raíz de ciertas incertidumbres que pueden, y suelen, frustrar una comunicación lingüística.

A esta altura un crítico imaginario podría observar lo siguiente:

"Es cierto que usamos palabras generales que cubren grupos o familias de objetos (en sentido amplísimo). Pero, ¿qué dificultad genuina puede suscitar el uso de ellas? Los distintos objetos designados por una misma palabra no están agrupados en forma arbitraria o casual; siempre hay un criterio o regla tras el uso del término. Agrupamos distintos objetos y aludimos a ellos con una misma palabra porque ellos tienen ciertas propiedades en común. Y es la presencia de esas propiedades comunes lo que justifica el agrupamiento.

"Esas palabras cumplen una doble función: *denotan* el conjunto de objetos que exhiben las características o propiedades

por cuya virtud les aplicamos la misma palabra, y *connotan* esas propiedades. Podemos decir entonces que tales palabras tienen un significado denotativo o *extensión* (el conjunto de objetos a los cuales se aplica la palabra) y un significado connotativo o *intensión* (las propiedades por virtud de las cuales aplicamos a esos objetos una misma palabra). Por lo tanto, la pertenencia de un objeto al grupo de objetos denotados por una palabra queda determinada por el hecho de que el primero exhibe las propiedades connotadas por la segunda. El criterio para el uso correcto de ella, por ende, es la presencia, en un objeto determinado, de las propiedades en cuestión. Si en nuestro lenguaje una palabra se usa para connotar la reunión o suma de las propiedades A, B y C, entonces todos los objetos del universo quedan automáticamente clasificados en dos grupos distintos y complementarios: el de los objetos que tienen las propiedades A, B y C y el de los que no las poseen. A los objetos que tienen tales propiedades les será aplicable la palabra; a los otros, no. ¿Qué problemas pueden presentarse aquí? Por supuesto que cuando usamos las palabras podemos no ser conscientes de esto, pero nuestra tarea sencilla hacer explícitos esos criterios de aplicación. Es necesario, *definir* las palabras que usamos. Una vez que tenemos la correcta definición según el uso vigente, ¿qué problemas de clasificación puede haber?, ¿Cómo es posible que surjan perplejidades genuinas o reales desconciertos?

Hasta aquí nuestro crítico imaginario. Por desdicha, el cuadro diseñado por él es excesivamente idílico. Las cosas no son tan simples.

2. AMBIGÜEDAD

En primer lugar, las complica un fenómeno corriente y, a primera vista, trivial. No es cierto que todas las palabras son usadas en todos los contextos, para connotar las mismas propiedades. Si uno de mis hijos me pregunta "¿Qué quiere decir 'radio'?" no tengo más remedio que contestarle con otra pregunta: "¿En qué frase u oración?". Porque en algunas significará algo así como "aparato eléctrico que sirve para escuchar música y no

cias"; en otras, "metal descubierto por los esposos Curie"; en otras "la mitad del diámetro"; en otras, cosas tan poco precisas como las que indicamos al hablar del radio de acción de cierta influencia política, o del radio céntrico de la ciudad.

Este ejemplo simple nos muestra que el significado de las palabras está en función del contexto lingüístico en que aparecen y de la situación humana dentro de la que son usadas. Claro está que el contexto y la situación, en la generalidad de los casos, disipan toda posibilidad de confusión. Sobre todo cuando, como ocurre en el caso de "radio", el uso de una misma palabra con distintos significados es un puro accidente lingüístico.

Otras veces, en cambio, advertimos que una misma palabra tiene distintos criterios de aplicación, pero que, a diferencia de lo que ocurre en los casos de mera homonimia, esos criterios están unidos entre sí por conexiones más o menos complicadas. En algunos casos hay algo así como un significado originario central, y extensiones metafóricas o figurativas. Hablamos, por ejemplo, de una conferencia pesada, o de un escritor oscuro o de una personalidad opaca, y, obviamente, una conferencia no es pesada en el mismo sentido en que lo es una caja de hierro, ni un escritor es oscuro en el mismo sentido en que lo es una habitación interna (o un determinado designio humano), ni una personalidad es opaca en el mismo sentido en que lo es un cuerpo sólido.

Pero además de estos usos extensivos o metafóricos hay muchos otros casos, más complicados y más interesantes, de palabras que se aplican a una multitud de objetos que no presentan propiedades comunes connotadas por aquéllas y donde, a pesar de ello, tenemos la impresión firme de que el uso de una misma palabra no es un mero accidente.

Tomemos el ejemplo que trae Wittgenstein³. Hablamos de "juego" para aludir a la rayuela, al fútbol, a los juegos de palabras, al rugby, a los juegos malabares, al polo, a los solitarios, al ajedrez, a la escoba de quince, a la lotería, al pato, a la ruleta, a las rondas infantiles, al bridge y a la taba. ¿Qué tienen de común

³ *Philosophical Investigations*, Mac Millan Co., New York, 1953, apartado 66.

estas cosas? ¿Qué propiedad común justifica que se hable de "juego" para aludir a actividades tan disímiles? Se podrá decir, quizás, que en todos estos casos hay una cierta actividad humana guiada por un fin de diversión y entretenimiento. Pero ¿quién compra billetes de lotería para entretenerse? ¿Diremos entonces que la característica "esencial" es que se trata de actividades humanas guiadas por reglas, donde se gana o se pierde? Pero esto no parece convenir a buena parte de los juegos infantiles.

Por otro lado, ¿por qué en castellano —o, al menos, en la variante de él que hablamos los argentinos— llamamos "juego" al fútbol y al rugby y no llamamos "juego" al box y a la lucha grecorromana? ¿Por qué hablamos de jugadores de basket-ball y no de jugadores de esgrima? ¿En qué medida el fútbol y el rugby son más parecidos a la ruleta o al bridge que al box o a la lucha, para que hablemos de "juego" en el caso de los cuatro primeros y no apliquemos el término a los dos últimos? ¿Hay alguna regla o principio oculto tras este aparente desorden? Cuando alguien me da una orden en la que aparece la palabra "juego" ¿cómo debo entenderla? ¿Se han querido incluir todas las variadísimas actividades cubiertas por la palabra o sólo algunas? Y si es esto último, ¿cuál o cuáles de ellas?

También aquí el contexto y la situación eliminan por sí mismas toda duda razonable. Pero hay casos en los que el dilema concierne subsiste a pesar de nuestros esfuerzos por hacerlo desaparecer.

Los problemas de este tipo son analizados y estudiados bastante

⁴ He aquí un intento de respuesta (parcial) a estas últimas preguntas. No hablamos de "juego" para referirnos al box o a la lucha grecorromana porque si bien estas actividades se asemejan al fútbol o al rugby en muchos aspectos importantes, difieren de ellos en un punto capital. A saber, que tanto el box como la lucha grecorromana se parecen mucho a cosas que los hombres hacen a veces "en serio" —pelearse entre sí— lo que no ocurre con el fútbol o el rugby. El parecido con una actividad "natural" neutraliza las semejanzas que el box y la lucha tienen con el fútbol y el rugby (el propósito de competencia, la aceptación de reglas, etc.) y excluye la aplicación de la palabra juego en relación con los dos primeros deportes. Esto puede explicarse, tal vez, porque no llamamos juegos a deportes tales como la equitación, la esgrima, las carreras pedestres, la caza, la pesca, el automovilismo, etcétera.

el rótulo de "ambigüedad de los lenguajes naturales". Las dificultades prácticas pueden superarse si tomamos la precaución de precisar, en todos los casos de posible duda, el sentido con que hemos empleado tal o cual palabra o expresión.

3. VAGUEDAD

Hay otros casos en que la incertidumbre en la aplicación o interpretación de ciertos términos no brota de que no sabemos en qué sentido han sido usados, porque sobre eso no tenemos dudas.

Aquí ocurre lo siguiente. Me hallo frente a un caso o ejemplo concreto, cuyas características individuales he podido examinar en detalle, pero a pesar de todos mis empeños no sé si se trata de un ejemplo de la palabra general "X", esto es, de un caso de aplicación de ella. Mi duda no se origina en falta de información acerca del objeto; sé todo lo que necesito saber de él. Ella se origina en que no sé bien dónde termina el campo de aplicación de la palabra "X" y este caso parece hallarse en las proximidades de esos desdibujados linderos, cuya ubicación no puedo precisar. Más fundamental aún: tengo la impresión de que carece de sentido hablar aquí de límites precisos.

Tal fenómeno acaece, por ejemplo, cada vez que una palabra tiene como criterio relevante de aplicación la presencia de una característica o propiedad que en los hechos se da en la forma de un continuo, como la edad, o la altura, o el número de cabellos que un hombre puede tener, y pretendemos hacer cortes en ese continuo valiéndonos de palabras o expresiones tales como "joven", "adulto", "anciano", "hombre edad madura"; o "alto", "bajo", "retacón"; o "calvo", "hirsuto", etc.

Ya sabemos lo que quiere decir "joven" o "calvo". No se trata aquí de un problema de ambigüedad. El problema es este otro: carece de sentido preguntarse a qué precisa edad se deja de ser joven, o cuántos cabellos hay que tener para no ser calvo, o cuánto hay que medir para ser alto. Todo cuanto podemos decir es que hay casos centrales o típicos, frente a los cuales nadie vacilaría en aplicar la palabra, y casos claros de exclusión respecto

de los cuales nadie dudaría en no usarla. Pero en el medio hay una zona más o menos extendida de casos posibles frente a los cuales, cuando se presentan, no sabemos qué hacer.

El uso vigente de la palabra no nos suministra una guía segura, positiva o negativa, para clasificar los casos dudosos, porque ella es deliberadamente usada con imprecisión. Tales vocablos cumplen una función importantísima en los lenguajes naturales y también en el lenguaje del derecho. Hablamos corrientemente de plazo razonable, de error sustancial, de culpa o de injuria grave, de peligro inminente, de velocidad excesiva, etc.

Para aludir a este fenómeno se habla de la "vaguedad de los lenguajes naturales". No todas las palabras vagas lo son de la misma manera. Hay veces en que las vacilaciones que suscitan la aplicación de un rótulo general a un hecho o fenómeno concreto se originan en que los casos típicos están constituidos por un conjunto de características o propiedades que allí aparecen estructuradas o combinadas en una forma especial, y no resulta claro si el criterio implícito en el uso del término considera todas ellas, o sólo a algunas, condición necesaria y suficiente para su "correcta" aplicación. El problema irrumpe con la aparición de los casos marginales o atípicos, en los que faltan algunas propiedades, por lo común concomitantes, o está presente una adicional, de carácter insólito. ¿Habremos de seguir usando el mismo rótulo, a despecho de la anomalía presente en el caso atípico? ¿O esta disparidad tiene una relevancia tal que justifica la no aplicación del término clasificatorio general? Muchas veces el uso establecido carece de respuesta para esos interrogantes. No cabe duda de que un automóvil es un "vehículo", pero ¿podemos llamar "vehículo" a un ascensor? ¿Y a una escalera mecánica?

Tomemos, adaptándolo, un ejemplo de Max Black⁵: el uso de las palabras con que pretendemos distinguir entre diversas razas de caninas. Veamos cómo define el Diccionario de la Real Academia algunas de esas palabras:

⁵ "Definition, Presupposition and Assertion", en *Problems of Analysis*, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1954, Cap. II.

"Lebrel": "Variedad de perro que se distingue en tener el labio superior y las orejas caídas, el hocico recio, el lomo recto, el cuerpo largo y las piernas retiradas atrás".

"Mastín": "El (perro) grande fornido, de cabeza redonda, orejas pequeñas y caídas, ojos encendidos, boca rasgada, dientes fuertes, cuello corto y grueso, pecho ancho y robusto, manos y pies recios y nervudos, y el pelo largo, algo lanoso".

"Danés": "El (perro) que participa de los caracteres del lebel y del mastín".

Parece claro que con esta información es imposible salir por los campos a buscar lebreles, mastines o daneses. Aquellas palabras no son definibles con la misma técnica que emplea un pémetro para definir sus términos. Definir "triángulo" es proporcionar las condiciones necesarias y suficientes que sirven como criterio para la aplicación de esa palabra y que permiten acotar, en forma rígida y nítida, una clase de objetos.

No ocurre lo mismo en nuestro ejemplo canino. No hay aquí ninguna propiedad o conjunto de propiedades que sean condición necesaria y suficiente para el uso de "lebel", "mastín" o "danés". Para enseñar a alguien a usar estas palabras hay que mostrarle lebreles, mastines o daneses típicos y, después, ejemplares atípicos situados a distinto grado de proximidad de los casos centrales. Las palabras de nuestro ejemplo no acotan una clase de objetos, sino un *campo* de límites imprecisos, dentro del cual podemos, ciertamente, señalar casos claros. Pero además de los casos claros hay numerosísimos ejemplares que se asemejan en grado decreciente a aquéllos. Entre el área de los casos claros y la de los inequívocamente excluidos se extiende una imprecisa zona de fronteras, no susceptible de deslinde, como no sea por una decisión arbitraria. No se vaya a pensar, dice Black, que esta indefinición o indeterminación es un producto espurio de la promiscuidad perruna. Todas las palabras que se usan para hablar del mundo, para aludir a los fenómenos de la realidad, participan de las mismas características.

Respecto de todas ellas vale la siguiente metáfora esclarecedora. Hay un foco de intensidad luminosa donde se agrupan los ejemplos típicos, aquellos frente a los cuales no se duda que la palabra es aplicable. Hay una mediata zona de oscuridad cir-

cundante donde caen todos los casos en los que no se duda que el uso de un vocablo en la práctica cotidiana, siempre es no lo es. El tránsito de una zona a otra es gradual; entre la total luminosidad y la oscuridad total hay una zona de penumbra sin límites precisos. Paradójicamente ella no empieza ni termina en ninguna parte, y sin embargo existe. Las palabras que usamos diariamente para aludir al mundo en que vivimos y a los que nosotros mismos llevan consigo esa imprecisa aura de imprecisión.

Pero, se me dirá, ¿no hay en esto una exageración patente? No es cierto que todas las palabras exhiben tal indeterminación. Tomemos, por ejemplo, la palabra "hombre" (en el sentido de "ser humano"). En condiciones de observación normales —sin guiría la objeción— jamás dudamos si a algo que tenemos ante nuestros ojos le es o no aplicable ese término.

Quizás se pueda responder a esa objeción señalando las vacilaciones de los antropólogos respecto del modo de clasificar ciertos especímenes primitivos. O preguntando (y preguntándonos) si según el uso establecido la palabra "hombre" se aplica claramente a un cadáver, y, si la respuesta es afirmativa, preguntando (y preguntándonos) si el uso ha fijado también con precisión cuándo, esto es, en qué momento, los despojos mortales de un hombre quedan fuera del campo de aplicación de la palabra.

Pero hay otra respuesta mucho más reveladora, y menos macabra, que ésta. Es verdad que *de hecho* usamos muchas palabras sin que se susciten oportunidades de duda; tales palabras no son actualmente vagas. Pero también es verdad que *todas* las palabras que usamos para hablar del mundo que nos rodea, y que nosotros mismos, son, al menos, *potencialmente* vagas. Sus condiciones de aplicación no están determinadas en todas las direcciones posibles; siempre podemos imaginar casos, supuestos, circunstancias frente a los cuales el uso no dicta la aplicación ni la no aplicación del término.

Todos usamos, por ejemplo, la palabra "escribir"; no parece, a primera vista, que ella sea actualmente vaga. Pero si nos mostraran una máquina que transformase las palabras habladas en palabras escritas, sin intermediario humano, ¿cómo describiríamos la actividad de la persona que habla ante la máquina? ¿Diríamos o no que está "escribiendo"? Por consolidado que pa-

4. LA TEXTURA ABIERTA DEL LENGUAJE

Es corriente presuponer que los criterios que presiden el uso de las palabras que empleamos para hablar acerca de la realidad están totalmente determinados. Pero eso no es más que una ilusión.

Si se nos pide que hagamos explícito el criterio de aplicación de una palabra podemos indicar un cierto número de características, o propiedades definitorias, y creer que todas las otras propiedades posibles no incluidas entre aquellas están, por ello, excluidas como no relevantes. Esta creencia es equivocada. Sólo pueden reputarse excluidas como irrelevantes las propiedades o características posibles que *han sido consideradas*, pero no las que no lo han sido. Estas últimas no están excluidas; cuando se presenta un caso en el que aparece una o más de ellas es perfectamente legítimo que sintamos dudas que no pueden ser eliminadas por un proceso de pura deducción a partir del significado corriente de la palabra. El uso puede estar, a este respecto, totalmente "abierto". Es decir, no decidido o, en otros términos, dispuesto a admitir extensiones o restricciones.

Imaginemos que alguien me pregunta si hay un gato en la habitación de al lado. Abro la puerta y veo un animal cuya apariencia reúne todas las características que normalmente exhiben

⁶ Cf. su artículo "Verifiability", publicado en *Logic and Language* (primera serie), antología compilada por A. N. G. Flew, Blackwell, Oxford, 1951, pág. 119.

⁷ Cf. su artículo "Significado y sinonimia en los lenguajes naturales", en *Antología Semántica*, compilada por Mario Bunge, Nueva Visión, Buenos Aires, 1960, págs. 25/44.

los gatos. Contesto, por lo tanto, que sí. Mi interlocutor insiste: "¿Está usted seguro?" Abro nuevamente la puerta y examino al animal más de cerca. En ese momento el gato me mira y en un impecable castellano exclama: "¿Se dejará usted de amolar?" (palabras equivalentes), al par que empieza a crecer y en un instante alcanza dos metros de altura, para volver de inmediato a su tamaño y parquedad habituales. ¿Seguiré llamando "gato" a este curioso espécimen? ¿Y si nunca más, en el resto de sus días, vuelve a conducirse en forma tan poco oxtodoxa, o sólo lo hace en ocasiones rarísimas, comportándose, por lo demás, como el resto de los gatos? Cualquiera sea la resolución que tome, ella no estará controlada por los usos vigentes, sino que será una decisión adoptada frente al caso insólito.

Se dirá, expresa Waismann, que esas cosas no ocurren. Pero basta con que sean *posibles* para que se nos haga patente que palabras generales que usamos no están perfectamente definidas cualesquiera sean nuestras creencias sobre el particular. Cuando pensamos haberlas delimitado en todas las direcciones, el caso insólito nos muestra que en un aspecto no contemplado falta la determinación. No disponemos de un criterio que nos sirva para incluir o excluir *todos* los casos posibles, por la sencilla razón de que no podemos prever todos los casos posibles. No podemos agotar la descripción de un objeto material ni, por lo tanto, formular una lista completa de todas las propiedades en relación con las cuales pueden registrarse variantes o combinaciones de eventual relevancia. Estas aptitudes no forman parte del equipamiento de los seres humanos ni pueden adquirirse mediante algún adiestramiento especial. Es por ello que las palabras presentan una característica de vaguedad potencial o textura abierta; y es por ello, también, que tal característica constituye, por decir así, una enfermedad incurable de los lenguajes naturales.

Todas estas cosas tienen una enorme importancia para los problemas que los juristas analizan bajo el rótulo de "interpretación". Así lo veremos en la segunda parte (pág. 49 y siguientes).

NOTAS Y COMENTARIOS

Las notas y comentarios que siguen complementan la exposición precedente. Buena parte de ellos proporcionan fuentes bibliográficas, en muchos casos con transcripciones breves o resúmenes. Hay otras notas que procuran aclarar cosas que quedaron oscuras en el texto principal o hacer explícito el criterio seguido en el tratamiento de algunos temas. La indicación entre paréntesis que sigue al título de cada nota remite al lugar correspondiente en el texto principal. Esto es, al apartado y punto que se busca complementar.

Estas mismas observaciones se aplican a las notas y comentarios que se insertaron después de las partes segunda y tercera (págs. 73 a 89 y 115 a 128).

1. FUERZA VS. SIGNIFICADO DE UNA EXPRESION (APARTADO I)

La terminología es de J. L. Austin, *How to do Things with Words*, Oxford University Press, Oxford, 1962. Véase, por ejemplo, págs. 33, 73, 98, 99, 100 y la nota de págs. 114-5. En este último sitio Austin señala que "podemos estar de acuerdo sobre cuáles fueron las palabras que efectivamente se pronunciaron, o incluso cuáles fueron los sentidos en los que se las usó y las realidades a las que ellas hicieron referencia, y sin embargo podemos todavía discrepar acerca de si, en las circunstancias, esas palabras constituyeron una orden, o una amenaza o simplemente un consejo o una advertencia". Seguidamente hace notar que, del mismo modo, podemos estar en desacuerdo respecto del significado y la referencia de un acto de lenguaje, y no obstante ello concordar en que se trata, por ejemplo, de una orden (*op. cit.*, pág. 115).

Véase también el artículo del mismo Austin "Performatif-Constatif", que forma parte del simposio *La Philosophie Analytique*, publicado por Les Éditions de Minuit, 1962, págs. 271 y siguientes. Durante la discusión posterior, Austin expresó lo siguiente: "En dehors de ce que nous entendons par la 'signification' d'une phrase, et je sais tout ce que cette appellation peut avoir d'obscur, même quand nous la restreignons à l'usage banal qu'on en fait, nous avons toujours quelque chose que nous appelle-

rons, puisqu'il faut lui donner un nom, sa 'force'. Nous pourrions toujours attribuer un sens, même s'il s'agit d'un faisceau de significations et d'intentions extrêmement complexes, à une expression comme 'j'ai mal dormi cette nuit', sans avoir abordé pour autant la question qui se pose sur un tout autre plan: ¿est-ce un énoncé constatif? ¿Est-ce une plainte? ¿est-ce un avertissement? ¿est-ce une menace, etc...? Nous avons là comme une deuxième dimension. Nous pourrions là encore parler de *signification*, mais puisque nous nous sommes déjà servi de ce mot à l'étage inférieur, choisissons un mot différent, et efforçons nous d'élaborer une doctrine nouvelle, pour rendre compte de ce qu'on peut appeler la *force* de cette expression". . . . "En essayant d'expliquer le second, ou la force d'une expression. . . , nous nous efforçons de qualifier le genre d'acte du discours qu'elle manifeste". "Il y a là un problème tout à fait distinct de celui de la signification qui ne se situe pas sur le plan du contenu factuel des expressions, mais sur le plan des forces qui se manifestent quand nous parlons" (*op. cit.*, págs. 293-4).

2. ACTOS QUE SE PUEDEN HACER CON PALABRAS. EL LENGUAJE COMO HERRAMIENTA (APARTADOS I Y II, 1)

"Pero ¿cuántos géneros de frases hay? Digamos ¿aserción, pregunta y orden? Hay un *número infinito* de géneros: incontables tipos diferentes de lo que llamamos 'símbolos', 'palabras', 'frases'. Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez para siempre; nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, podemos decir, aparecen, y otros pierden vigencia y pasan al olvido". . . . "Aquí uso la expresión 'juego de lenguaje' para destacar el hecho de que el *hablar* un lenguaje constituye parte de una actividad o de una forma de vida".

"Examinad la multiplicidad de juegos de lenguaje en los ejemplos siguientes, y en otros:

- Dar órdenes y obedecerlas;
- Describir la apariencia de un objeto, o indicar sus propiedades;

- Construir un objeto a partir de una descripción (un dibujo);
- Dar cuenta de un hecho;
- Especular acerca de un hecho;
- Formar y poner a prueba una hipótesis;
- Presentar los resultados de un experimento en cuadros y diagramas;
- Inventar un cuento y leerlo;
- Representar una pieza teatral;
- Cantar estribillos jocosos;
- Resolver acertijos;
- Hacer una broma; contar un chiste;
- Resolver un problema de aritmética práctica;
- Traducir de un idioma a otro;
- Preguntar, agradecer, maldecir, saludar, orar.

Es interesante comparar la multiplicidad de las herramientas del lenguaje y de las maneras como son usadas, con lo que los lógicos (incluido el autor del *Tractatus Logicus Philosophicus*) han dicho acerca de la estructura del lenguaje". (Wittgenstein, *Philosophical Investigations*, The MacMillan Co., New York, 1953, parágrafo 23).

"Pensad en las herramientas contenidas en una caja de herramientas: hay un martillo, tenazas, un serrucho, un destornillador, una regla, cola, un recipiente para prepararla, clavos y tornillos. Las funciones de las palabras son tan diversas como las de estos objetos (Y en uno y otro caso hay semejanzas)" (Wittgenstein, *op. cit.*, parágrafo 11).

Véase también Karl Bühler, *Teoría del Lenguaje* (traducción de Julián Marías), Revista de Occidente, Madrid, 2ª edición, 1961. Este autor afirma que "se ha hallado algo así como un hilo de Ariadna, que saca de toda clase de confusiones comprendidas a medias, cuando se define el hablar como acción. . . . "Al pensamiento antiguo, que identificaba total o casi totalmente lenguaje y *logos*, se le escapó precisamente la fecundidad de este punto de vista. . . ." (*op. cit.*, pág. 78). Para Bühler "el lenguaje humano. . . pertenece a los 'instrumentos'". . . . "La lingüística encuentra así en el axioma de la naturaleza de signo

propia del lenguaje el modelo mental del *homo faber*, un fabricante y usuario de instrumentos". "... Aquello que se emplea con valor de signo en el tráfico intersubjetivo [se puede caracterizar] como un instrumento de orientación de la vida de la comunidad" (*op. cit.*, pág. 73).

3. DOGMATISMO FRENTE A LA INAGOTABLE MULTIPLICIDAD DE LAS FUNCIONES QUE CUMPLE EL LENGUAJE (APARTADO II, 1)

En el texto se alude a lo que Austin llamó "descriptive fallacy" o, mejor, "constative fallacy" (*How to do...*, pág. 55). Esto es, a la presuposición obstinada de que todas las expresiones con sentido —salvo las tautológicas— cumplen una sola función: la de describir o registrar estados de hecho. Sobre el particular véase J. O. Urmson, *Philosophical Analysis*, Oxford University Press, Oxford, 1958, págs. 196-9. Recuérdense las palabras finales del párrafo 23 de las *Philosophical Investigations*, traducido al español en la nota anterior. Ya Berkeley había anotado que la opinión aceptada que el lenguaje no tiene otra finalidad que la comunicación de las ideas ("Tratado...", Introducción, pero "la comunicación de las ideas señaladas por las palabras no es ni el principal ni el solo fin del lenguaje, como se supone comúnmente" (*op. cit.* Introducción, 20); ver, además, nota siguiente.

4. INTENTOS DE CLASIFICAR LOS USOS DEL LENGUAJE (APARTADO II, 1)

La clasificación que se bosqueja en el texto es la que propone Irving Copi, *Introducción a la Lógica* (traducción de Néstor Míguez), Eudeba, Buenos Aires, 1962, cap. II, "Los usos del lenguaje", págs. 34 y sigtes. Bühler sostiene que el signo lingüístico (complejo) cumple tres funciones distinguibles: 1) "símbolo en virtud de su ordenación a objetos y relaciones"; 2) "Síntoma (indicio), en virtud de su dependencia del emisor, de su interioridad expresa", y 3) "Señal en virtud de su apelación

del oyente, cuya conducta externa o interna dirige como otros signos de tráfico" (*op. cit.*, pág. 51-2). Sobre esta base dicho autor distingue tres funciones del lenguaje: *representación*, *expresión* y *apelación*. Bühler recurre a casos paradigmáticos para ilustrar su clasificación. Se refiere, así, a 1) "fenómenos verbales en los que resulta visible por vez primera que casi todo puede trazarse y prepararse sobre la sola función representativa de los signos lingüísticos" y dice que "esto es seguramente válido del modo más manifiesto para el lenguaje científico"; 2) señala que el rendimiento de la función expresiva como tal "... será, por supuesto, más rico en el lírico"; y 3) destaca que "para una función exacta de apelación está preparado todo, por ejemplo, en el lenguaje de mando" (pág. 55). (Los subrayados son míos). Véase también Charles Morris, *Signos, Lenguaje y Conducta* (traducción de José Rovira Armengol, al cuidado de Ansgar Klein), Losada, Buenos Aires, 1962, págs. 109 y 141 y siguientes.

Esto de reconocer la importancia de los múltiples usos o funciones del lenguaje —que parece tan de nuestros días— tiene precedentes ilustres en Hobbes (*Leviathan*, Parte I, cap. IV) y en Berkeley (*A Treatise concerning the Principles of Human Understanding*, Introducción, 19 y 20). Creo que se justifican algunas transcripciones:

—Hobbes distingue entre 1) un *uso general* del lenguaje, que "consiste en transponer nuestros discursos mentales en verbales", ya para hacer un "registro de las consecuencias de nuestros pensamientos", ya para significar unas personas a otras "lo que conciben o piensan de cada materia; y también lo que desean, temen o promueve en ellas otra pasión"; y b) *usos especiales*, entre los que menciona (1) "registrar lo que por meditación hallamos ser la causa de todas las cosas, presentes o pasadas, y lo que a juicio nuestro las cosas presentes o pasadas pueden producir, o efecto"; (2) "mostrar a otros el conocimiento que hemos adquirido, lo cual significa aconsejar y enseñar uno a otro"; (3) "dar a conocer a otros nuestras voluntades y propósitos, para que podamos prestarnos ayuda mutua"; (4) "complacernos y deleitarnos nosotros y los demás, jugando con nuestras palabras incontinentemente, para deleite nuestro" (Cito de la traducción castellana

de Manuel Sánchez Sarto, publicada por el Fondo de Cultura Económica, México 1940, págs. 23-4).

—Berkeley, a su vez, señala que si bien “es opinión ario; (2) magnificar o empequeñecer los hechos principales; (3) provocar el estado emotivo requerido en los oyentes; y (4) refrescar su memoria”... “(3) Luego, cuando los hechos y su importancia han sido entendidos con claridad, debemos excitar guaje...” “Hay otros fines, tales como hacer surgir ciertas las emociones de nuestros oyentes. Ellas son la piedad, la indignación, la ira, el odio, la envidia, la emulación, la belicosidad. disposición particular” (*op. cit.*, Introducción, 20). “El fin Ya he mencionado previamente las líneas de argumentación a ser comunicación de las ideas es, en muchos casos, puramente empleadas para estos fines” (*op. cit.*, Libro III, cap. 18, 1419b). sorio, y a veces enteramente omitido, cuando ellos [los fines] pueden ser obtenidos sin él, como sucede no raras veces en el uso familiar del lenguaje” (*op. y loc. cit.*). Y seguidamente agrega Berkeley: “Ruego al lector reflexione y observe si sucede a menudo, sea al oír o al leer un discurso, que las pasiones de temor, amor, odio, admiración, desprecio y otras semejantes surgen inmediatamente en su espíritu al percibir ciertas palabras, sin que se interponga una idea”... “Aun los nombres propios no siempre se dicen con el propósito de producir los efectos designan. Por ejemplo, cuando un escolástico me dice: ‘Ados por Glanville Williams en *The Law Quarterly Review*, vol. 61 toteles lo ha dicho’, lo único que entiendo es que él intenta y 62, bajo el título de “Language and the Law” (números de este disponerme a que acepte su opinión con la deferencia ro, abril, julio y octubre de 1945 y octubre de 1946); en especial sumisión que la costumbre ha asociado a ese nombre” (*op. y véase el* parágrafo 7, “The Emotive Function of Words”, en *cit.*) (Cito la traducción de Risieri Frondizi, *Tratado sobre* vol. 62, oct. 1946, págs. 387 y sigtes. Véase también Alf Ross, *principios del conocimiento humano*, Losada, Buenos Aires, 1945, págs. 29-30).

5. EL USO EXPRESIVO DE LAS PALABRAS (APARTADO II, 1)

Véase Aristóteles, *Retórica*, Libro I, 1355b, 26 y 1356b, Libro III, cap. 14, 1415a, cap. 15, 1416a; cap. 18, 1419b, 1961, págs. 220-239. En ese artículo se formula una oposición “La apelación al oyente tiende a obtener su buena voluntad, ajante entre las expresiones operativas, por un lado, y las desprovocar su resentimiento, o a veces a asegurar su atención scriptivas o “constative” por el otro. Más tarde Austin eliminó, al caso, o incluso a apartarla de él, porque asegurarla no es por engañosa, esa oposición (ver los dos trabajos citados en la pre una ventaja...” (*op. cit.*, Libro III, 1415a). “El Ephiota 1). En la nueva versión se reconoce a los verbos operati-

6. USO OPERATIVO (APARTADO II, 1)

Véase, por supuesto, J. L. Austin, “Performative Utterances”, en *Philosophical Papers*, Oxford University Press, Oxford, 1961, págs. 220-239. Véase igualmente la importante serie de artículos publicados por Glanville Williams en *The Law Quarterly Review*, vol. 61 y 62, bajo el título de “Language and the Law” (números de abril, julio y octubre de 1945 y octubre de 1946); en especial véase el parágrafo 7, “The Emotive Function of Words”, en *cit.* Véase también Alf Ross, *Sobre el Derecho y la Justicia*, Eudeba, Buenos Aires, 1963, capítulo XIV.

vos el papel de *hacer explícita* la fuerza del acto verbal de que se trata (ver nota 1). Ese acto verbal puede tener, pongo por caso, la fuerza de una aserción o de una descripción. Para el primer supuesto hay expresiones que incluyen un verbo operativo especial: "*Afirmo que p*", "*Yo le digo que q*" "*Sostengo que r*" etcétera. (No existe, en cambio, "*Describo que p*"). Estos ejemplos muestran que la dicotomía mencionada al comienzo es insatisfactoria. En *How to do...* Austin modificó su análisis para superar las limitaciones del enfoque originario.

7. IMPORTANCIA DEL USO OPERATIVO EN EL CAMPO JURIDICO (APARTADO II, 1, *IN FINE*)

Véase J. L. Austin, "*How to do...*", pág. 4 (n. 2), 7, 12, 22, 24, 31-2, 33, 35, 36, 42-43, 150, 153, 154, 156. También "*Performative Utterances*", en *Philosophical Papers*, pág. 22. Cf. además H. L. A. Hart, "*The ascription of responsibility and rights*", en Flew, *Logic and Language* (first series) Blackwell, Oxford, 1951, págs. 145-6. He aquí algunos ejemplos triviales de expresiones jurídicas que envuelven un uso operativo de las palabras: "Interpongo el recurso de apelación contra el auto de fs...", "Renuncio a mis derechos contra x"; "Acepto su oferta del 6 del corriente"; "Autorizo al portador, Sr. x, a hacer z"; "Solicito se me concedan los beneficios de la jubilación ordinaria"; "Me opongo a la repregunta"; "Por la presente me comprometo a pagar al Sr. x la suma de..."; etc. Sobre los enunciados operativos en el lenguaje jurídico véase Karl Olivecrona, "*Legal Language and Reality*", en *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*, Bobbs-Merrill Company Inc., 1962, págs. 151-9, en especial págs. 177 y sigtes. (Hay traducción castellana, aún inédita, de Ernesto Garzón Valdés). Olivecrona se empeña en atribuir a los enunciados operativos un innecesario "sentido mágico", cosa que no beneficia su análisis.

8. EL LLAMADO "SIGNIFICADO EMOTIVO" DE LAS PALABRAS (APARTADO II, 2)

En Hobbes, *Leviathan*, parte I, cap. IV, *in fine*, se lee lo siguiente:

Los nombres de las cosas que nos afectan, es decir lo que nos agrada y nos desagrada (porque la misma cosa no afecta a todos los hombres del mismo modo, ni a los mismos hombres en todo momento) son de significación *inconstante* en los discursos constantes de los hombres. Adviértase que los nombres se establecen para dar significado a nuestras concepciones, y que todos nuestros afectos no son sino concepciones; así cuando nosotros concebimos de modo diferente las distintas cosas, difícilmente podemos evitar llamarlas de modo distinto. Aunque la naturaleza de lo que concebimos sea la misma, la diversidad de nuestra recepción de ella, motivada por las diferentes constituciones del cuerpo y los prejuicios de opinión prestan a cada cosa el matiz de nuestras diferentes pasiones. Por consiguiente, al razonar un hombre debe ponderar las palabras; las cuales, *al lado de la significación que imaginamos por su naturaleza, tienen también un significado propio de la naturaleza, disposición e interés del que habla...* (Esta última bastardilla es mía). Y en la misma Parte Primera, cap. XI, agrega Hobbes: "De esa misma ignorancia se deduce que los hombres dan nombres distintos a una misma cosa, según las diferencias de sus propias pasiones. Así, quienes aprueban una opinión privada la llaman opinión; quienes están inconformes con ella, herejía, y sin embargo herejía no significa otra cosa sino opinión particular, sólo que tiene un mayor tinte de cólera" (Cito la traducción castellana de Manuel Sánchez Sarto mencionada *supra*, nota 4. Los dos pasajes transcritos aparecen en las págs. 30-31 y 83, respectivamente, de esa traducción).

Sobre el "significado emotivo" de los términos éticos, véase Stevenson, op. cit. en nota 5, especialmente cap. III y R. M. Hare, *The Language of Morals*, Oxford University Press, Oxford, 1952, especialmente Parte II, caps. 6 y 7.

9. "SIGNIFICADO EMOTIVO" BAJO ROPAJE DESCRIPTIVO (APARTADO II, 3)

Véase Glanville Williams, "Language and the Law" (V), en *The Law Quarterly Review*, vol. 62, oct. 1946, págs. 389-90.

En la Tercera Parte me ocupó específicamente de esa cuestión. En el Apartado II, 5, Controversias generadas por un desacuerdo en el valorativo encubierto y Apartado III, "Los jueces crean derecho". Para un análisis de los términos "bivalentes" que poseen tan un uso encubiertamente exhortativo, o de recomendación, censura, crítica, etc., de ciertos enunciados aparentemente descriptivos, véase Nowell-Smith, *Ethics*, Blackwell, Oxford, 1957: "Como señaló Hume, hay algunas palabras que describen la manera en que un hombre se comporta y a la vez tienen una fuerza laudatoria o peyorativa" (*op. cit.*, pág. 89). Seguidamente Nowell-Smith enuncia lo que llama "principio de Jano": "una palabra determinada no solo puede cumplir dos o más tareas al mismo tiempo, sino que a menudo, y salvo prueba en contrario o reserva expresa, se presume que está haciendo dos o más trabajos a la vez". En los análisis que hace a continuación hay numerosas muestras de la verdad de ese principio (ver, p. ej. cap. 8).

10. AMBIGÜEDAD SISTEMÁTICA EN LA FUERZA DE LOS ENUNCIADOS QUE FORMULAN LOS JURISTAS (APARTADO II, 4)

Véase Alf Ross, *op. cit.* en nota 5, págs. 45-49, donde se examina la dificultad que existe en "trazar una línea divisoria nítida entre los pronunciamientos que corresponden a la esfera de la política jurídica y a la de la política jurídica".

11. EL USO DE PALABRAS GENERALES (APARTADO III, 1)

Véase Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*, Libro III, capítulo III, 1, 2, 3 y 4; Hospers, *Introducción al Análisis filosófico*, Macchi, Buenos Aires, 1962, cap. 1, págs. 17 y 18.

De la empresa de Ireneo Funes (1868-1889), aludida en el texto, sólo se conserva la minuciosa crónica que el Dr. Seamus O'Connor trae en sus manuscritos, depositados, desde 1902, en la biblioteca del Trinity College (Dublin). Ni la extraordinaria empresa de Funes, ni los prolijos manuscritos de O'Connor,

despertado el interés de los filósofos. Tengo entendido que al menos un literato sudamericano se ha ocupado superficialmente de la primera, sin mencionar (supongo que por olvido) la existencia de los segundos.

12. DENOTACION Y CONNOTACION. EXTENSION E INTENSION (APARTADO III, 1)

Véase John Stuart Mill, *A System of Logic*, Libro I, cap. II, parágrafo 5; Copi, *op. cit.* págs. 107-111; Hospers, *op. cit.*, págs. 8-19, 25-26; Morris Cohen y Ernest Nagel, *An Introduction to Logic and Scientific Method*, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1934, págs. 30-33; L. Susan Stebbing, *A Modern Introduction to Logic*, Methuen & Co. Ltd., Londres, 7ª edic., 1950, págs. 27-32.

13. AMBIGÜEDAD (APARTADO III, 1)

Véase Aristóteles, *Tópica*, Libro I, capítulos 15 y 18; Libro I, cap. 3; Libro VI, capítulos 2 y 10; Libro VIII, cap. 3; *Metafísica*, Libro IV, cap. 2; Libro VII, cap. 4 y Libro XI, cap. 3; *Ética a Nicómaco*, Libro I, cap. VI; Hume, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, Secc. VII, parte I, 48; Locke, *op. cit.*, Libro III, cap. IX, 4-11. Cf. también Hospers, *op. cit.* págs. 22-25 y Copi, *op. cit.* págs. 93 y sigtes.

Sobre las distintas razones que justifican que diferentes clases de cosas sean llamadas de la misma manera, ver J. L. Austin, "The meaning of a word" en *Philosophical Papers* (ver *supra*, nota 6), págs. 23-43. Ver en especial págs. 37-42. Ver también Hart, *El Concepto de Derecho*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1963, págs. 18-19 y 296.

Sobre la noción de "parecido de familia" ver Wittgenstein, *Philosophical Investigations*, parágrafo 67 y siguientes.

14. VAGUEDAD (APARTADO III, 3)

Cf. Bertrand Russell, "Vaguedad", publicado en *Antología de Semántica*, compilada por Mario Bunge, Nueva Visión, Buenos

Aires, 1960, págs. 14-24; Locke, *op. cit.*, Libro III, capítulo 47, Libro IX, 13-17. Véase también Copi, *op. cit.*, págs. 9 sigtes.; Hospers, *op. cit.*, págs. 39 y sigtes.; Cohen y Nagel, *op. cit.*, págs. 117-8; Glanville Williams, "Language and the Law", *The Law Quarterly Review*, vol. 61, abril 1945, (págs. 181-190) y julio 1945 (págs. 293-302). Sobre la vaguedad de "hombr" véase Locke, *op. cit.*, Libro III, cap. VI, 27.

15. TEXTURA ABIERTA DEL LENGUAJE (APARTADO III, 4)

Además del trabajo de Waismann citado en el texto, véase Wittgenstein, *Philosophical Investigations*, parágrafo 80: "Yo voy 'Allí hay una silla', ¿Qué pasa si voy hacia ella, con el propósito de tomarla, y súbitamente desaparece de la vista? — que no era una silla, sino una especie de ilusión'. Pero en esos momentos la vemos de nuevo y podemos tocarla, etc. — 'Así, después de todo la silla estaba allí y su desaparición fue una especie de ilusión'. — Pero supongamos que después de un tiempo desaparece de nuevo, o da la impresión de que desaparece. ¿Ben o hacen obligatorias ciertas acciones humanas, y en cuanto habremos de decir ahora? ¿Tenemos reglas listas para tales casos, reglas que digan si podemos usar la palabra 'silla' de manera de incluir este tipo de cosa? ¿Pero es que echamos de menos esas reglas cuando usamos la palabra 'silla'? ¿Y habremos de ellas de decir que en realidad no atribuimos ningún significado a la palabra porque no estamos provistos de reglas para toda la variación posible de ella?"

Ver también Austin, "The meaning of a word", en *Philosophical Papers*, citado *supra* en nota 6. Ver especialmente págs. 35-37, donde el autor argumenta que el lenguaje ordinario está en crisis ante los casos extraordinarios, dado que no existen convenciones semánticas, explícitas o implícitas, que los incluyan.

El curioso espécimen de apariencia gatuna, que en la p. 34 del texto habla y muda de dimensiones, está emparentado con el que se echa una filípica en el citado artículo de Austin con el que exhibe pasmosa elasticidad en "Verifiability" Waismann.

SEGUNDA PARTE

SOBRE LA INTERPRETACION EN EL DERECHO

I. LENGUAJE JURÍDICO Y LENGUAJE NATURAL

1. TESIS

Espero que se me conceda sin necesidad de una elaborada demostración que las normas jurídicas, en cuanto autorizan, prohíben o hacen obligatorias ciertas acciones humanas, y en cuanto ministran a los súbditos y a las autoridades pautas de comportamiento, están compuestas por palabras que tienen las características propias de los lenguajes naturales o son definibles en términos de ellos.

Esa no es una circunstancia meramente accidental; tampoco debe ser vista como un defecto grave ni como una insuficiencia ineliminable de la técnica de control social que llamamos derecho. El uso eficaz de esta técnica reclama que las reglas jurídicas sean comprendidas por el mayor número posible de hombres. La función social del derecho se vería hoy seriamente comprometida si ellas estuvieran formuladas de manera tal que sólo un grupo muy pequeño de iniciados pudiese comprenderlas. Por ello es legítimo decir que las normas jurídicas no sólo se valen del lenguaje natural sino que, en cierto sentido, *tienen* que hacerlo.

2. UNA POSIBLE OBJECION

Frente a lo que acabo de decir se podría replicar que desde tiempos muy lejanos los juristas vienen elaborando un lenguaje

especializado, compuesto de términos que no forman parte del lenguaje natural, y que esas palabras técnicas, susceptibles de una definición precisa, se han incorporado a las leyes y demás normas jurídicas escritas.

Así —continuaría la objeción— cuando el Código Civil argentino usa términos o expresiones tales como “locación”, “compraventa”, “donación”, “culpa”, “derechos reales”, “mandato”, “nulidad de los actos jurídicos”, etc., está valiéndose de palabras o expresiones que tienen una altísima precisión. Esto es, de fórmulas verbales cuyos criterios de aplicación son de una nitidez equivalente a la que poseen los criterios de aplicación de palabras o expresiones tales como “cuadrado”, “pentágono”, “triángulo isósceles”, “tetraedro”, etc.

Esa convicción inspira algunos desarrollos hechos por bastián Soler en sus libros *Fe en el Derecho*¹ y *La interpretación de la ley*². En el primero se lee que “el comportamiento del derecho guarda relación con las matemáticas en los dos sentidos: por la forma en que se constituyen los conceptos jurídicos y por la manera en que recíprocamente los conceptos jurídicos integran las normas y por la manera en que recíprocamente las normas se han incorporado a las normas jurídicas, por lo menos en algunos sectores (p. ej., en el derecho civil). También es verdad que existe semejanza entre esta clase de conceptos y los conceptos matemáticos: la semejanza es profunda. Entre el concepto de hipoteca y el de triángulo isósceles existe la coincidencia de que ambos están constituidos por un número limitado de elementos puestos” (pág. 162)³.

En *La interpretación de la ley* Soler repite que “la relación que efectivamente guardan los conceptos jurídicos con los conceptos matemáticos, especialmente con las figuras de la geometría... consiste en que ambos son conceptos dados o puestos, hipótesis, integrados, además, por un número determinado de elementos necesarios” (pág. 42). A continuación da el siguiente ejemplo: “Si hay un acuerdo para transferir el dominio de una cosa mediante un precio, hay compraventa; si suprimimos el precio, hay donación; si en vez de la cosa suponemos un crédito, hay cesión; si no hay acuerdo sino engaño, hay estafa. De acuerdo con la primera definición no podemos tocar nada, según se ve, sin que la figura se desmorone, como cuando a un triángulo le quitamos un lado” (*op. y loc. cit.*).

Esta equiparación, en el mejor de los casos, es engañosa. Sugiere que las palabras y expresiones jurídicas tienen la misma precisión que las palabras que usa el geómetra para aludir a sus objetos construidos. Si fuera correcta, refutaría mi afirmación de que las normas se valen de un lenguaje que tiene básicamente las mismas características que los lenguajes naturales. Sostengo que no lo es y que la objeción que me ocupa no tiene sino una fuerza aparente. Veamos por qué.

3. CONTRARREPLICA

Es verdad que los juristas se han esforzado por crear un lenguaje en cierto modo artificial, de contornos más precisos, para alcanzar un mayor rigor expositivo. Esa terminología especial se ha incorporado a las normas jurídicas, por lo menos en algunos sectores (p. ej., en el derecho civil). También es verdad que algunas palabras tales como “capacidad”, “menor”, “heredero”, “domicilio”, en boca de un jurista y en un contexto jurídico, tienen por lo general mayor precisión que en boca de un lego y en un contexto de lenguaje cotidiano. Es innegable que “donar”, como palabra jurídica, tiene contornos más definidos que la palabra coloquial “regalar”; que “pagar”, en el lenguaje de los juristas, significa lo mismo que “pagar” en el habla del hombre de la calle; que “constituto posesorio” no significa absolutamente nada en este último, etcétera.

Podemos conceder todo eso sin dificultad y seguir sosteniendo con firmeza que existen diferencias fundamentales entre el lenguaje de los juristas y un lenguaje formalizado. El primero no es sino una forma menos espontánea y menos imprecisa de lenguaje natural, que muchos juristas usan con la pretensión, consciente o no, de estar usando un lenguaje absolutamente riguroso.

No puedo desarrollar aquí este tema con la extensión que merece. Me limitaré a señalar algunas pocas cosas.

¹ *Fe en el Derecho y otros ensayos* (T.E.A., Buenos Aires, 1955).

² *La interpretación de la ley*, Ed. Ariel, Barcelona, 1962.

³ Ver también, *op. cit.*, págs. 165/68, 259/60, 269 y 281/85.

No hace falta mucha agudeza para advertir que, en nuestro sistema, no podemos saber si a un ser humano le es o no aplicable el rótulo jurídico "incapaz" (o "capaz") sin determinar entre otras cosas, si le son o no aplicables los rótulos "demente" o "sordomudo que no sabe darse a entender por escrito". No cabe duda de que estas últimas palabras no tienen, en modo alguno, un campo rigurosamente preciso de aplicación. No hace falta meditar mucho para advertir que si bien la expresión jurídica "domicilio real", equivalente a "asiento principal de la residencia y negocios", tiene ejemplos claros de aplicación, hay muchos supuestos ante los cuales su aplicabilidad suscita dudas que no pueden resolverse sin tomar una genuina decisión. No menester gran perspicacia para darse cuenta de que, en nuestro sistema, la expresión altamente técnica "acto jurídico" es oponible a una determinada acción o transacción humana según que ésta pueda o no ser calificada de "acto realizado con discernimiento, intención y libertad", no opuesto a "las buenas costumbres" ni incompatible con "la libertad de la conciencia", expresiones que, huelga decirlo, no acotan una clase de actos perfectamente definida. Lo mismo puede decirse de distinciones tales como las que marcan las palabras "delito" y "cuasidelito", ligadas a "dolo" y "culpa"; o "acto válido" y "acto nulo" ("anulable"), ligadas a expresiones tales como "error sustancial", "dolo grave, determinante, que ocasiona un daño importante", "injustas amenazas de sufrir un mal inminente y grave", etcétera.

Nadie puede negar que estas fórmulas verbales son claramente aplicables a algunos supuestos de hecho, claramente aplicables a otros, y dudosamente aplicables a casos atípicos, malos o marginales. No podemos encerrarnos en la falsa seguridad de que los tecnicismos del lenguaje jurídico pueden eliminar esta última categoría de casos. La diaria experiencia de los tribunales y, en general, el contacto profesional con el derecho nos enseñan que esa seguridad es quimérica.

e) Los juristas (no todos) se dan cuenta (no siempre) de estas cosas. Cuando no los obsesiona el afán de alcanzar una inalcanzable seguridad, o el deseo de presentar, con fines didácticos, un cuadro de perfiles nítidos, libre de zonas grises, reconocen que "las categorías jurídicas no presuponen identidad de

las categorías y conceptos de otras ciencias, sino que se inspiran más bien en los conceptos vulgares" (Rotondi, *Instituzioni di Diritto Privato*, pág. 412), y admiten que por fuerza "tenemos que tropezar con la imprecisión o relatividad de los conceptos jurídicos", pues "existen numerosas zonas de transición, en las que el jurista debe estar alerta para no caer en una peligrosa geometría jurídica" (Dassen-Vera Villalobos, *Manual de Derechos Reales*, Parte General, Tea, 1962, pág. 1).

Los juristas advierten entonces que las clasificaciones jurídicas —incluso algunas tan básicas como la división entre derechos reales y personales— constituyen un "intento de agrupar distintos fenómenos" según caracteres que "no se dan en forma aislada sino en una gran variedad de matices y combinaciones", por lo que "necesariamente debemos contentarnos con criterios aproximativos y flexibles" (Dassen-Vera Villalobos, *ob. cit.*, pág. 4). Y destacan que nociones aparentemente tan precisas como "responsabilidad contractual" y "acción contractual", no son otra cosa que "conceptos clasificadores, cómodos, orientadores y útiles, pero siempre un poco arbitrarios y cuantitativos, como toda tentativa de trazar una línea divisoria allí donde existen matices, gradaciones y zonas de transición" (Gorla, *El contrato*, Ed. Bosch, Barcelona, 1959, pág. 13).

Podemos afirmar, en conclusión, que el lenguaje jurídico tiene básicamente las mismas características que los lenguajes naturales. Señalaré, a continuación, y en forma esquemática, algunas consecuencias que cabe extraer de ello.

II. CASOS TÍPICOS Y CASOS MARGINALES

1. DISTINTOS TIPOS DE CASOS

Las palabras que aparecen en las normas jurídicas para aludir a hechos, sucesos o actividades humanas, y proporcionar pautas o criterios para guiar o juzgar estas últimas, tienen, pues, una zona de penumbra, es decir, son actual o potencialmente vagas. La vaguedad se pone de manifiesto frente al caso marginal o atípico. En su presencia, quien trata de orientar su conducta se-

gún la regla, o apreciar el comportamiento ajeno a la luz de lo que se siente desconcertado. El caso no está claramente incluido en el área de significado central donde se congregan los casos típicos o paradigmáticos, ni claramente excluido de ella.

Por lo tanto, cualquier descripción honesta de lo que ocurre cuando un intérprete (un juez, un funcionario o un particular) trata de determinar si un caso concreto está o no comprendido por el significado actual de una regla, tiene que admitir que no todos los casos son del mismo tipo ni suscitan los mismos problemas. Dicha descripción debe distinguir entre estos dos tipos de casos:

a) aquellos cuyos hechos constitutivos están claramente comprendidos por el área de significado central de los términos o expresiones en que la regla consiste; y

b) aquellos que se encuentran en lo que —siguiendo a Hart¹— hemos llamado zona de penumbra, es decir, que son marginales o atípicos, en cualquiera de las múltiples formas en que esto puede ocurrir.

Esta distinción, a su vez, es vaga, porque depende de la distinción de zona de penumbra, que también lo es.

2. DESCUBRIR Y ADJUDICAR UN SENTIDO²

La solución de los casos del primer tipo, que para abreviar llamaré casos claros, puede ser adecuadamente descripta us

¹ Véase H. L. A. Hart, "El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral", en *Derecho y Moral: Contribuciones a su análisis* (traducción de Genaro R. Carrió), Depalma, Buenos Aires, 1962, págs. 116/19 y sigtes.; y *El Concepto de Derecho* (traducción de Genaro R. Carrió), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1963, Cap. VII, 1. "La textura abierta del derecho". Los desarrollos que seguidamente se hacen en el texto están influenciados visiblemente por las enseñanzas de Hart y por el análisis que trae Alf Ross en el capítulo IV de *Sobre el derecho y la justicia* (traducción de Genaro R. Carrió), Eudeba, Buenos Aires, 1963.

² En el uso de esta terminología sigo a Ross y a Perelman. Del primero véase *Sobre el Derecho y la Justicia*, págs. 116/19 y 131 y sigtes. Del segundo, "Avoir un sens et donner un sens", en *Logique et Analyse*, nº 20, diciembre de 1962, pág. 225 y sigtes.

do expresiones tales como "el intérprete descubrió o halló el significado que tal o cual norma tiene", o bien "el intérprete aplicó tal o cual regla en su significado objetivo". Pero esa manera de hablar no debe ocultarnos el hecho de que el significado "descubierto" u "objetivo" no puede ser sino una de estas dos cosas: (1) el significado que efectivamente quiso poner en la norma la autoridad que la sancionó: o (2) el significado que en contextos y situaciones semejantes le acuerda hoy el uso lingüístico preponderante, ya sea en la comunidad como un todo, ya en algún sector de ella a cuyos usos lingüísticos se atribuye un carácter privilegiado (por ejemplo, los jueces).

En cambio, la solución de los casos del segundo tipo, es decir, los de la zona de penumbra, no puede ser descripta de ese modo sin engendrar graves equívocos. Estamos frente a un caso atípico, marginal o insólito, en algún aspecto relevante. El caso no está claramente incluido ni claramente excluido por el significado "descubrible" de las palabras de la ley. El intérprete ha agotado todos los métodos de tipo cognoscitivo y su duda sigue en pie. Ella no deriva de ignorancia de los hechos, sino de ignorancia del significado efectivo de la regla en relación con esos hechos.

Para resolver el problema se ve forzado a *decidir*, bajo su responsabilidad, si esos hechos están o no comprendidos por las expresiones lingüísticas que, a ese respecto, son indeterminadas. Su decisión, en consecuencia, no está controlada por ellas.

Para considerar al caso como incluido o como excluido el intérprete se ve forzado a *adjudicar* a la regla un sentido que, en lo que hace al caso presente, hasta ese momento no tenía. Sólo así puede fundar en ella la inclusión o la exclusión. Ese sentido o significado no estaba en la regla. Claramente ha sido *puesto* por el intérprete sobre la base de una decisión no determinada por los hábitos lingüísticos establecidos. Si esta adjudicación de sentido no es arbitraria (y no tiene por qué serlo), estará guiada por ciertos *standards* valorativos, sociales, políticos, económicos, etc., a la luz de los cuales se aprecian y sopesan las consecuencias de la inclusión o exclusión. Estos criterios adicionales son los que dan fundamento a la decisión; no la regla o reglas del orden jurídico, que simplemente *no se oponen* a ella.

De todo esto se siguen algunas consecuencias cuya enunciación resultará, para muchos, bastante menos monótona que las aparentes trivialidades que recordé en la primera parte, al destacar algunas características de los lenguajes naturales. Esas consecuencias, empero, se siguen *necesariamente* de tales supuestas trivialidades.

3. TRES CONSECUENCIAS

Primera consecuencia: Es falsa la afirmación, tan repetida, de que el derecho, es decir, un cierto orden jurídico, es un sistema cerrado, dotado de "plenitud hermética" o "finitud lógica", del cual pueden derivarse, por deducción, las soluciones para todos los casos posibles. El derecho, o sea un orden jurídico determinado, *tiene lagunas*, en el sentido de que hay casos que no pueden ser resueltos con fundamento exclusivo en sus reglas o en alguna combinación de ellas.

En relación con esto se hacen necesarias, creo, algunas aclaraciones. [En primer lugar, cuando afirmo que, en el sentido indicado, todo orden jurídico tiene "lagunas", no quiero decir únicamente que el legislador es incapaz de dar solución anticipada a todos los supuestos, sino algo mucho más radical. A saber, que aun admitiendo que el orden jurídico está integrado también por las pautas jurisprudenciales vigentes, fruto de la labor judicial que va llenando los "vacíos" de la legislación y haciendo frente, con mayor o menor imaginación y coraje, a las cambiantes necesidades del cuerpo social, y aun concediendo que de algún modo no clarificado ese orden se complementa con los conceptos dogmáticos elaborados por los juristas teóricos, siempre quedan y quedarán zonas de indeterminación, cuyos límites son indeterminables. Los casos que se suscitan en ellas reclamarán, en su momento, auténticas decisiones (y no simples deducciones). Una vez consolidadas, esas decisiones aportarán certeza a un área que, hasta entonces, carecía de ella.] Es, precisamente, el papel principal de la jurisprudencia.

En segundo lugar, si al afirmar que un orden jurídico tiene "lagunas" queremos decir todo eso, pero nada más que es

entonces no sirve como contra-argumento sostener que no existen "lagunas" porque los jueces no deben dejar de fallar. Tal réplica es insuficiente, aunque se la apoye diciendo que cuando los jueces rechazan una pretensión porque no hay norma positiva que la sustente están aplicando el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, que sería una parte "necesaria" de todos los órdenes jurídicos y que, operando como norma de clausura, los presentará como sistemas herméticos, plenos o finitos.

Son varias las razones que hacen que éste no sea un buen contra-argumento. En la mayoría de las ramas del derecho el rechazo de la demanda no es la única alternativa frente a la ausencia de normas expresas que justifiquen claramente su aceptación. No parece serio, por otra parte, sostener que no hay "lagunas" porque los jueces las colman. Tampoco lo parece admitir sin análisis que cuando decimos que en ciertos casos los jueces, al rechazar la demanda o al absolver al acusado, *aplican* el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, "aplican" tiene el mismo sentido que cuando decimos que los jueces, al condenar a alguien por homicidio simple, *aplican* el artículo 79 del Código Penal argentino. Pero aunque pudiéramos superar estas dificultades y sostener, sin hacer distinguos, que para todo supuesto hay reglas "aplicables" (las normas positivas o el llamado principio de clausura), siempre cabría preguntarse si podemos deslindar el área cubierta por las primeras y el área "cubierta" por la última mediante un conjunto determinado de criterios precisos que, sin vacilaciones, nos permiten ubicar en uno u otro sector a todos los casos posibles. Porque si no existen tales criterios hay penumbra y, en el sentido en que he usado la palabra, hay "lagunas".

La última aclaración es ésta. De lo expuesto se sigue que no es muy afortunado hablar de "lagunas", pues esta metáfora sugiere la existencia de una clara línea de delimitación entre los casos claros y los que (todavía) no lo son. El uso de una metáfora que posee tal sugerencia puede provocar confusión. Tal vez sea mejor prescindir de ella y decir, simplemente, que el orden jurídico no es un sistema cerrado o finito, sino un "sis-

tema abierto"³, y si esto no suena bien, negar derechamente carácter sistemático al orden jurídico, entendido como un conjunto de reglas *usadas* por funcionarios y particulares como pautas o criterios de conducta, y no como una estructura coherente de reglas y principios *mencionados* por teóricos y profesores a quienes acucia el deseo de presentar, a cualquier precio, una imagen pulcra y nítida.

Segunda consecuencia: Si los jueces no quieren resolver ciegos o en forma arbitraria los casos de la penumbra (que por razones obvias constituyen una importante proporción de los que se litigan), no les basta con conocer a fondo las normas jurídicas y sus fuentes, ni saber armar con ellas estructuras coherentes.

Tienen que poseer, además, una adecuada información de hecho sobre ciertos aspectos básicos de la vida de la comunidad a que pertenecen, un conocimiento serio de las consecuencias probables de sus decisiones y una inteligencia alerta para clarificar cuestiones valorativas y dar buenas razones en apoyo de las pautas no específicamente jurídicas en que, muchas veces, tienen que buscar fundamento. Algo semejante se requiere de los jueces que no se resignen a ser meros espectadores de un espectáculo que no entienden. De lo contrario ni unos ni otros estarán en condiciones de cumplir una función social verdaderamente útil.

Tercera consecuencia: Es verdad que los casos ubicados en la zona de penumbra tienen título suficiente para atraer, en todo momento, la atención de los juristas profesionales. Pero la aparición siempre constante no es incompatible con el hecho, fácilmente comprobable, de que la aplicación y el uso cotidiano de la mayoría de las reglas que componen un orden jurídico suscitan, por lo general, problemas semejantes a los que aquéllos casos plantean. Importantes sectores de la vida comunitaria están controlados por reglas cuyo significado cubre claramente la enorme mayoría de los supuestos de hecho que están destinados a regular.

³ Sobre el sistema jurídico como "sistema abierto" ver Levi, *Introducción al razonamiento jurídico* (traducción de Genaro R. Carrió), Eudeba, Buenos Aires, 1964, apartado I, y nota del traductor nº 3.

Hay que tener en cuenta, además, que existen zonas donde por diversas razones se hace necesaria la intervención de los jueces en la aplicación de las reglas, aunque no haya, ni en el caso quepan, interpretaciones discrepantes. Tal es lo que ocurre, por ejemplo, con la aplicación de las normas penales, de las relativas a divorcio, a trámites sucesorios, a cuestiones que involucren la persona o los bienes de incapaces, etc. En buena parte de estos casos de aplicación de reglas no se requiere que los jueces adopten ninguna actitud crítico-valorativa frente a ellas, ni que escudriñen su finalidad social, ni que se coloquen en una posición análoga a la del legislador. Tales casos pueden estar, en una proporción importante, claramente comprendidos por el significado "natural" de las reglas, que reciben allí una aplicación, por así decir, "automática".

Algo semejante puede llegar a ocurrir en otras áreas del derecho cuando, por razones ligadas a circunstancias económicas especiales, proliferan artificialmente los litigios porque muchos prefieren afrontar un pleito, aun con la certeza de que la resolución final les será adversa, con tal de demorar el cumplimiento de sus obligaciones.

Hablar en todos estos casos de la función "creadora" de los jueces o intérpretes es, sin duda, un abuso de lenguaje y una grave fuente de confusiones, tan grave como hablar de "mera aplicación" en los supuestos de genuina decisión de casos difíciles o dudosos.

III. DOS TIPOS DE UNIFORMIDAD DEFORMANTE

Es equívoco describir la tarea de administración de justicia (o de aplicación de reglas generales a casos concretos) como si todos los casos fueran del tipo de los casos claros o todos del tipo de los casos de la penumbra. El uso de la misma palabra, "interpretación", para aludir a dos actividades básicamente distintas, borra una distinción útil y sugiere una homogeneidad inexistente. Así lo ha demostrado Ross con gran penetración⁴.

⁴ *Sobre el derecho y la justicia*, capítulo IV, págs. 131 y sigs.

Cuando la homogeneidad se alcanza sobre la base de equiparar artificialmente todos los casos con los que hemos llamado casos claros, se incurre en el vicio de *formalismo* (o racionalismo). Consiste, fundamentalmente, en *no ver* los problemas de la penumbra.

Cuando la homogeneidad se alcanza sobre la base de equiparar artificialmente todos los casos con los casos de la penumbra, se incurre en el vicio opuesto que, a falta de una denominación corrientemente aceptada llamaré *realismo extremo*, o más brevemente "realismo". Consiste, fundamentalmente, en *no ver sino* los problemas de la penumbra.

Se trata de dos exageraciones de signo opuesto que parecen reclamarse dialécticamente. La segunda surgió como una respuesta a la primera y advino a la palestra poseída de un impulso destructor demolidoramente eficaz. Más adelante veremos que una y otra exageración, que ejercen una seducción irresistible sobre el espíritu de los juristas, son tributarias del mismo tipo de error respecto de ciertas características del lenguaje del derecho y, en particular, del papel que en la guía de la vida de una comunidad desempeñan las normas jurídicas.

1. LA POSICION FORMALISTA

Tomemos como modelo la variedad de formalismo más elaborada y más influyente, por lo menos entre nosotros: la dogmática jurídica.

Sus tesis principales pueden ser resumidas como sigue:

a) El derecho es un sistema cerrado, dotado de plenitud hermética o finitud lógica, del que pueden derivarse —esto es, deducirse— soluciones para todos los casos individuales, reales posibles.

b) No es correcto identificar el sistema jurídico con la voluntad histórica de un legislador o de una sucesión de legisladores. La ley, una vez dictada, adquiere una suerte de vida propia. Su significado no permanece estático sino que evoluciona con el cambio de los tiempos, siguiendo una línea de desarrollo que va actualizando sus virtualidades.

c) Compete a los juristas —los científicos del derecho— exhibir y fijar en conceptos los pasos de esa evolución. A tal fin, con métodos específicos propios de su disciplina, ellos operan abstracciones de primer grado: a partir del material en bruto de las normas positivas arriban a conceptos jurídicos dotados de nitidez y fijeza absolutas. Esos conceptos jurídicos, a su vez, pueden servir de base para sucesivas abstracciones de grado superior. El resultado final es un conjunto sistemático y coherente de proposiciones, construidas exclusivamente a partir del material positivo dado.

d) La tarea del juez o del intérprete se reduce a *descubrir* la regla general que ha de resolver el caso concreto que se le presenta. Esa tarea se alcanza, cuando la complejidad del caso lo requiere, mediante una integración sistemática, coherente y dinámica, de conceptos y figuras jurídicas tomadas de todo el ordenamiento. El material está dado exclusivamente por el orden jurídico; no es legítimo echar mano de elementos de otro origen, a menos que las normas jurídicas expresamente lo admitan. Nada en la actividad del juez o del intérprete puede describirse como "creación": si bien él elabora la regla general bajo la que va a subsumir el caso, todos los elementos que entran en esa elaboración le están dados o impuestos por el orden jurídico y exclusivamente por él. Todo consiste en saber descubrir la combinación adecuada.

Espero que esa caracterización, aunque esquemática, no será considerada una caricatura. Al formularla he tenido principalmente en cuenta el ya citado libro de Soler, *La interpretación de la ley*, que representa, según mi modo de ver, la más completa elaboración de la posición dogmática escrita en nuestro idioma.

Esta posición puede ser explicada en función de un conjunto de factores históricos que permiten entender cómo se llegó a ella. Para comprender por qué se la sigue sosteniendo hoy se hace menester reparar en ciertas motivaciones de tipo ideológico. Hay de por medio un explicable anhelo de *seguridad*. Se prefiere concebir el derecho como una voluntad impersonal y objetiva, liberada de las apetencias e intereses de los seres humanos, porque se piensa que esa es la única alternativa frente a

los regímenes caracterizados por las decisiones incontroladas de hombres providenciales. Se trata de optar entre un gobierno de leyes y un gobierno de hombres. Lo primero, que se reputa indudablemente preferible, requiere adherir a las tesis resumidas más arriba. Tal es el planteo.

La variante de formalismo más influyente en nuestro medio es heredera, consciente o no, de la jurisprudencia conceptual (*Begriffsjurisprudenz*) alemana, que mereció primero la adhesión entusiasta y luego el caústico repudio de Ihering. En el mundo anglosajón hubo también una variedad de formalismo protagonizada por algunos epígonos de Austin que, apartándose del fundador de la *Analytical Jurisprudence*, creyeron que toda la faena de los juristas consiste en la ordenación y sistematización de los conceptos jurídicos de diverso nivel y que la de los jueces se agota en deducir soluciones correctas a partir de reglas pre-determinadas.

2. LA REACCION REALISTA

El formalismo desencadenó reacciones a ambos lados del Atlántico. Las hubo moderadas, y también extremas. Entre las primeras debe señalarse la línea sociológica —este rótulo es quizás demasiado impreciso— que en forma directa o indirecta se apoya en el último Ihering, el de *Der Zweck*. Allí se ubica la jurisprudencia de intereses (*Interessenjurisprudenz*), cuyo expositor más brillante es Philipp Heck. Entre las reacciones moderadas se cuenta también la que tuvo como inspirador a Gény. La contrapartida de la *Interessensjurisprudenz* en el mundo de habla inglesa está representada principalmente por Pound y Cardozo.

Entre las reacciones extremas hay que mencionar dos: la *Freirechtslehre*, o concepción del derecho libre, de origen alemán, y su contrapartida en el mundo anglosajón, el llamado realismo jurídico norteamericano de la década 1930/40. Este último movimiento tuvo mucha mayor influencia que su equivalente europeo. Son numerosos los factores que permiten explicar por qué germinó en el suelo de los Estados Unidos y alcan-

zó allí desarrollos tan importantes. No puedo detenerme en eso. El llamado realismo jurídico escandinavo tiene otro alcance y otras pretensiones, aunque comparte ciertos puntos de vista básicos con el realismo norteamericano.

Las críticas al formalismo han seguido, en líneas generales, estas dos direcciones: se le ha reprochado que es *falso* en cuanto descripción de lo que efectivamente acontece en la administración de justicia, y que es *inconveniente* en cuanto modelo de lo que deben hacer los jueces o funcionarios al decidir casos concretos.

No voy a reproducir aquí esas críticas en detalle. Ellas son bien conocidas. Sólo quiero señalar que en su afán crítico los "realistas" llegaron a negar que las normas y los conceptos generales desempeñaban un papel importante en la práctica del derecho. Esto es excesivo y su postulación no es necesaria para demostrar las insuficiencias y errores de la posición formalista.

Los "realistas", es verdad, pusieron ante nuestros ojos hechos muy importantes que la teoría jurídica había pretendido ignorar. Pero también es verdad que muchos de ellos confundieron sistemáticamente los problemas psicológicos implicados en la génesis o motivación de las decisiones judiciales y los problemas de un tipo completamente distinto vinculados a la justificación de ellas. Al incurrir en esa confusión echaron por la borda mucho más de lo que era necesario para refutar el esquema formalista.

Para ello no era menester ponerse la máscara siniestra del Mal Hombre, cuyo punto de vista, dicho sea de paso y mal que nos pese, esclarece mucho de lo que tienen de distintivas ciertas actividades específicas de los abogados. Bastaba con recuperar el punto de vista del Hombre Sensato, para no pasar de una exageración a la opuesta o, en otros términos, para no saltar de un enfoque afectado por una cierta deformación profesional (la de los profesores de derecho) a otro afectado por una deformación profesional distinta (la de los abogados). Los excesos en la crítica condujeron, como suele ocurrir, a un resultado contrario al buscado. Sirvieron para robustecer las convicciones formalistas de muchos cultores de la teoría jurídica y para desprestigiar una actitud crítica sana y fecunda.

IV. DOS CRÍTICAS AL FORMALISMO

Ya dije que no voy a reproducir las críticas de los “realistas”. En este apartado me limitaré a destacar dos objeciones que los realistas no hicieron, por lo menos en la forma en que la expondré. En el apartado siguiente añadiré una tercera, que los “realistas” no pudieron haber hecho porque también los alcanza.

Las dos primeras objeciones apuntan a una de las tesis principales de la dogmática: la que afirma que mediante la síntesis o combinación de conceptos precisos, extraídos exclusivamente del orden jurídico, es siempre posible construir la norma que permitirá, por deducción, fundar la solución del caso y que, por lo tanto, el sistema es cerrado y completo. La tercera objeción apunta a un falso dilema aceptado —expresa o tácitamente— por formalistas y “realistas”.

1. PRIMERA CRÍTICA: “UMBRAL” VS “ZONA DE PENUMBRA

Se pretende que los conceptos jurídicos que entrarán en la síntesis son fijos y nítidos. Esto es, que carecen de lo que hemos llamado zona de penumbra y que a su respecto solo cabe hablar de “umbral”. Esta última figura de expresión, muy reveladora, pertenece a Soler. En *La interpretación de la ley* este autor señala que la imagen kelseniana del “marco” legal dentro del cual el intérprete crea su decisión puede convenir al caso en que un juez, frente a una estafa, fija la pena en concreto dentro de los límites, mínimo y máximo, autorizados por la ley. Ese elemento cuantitativo, dice Soler, se presta a la imagen del marco, pero si reparamos sólo en él operaremos una especie de escamoteo que ocultará lo más importante de la faena interpretativa. Vale la pena transcribir las palabras de nuestro autor:

“En el caso referido, además de la tarea de escoger entre un mes y seis años, está el de saber, comprender o entender el significado de ‘defraudar’ y de ‘ardid’, porque con respecto a esos elementos de la ley es absolutamente claro que, contrariamente a lo que dicen los neorrealistas del tipo de Gray, no es cierto que será *defraudar* y *ardid* lo que los jueces digan efectivamente que lo es... Acaso sea exacto en algunos casos

seguir hablando de un marco, pero nos inclinamos a creer que esos conceptos más bien responden a la idea del sí o del no, están compuestos por un conjunto de notas que se dan o no se dan y, en consecuencia, son o no son. La idea del marco dentro del cual nos movemos libremente no parece convenir en absoluto para definir la actividad desarrollada en este punto por el juez; parece convenir más bien la idea de umbral; lo importante no es lo que haremos una vez que estemos dentro de la casa; lo importante es decidir si entramos o no entramos: estamos frente a un dilema” (*op. cit.*, págs. 73/74).

Soler vuelve sobre el punto un poco más adelante, cuando hace referencia a una distinción entre dos tipos de normas, las que “expresamente crean un marco y las que plantean un dilema en el cual *tertius non datur*” (*op. cit.*, pág. 77). Ya en *Fe en el Derecho* el mismo autor había sostenido que “la fórmula jurídica, reguladora de acciones, se encuentra siempre ante una situación dilemática, que termina en sí o en no, es decir, en la absoluta precisión. En ese plano, *tertius non datur*: podemos o no podemos hacer con derecho”⁵.

Pues bien, esta figura del “umbral”, que trata de presentar gráficamente la existencia de una alternativa gobernada por el principio del tercero excluido, es claramente inadecuada. También lo es, dicho sea de paso, la imagen kelseniana del “marco”, en cuanto sugiere la existencia de un área de contornos netamente definidos, que separan los supuestos que están dentro y los que están fuera del campo de aplicación de una norma.

La imagen del “umbral” es inadecuada por la siguiente razón. Para que los conceptos y términos jurídicos puedan ser usados para regular una cierta realidad, para autorizar o prescribir acciones humanas, para justificar decisiones acerca de ellas, etc., tales conceptos y términos tienen que ser definibles,

⁵ *Op. cit.*, pág. 130. En el capítulo XIX de ese libro, bajo el título “La solidez ideal del derecho”, el autor formula apreciaciones coincidentes. En la pág. 216 se lee que los conceptos jurídicos “tienen cierto alcance, con un mínimo indispensable y una capacidad de absorción que llega hasta cierto punto. Antes de alcanzar ese límite, no hay nada, sobrepasado el máximo, hay otro concepto”. Véanse también págs. 245/46; 259/60; 269 y 281/85, todas ellas reveladoras de la posición que criticamos en el texto.

por fuerza, en términos del lenguaje natural. Y ya hemos visto que las palabras del lenguaje natural no tienen criterios de aplicación rígidos o de perfiles nítidos. Todas ellas son actual o potencialmente vagas. No es verdad que su aplicación plantee necesariamente un dilema en el cual *tertius non datur*. El principio del tercero excluido sólo vale para símbolos no interpretados; esto es, en dominios donde —como ocurre en matemática pura o en lógica— se opera con símbolos precisos.

Las afirmaciones de Soler, o bien presuponen que un sistema jurídico está constituido a semejanza de un sistema de geometría pura —y esta presuposición abre un flanco difícilmente defendible frente a las críticas de los “realistas”— o no se hacen cargo de ciertas características de los lenguajes naturales que desde hace algún tiempo se vienen destacando con insistencia.

A la imagen del “umbral”, a la concepción de que el lenguaje de los juristas está integrado por palabras “que responden a la idea del sí o del no”, a la afirmación de que tales términos se refieren “a un conjunto de notas que se dan o no se dan”, en consecuencia, “son o no son”, de suerte que su aplicación nos coloca “frente a un dilema ante el cual *tertius non datur*” cabe responder con estas palabras de Bertrand Russell⁶:

“Consideremos las diversas formas en que las palabras comunes son vagas, y comencemos con una palabra como ‘rojo’. Es perfectamente evidente, desde que los colores constituyen un continuo, que hay matices de color que dudaremos en llamar o no rojos, no porque ignoremos el significado de la palabra ‘rojo’ sino porque es una palabra cuyo campo de aplicación es esencialmente dudoso. Esta es por cierto, la respuesta al viejo acertijo del hombre que se volvió calvo. Se supone que al principio no era calvo, que perdió sus cabellos uno por uno y que sólo entonces quedó calvo; por lo tanto, si arguye, debe haber habido un cabello cuya pérdida lo convirtió en un hombre calvo. Esto, por supuesto, es absurdo. El ‘calvicie’ es un concepto vago; algunos hombres son efectivamente calvos, algunos no lo son, mientras que entre ellos ha-

⁶ “Vagueness”, *The Australasian Journal of Psychology and Philosophy*, t. 1, pág. 84, año 1923; artículo traducido al castellano bajo el título de “Vaguedad”, y publicado en *Antología Semántica*, compilada por Mario Bunge, Nueva Visión, Buenos Aires, 1960, págs. 14/24.

hombres de quienes no es verdadero afirmar que deben ser calvos o no. *La ley del tercero excluido es verdadera cuando se emplean símbolos precisos, pero no es verdadera cuando los símbolos son vagos, como lo son de hecho todos los símbolos. Todas las palabras que describen cualidades sensibles tienen la misma clase de vaguedad que la palabra ‘rojo’...* El hecho es que todas las palabras son sin duda atribuibles en cierto dominio, pero se tornan cuestionables dentro de una penumbra, fuera de la cual son sin duda no atribuibles. Alguien podría tratar de obtener precisión en el uso de las palabras, diciendo que ninguna palabra puede ser aplicada en la zona de penumbra; pero por fortuna *la penumbra misma no es exactamente definible*; y toda la vaguedad que confiere al uso primario, la confiere también cuando tratamos de fijar un límite a su indudable aplicabilidad”. (Las bastardillas son mías).

Esta cita resulta tan oportuna que no he podido resistir a insertarla, pese a su extensión. Porque no puede caber duda de que “ardid” o “defraudar” son palabras que acotan cierto campo de la realidad —en este caso, del comportamiento humano— con una vaguedad o imprecisión por lo menos igual, si no mayor, que la que exhiben los ejemplos utilizados por Russell.

2. SEGUNDA CRITICA: EL CARACTER INFINITO DE LAS COMBINACIONES POSIBLES Y LA REGLA O REGLAS DE SELECCION

La segunda crítica nos llevará menos tiempo. Puede ser formulada así:

El número de síntesis o combinaciones posibles es infinita. Así lo hace notar Soler en *La interpretación de la ley*. Véase, por ejemplo, la comparación con el alfabeto (pág. 161) y especialmente las págs. 165/66, donde dice: “Las combinaciones en que cada letra puede entrar *son infinitas* y con suma frecuencia, sobre todo en ciertos idiomas, la función cumplida por la letra es muy diferente, según sea el lugar que ocupa en las palabras, y según sean las vecinas entre las cuales se encuentre... *Semejantemente ocurre en el derecho*. La función cumplida por un precepto varía intensamente según el complejo en que se inserte” (Las bastardillas son mías).

Pues bien, si la elección de una de esa infinita serie de combinaciones o síntesis posibles no se efectúa al azar (y asumo que nadie pretenderá que así ocurren las cosas ni, mucho menos que así deben ocurrir), entonces ella estará guiada por algún principio o criterio de selección y síntesis. Si se piensa que ese criterio selectivo es externo al sistema —ciertos juicios de valor fundados en consideraciones políticas, económicas, etc.— ello importa admitir que el mismo *no es completo*. Pero aunque se considere que es interno al mismo, como parte de sus reglas de decisión (algo así como reglas de segundo grado que prescribirían la forma de realizar las síntesis para cada caso), tales reglas de segundo grado tendrían por necesidad —salvo que fuesen vacuas— su propia penumbra de vaguedad o textura abierta y así hasta el infinito.

No es posible remediar la indeterminación que surge de la textura abierta, porque las reglas destinadas a ello llevarían consigo su propio halo de penumbra. Recuérdese la parte final de la cita de Russell: “la penumbra misma no es exactamente definible; y toda la vaguedad que confiere al uso primario la confiere también cuando tratamos de fijar un límite a su indudable aplicabilidad”. La indeterminación marginal del orden jurídico es algo con lo que tenemos que contar; no puede ser eliminada con esperanzas ilusorias, por muy dignos que sean los motivos que las inspiran. La certidumbre absoluta en estas cuestiones es algo que falta, como tantas otras cosas, en el limitado equipaje de los hombres.

V. UNA CRÍTICA A FORMALISTAS Y “REALISTAS”

Hay una tercera objeción básica que también apunta al olvido de ciertas características de los lenguajes naturales, evidenciado en la aceptación dogmática de un falso dilema. Esta objeción alcanza por igual a formalistas y “realistas”. Unos otros presuponen sin análisis la verdad de esta alternativa: las normas determinan la totalidad de la conducta o no la determinan sino puras decisiones individuales. El formalista, que tiene explicable horror ante la inseguridad, se decide por el p-

mer término. El “realista”, que sabe que la seguridad absoluta no es bien deparado a los mortales y que está persuadido, por ello, de que las normas jurídicas no pueden proporcionarlo, se decide por el segundo término.

Para un ejemplo claro de la aceptación del falso dilema por un pensador de cuño formalista puede verse el ya citado libro *La interpretación de la ley*, de Soler. Criticando a Recasens Siches, expresa dicho autor:

“No entendemos, por ejemplo, cómo puede reconocerse que el derecho debe ‘elaborar conceptos abstractos’ pero no tomarlos como ‘mandatos inflexibles’. La cuestión consiste en saber —según lo veremos más adelante— si puede haber normas en general sin que ellas estén constituidas necesariamente por abstracciones, cuestión a la que no parece que puede darse más que respuesta afirmativa. Si esa es una necesidad de toda norma, está sobrando la referencia a los mandatos *inflexibles*. O ponemos las normas mediante abstracciones porque no hay otra manera de ponerlas, o no las ponemos; pero parece un poco juguetón el pensamiento que después de reconocer el primer término del dilema se complace en acariciar la esperanza de que pongamos las normas para no cumplirlas, o bien, al menos para que sean siempre flexibles, aun cuando las hayamos querido poner como inflexibles”⁷.

La idea de que los “realistas” pagan tributo, paradójicamente, al mismo error, está expuesta por Dickinson⁸ y por Hart. Dice este último⁹: “El escéptico ante las reglas es a veces un absolutista desilusionado: se ha dado cuenta de que aquéllas no son los que serían en un paraíso formalista, o en un mundo en que los hombres fueran dioses y pudieran anticipar todas las combinaciones de hechos, y la textura abierta no fuese una característica necesaria de las reglas. La concepción del escéptico

⁷ *Op. cit.*, págs. 35/36. Para otros ejemplos de la aceptación expresa o tácita del falso dilema ver *op. cit.*, págs. 3, 44, 127, 128, 132, 137-38, etc.

⁸ “Legal Rules. Their Function in the Process of Decision”, 79 *University of Pennsylvania Law Review*, 833, pág. 835, y “Legal Rules. Their Application and Elaboration”, en 79 *University of Pennsylvania Law Review*, pág. 1059.

⁹ *El concepto de Derecho*, págs. 173/74.

sobre lo que es la existencia de una regla puede consistir en un ideal inalcanzable, y cuando descubre que lo que llamamos reglas no realiza ese ideal, expresa su desilusión negando que ha ya o que pueda haber regla alguna".

La buena tesis consiste en rechazar por inaceptable el dilema. Ese rechazo halla fundamento seguro en un buen análisis de las características del lenguaje. Hay normas jurídicas y ellas desempeñan un papel indispensable en la práctica cotidiana del derecho. Pero esas normas no determinan toda la conducta pues tienen una textura abierta o presentan una zona de penumbra dentro de la cual el intérprete tiene que decidir bajo su responsabilidad. Tal decisión no puede ser razonablemente descrita como una simple deducción a partir de reglas que ya tenían un significado que aquél se limitó a descubrir. En otros términos, las reglas del sistema controlan los casos claros, pero no los de la penumbra. Y en eso exhiben las mismas características que el lenguaje natural.

NOTAS Y COMENTARIOS

1. LENGUAJE JURIDICO Y LENGUAJE NATURAL (APARTADO I)

"El lenguaje ordinario, en el que el derecho está necesariamente expresado —porque, de otro modo, ¿cómo podría preservarse su contacto con la vida real?— no es un instrumento de precisión matemática, sino que presenta lo que con acierto ha sido llamado una "textura abierta" (Dennis Lloyd, *Introduction to Jurisprudence*, Stevens & Sons, Londres, 1959, pág. 398).

En *Fe en el Derecho y otros ensayos*, T.E.A., Buenos Aires, 1956 (págs. 129-130), Soler expresa que "el primer objeto de las normas consiste en que las gentes las entiendan, sin distinciones sociales y a pesar de los grandes desniveles que existen dentro de una misma comunidad". A diferencia de la doctrina jurídica, que "puede... presentarse con un mayor o menor grado de hermetismo defensivo de su exactitud", la norma, "término y fin de toda teoría jurídica, es decir, el verdadero derecho, no tiene más remedio que sumergirse en el mundo de las palabras: debe recoger y emplear esos modos expresivos que la vida cotidiana crea, deforma, amplía y corrompe, porque aspira a regir la conducta de todos. Su primera necesidad es la de ser entendida, para que pueda ser obedecida". Soler cree, sin embargo, que con ese material es posible —aún más, es necesario— acuñar fórmulas verbales rigurosas, dotadas de absoluta precisión: "La exactitud tajante de las palabras de la ley es una exigencia de la necesaria exactitud de sus disposiciones, no ya en (sic) una mera complacencia estética. La ley debe a un tiempo

ser inteligible con facilidad para todos e intergiversable; con labras corruptas debe acuñar fórmulas nítidas..." (ob. cit., págs. 130-131). Claro que esto es imposible; en el texto encontramos esa posición (ver apartado IV, Dos críticas al formalismo).

Para una apreciación inteligente del problema del lenguaje de las normas jurídicas, véase el artículo de Jerzy Wroblewski "Semantic basis of the theory of legal interpretation" (*Logique Analyse*, nos. 21 a 24, diciembre de 1963, págs. 397-416). Allí se lee: "Las reglas sobre la comprensión inmediata de las normas jurídicas no son más explícitas que las reglas del mismo tipo relativas al lenguaje cotidiano. El análisis de éste no ha avanzado aún lo suficiente para explicar su contenido y operación. Construir lenguajes artificiales diversos, tales como los de los cálculos formalizados de los distintos sistemas deductivos, es tarea más fácil que hacer explícitas las reglas subyacentes al lenguaje cotidiano, con todas sus incertidumbres y faltas de precisión. Sin embargo, a pesar de ese inconveniente, usamos el lenguaje cotidiano sin trabas; éste funciona bien para la transmisión ordinaria de informaciones en el universo del discurso de nuestra vida diaria. Lo mismo puede decirse de las reglas de comprensión inmediata en el lenguaje jurídico, que se encuentran 'entre' el lenguaje cotidiano y los lenguajes artificiales, más precisamente quizás al primero que a los últimos. Es difícil formular reglas, pero la comprensión de las normas jurídicas que no admiten dudas constituye la prueba empírica de la existencia de reglas semánticas de este tipo, que se han incorporado a los modos jurídicos de pensar, mediante la educación y la tradición jurídicas" (ob. cit., pág. 409; el subrayado es mío).

Cf. también Viehweg, *Topik und Jurisprudenz*, cap. 7, Topica y Axiomática, donde el autor alude al lenguaje espontáneo como herramienta necesaria del sistema específicamente jurídico. Esto es, el sistema que sirve para decidir conflictos, como es distinta del sistema didáctico, que puede presentar un carácter unívoco y claro a los fines de la enseñanza del derecho (ver págs. 98-104 de la edición italiana, *Topica e Giurisprudenza*, traducida por Giuliano Grifò, Ed. Giuffrè, Milán, 1962).

Véase igualmente Philipp Heck, *Begriffsbildung und*

ressensjurisprudenz, trabajo traducido al inglés bajo el título de "The Formation of Concepts and the Jurisprudence of Interests" que es parte del volumen *The Jurisprudence of Interests*, (traducción de M. Magdalena Schoch) Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1948, págs. 101-256. En la pág. 147 de ese volumen se lee lo siguiente: "Los conceptos jurídicos tienen en común con los de la vida ordinaria la cualidad de que usualmente no están definidos en forma tajante. Todo concepto tiene un núcleo de perfiles nítidos y una penumbra que gradualmente se va esfumando". (Heck se equivoca, empero, cuando habla de núcleo "de perfiles nítidos". Hay en eso una contradicción con lo expresado antes).

2. CASOS TÍPICOS Y CASOS MARGINALES (APARTADO II, 1)

Cf. Hart, "El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral", que integra el volumen *Derecho y Moral: Contribuciones a su análisis*, Depalma, Buenos Aires, 1962, pág. 1-64. Véanse en particular págs. 25-28, donde se habla de los "problemas de la penumbra" y págs. 39-40, donde se les contraponen "un elemento central del derecho vigente que puede ser visto como un núcleo de significado central de las reglas". Del mismo Hart ver también *El Concepto de Derecho*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1963, cap. VII. Ver también Dickinson, "Legal Rules: Their Function in the Process of Decision", 79 *University of Pennsylvania Law Review*, pág. 833; en especial págs. 846-47.

3. DESCUBRIR Y ADJUDICAR UN SENTIDO (APARTADO II, 2)

"Pero nosotros sabemos... que un texto que parece perfectamente claro puede dejar de serlo cuando se hace necesario aplicarlo a situaciones imprevistas, y en las que el legislador no había podido pensar. Nociones claras son aquellas cuya extensión es conocida; pero lo que caracteriza a toda legislación que impone la obligación de juzgar es que es posible que ella de-

ba ser aplicada a situaciones radicalmente nuevas. ¿Cómo hemos de expresar nuestras intenciones para que un cierto tipo plicar los cambios de jurisprudencia que se producen de modo que la conducta esté reglado por normas, entonces es necesario que regular en todos los sistemas jurídicos? Cuando ante un caso las palabras generales que usamos... tengan algún ejemplo típico nuevo la interpretación antigua es considerada contraria al tipo respectivo del cual no existen dudas acerca de la aplicación de finalidad de una institución jurídica, la decisión jurisprudencial aquéllas. Tiene que haber un núcleo de significado establecido, podrá dar a un texto antiguo un sentido nuevo" (Perelman, pero también habrá una penumbra de casos discutibles en los "Avoir un sens et donner un sens", en *Logique et analyse*, 1962, pág. 235 y sigs. El párrafo transcrito no aplicables. Cada uno de estos casos tendrá algunas notas en rece en pág. 238).

"Si por una razón u otra (es decir, ya sea porque ellos características que no estaban presentes en aquél. La in-puede hallar prueba concluyente o porque la intención no inventiva humana y los procesos naturales aportan en forma confu-suficiente profundidad) no es posible llevar adelante la intención tales variaciones respecto de lo familiar, y si hemos de de-tación más allá de un punto que deja abierto un número de decidir que esta clase de hechos cae o no bajo lo prescripto por sibilidades, entonces el intérprete debe abandonar. Si, con las reglas existentes, entonces quien clasifica tiene que adoptar do, elige una posibilidad en particular, ello no constituye el una decisión que no le es impuesta, porque los hechos y los ximo paso dentro de una interpretación sino que es una decisión fenómenos a los que conformamos nuestras palabras, y a los motivada por consideraciones ajenas al deseo de aprehender que aplicamos nuestras reglas son, como quien dice, mudos"... significado de una expresión. La interpretación de directiva "Las situaciones de hecho no nos aguardan netamente rotuladas especialmente, exige decisiones de este tipo" (Alf Ross, *Sobre y plegadas; su clasificación jurídica no está escrita en ellas pa-Derecho y la Justicia*, Eudeba, Buenos Aires, 1963, pág. 117). "ra que los jueces simplemente la lean. Por el contrario, al apli-inevitable vaguedad de las palabras y la inevitable limitación car las reglas jurídicas alguien debe asumir la responsabilidad la profundidad intencional hacen que, a menudo, sea imposi-de decidir que las palabras se refieren o no a cierto caso, con establecer si el caso está comprendido o no por el significatodas las consecuencias prácticas que esta decisión implica" de la ley. El caso no es obvio. Es razonablemente posible (Hart, "El positivismo jurídico..." en *Derecho y Moral...*, finir el significado de las palabras de tal manera que los hechos págs. 25-26).

resulten comprendidos por la ley. Pero también es posible Véase también el importante trabajo de Dickinson "The Pro-forma igualmente razonable definir el significado de las pblem of the Unprovided Case", publicado en el Recueil Gény, bras de tal manera que el caso quede fuera del campo de re. II, pág. 503 y sigtes. (Hay traducción castellana publicada rencia de aquélla. La interpretación (en sentido propio, es de en *La Ley*, t. 4, sección doctrina, pág. 32).

como actividad cognoscitiva que solo busca determinar el sig-ficado en tanto que hecho empírico) tiene que fracasar. Po-el juez no puede dejar de cumplir su tarea. Tiene que decidir y esta elección ha de originarse, cualquiera sea su contenido, una valoración. Su interpretación de la ley (en un sentido m-amplio) es, en esta medida, un acto de naturaleza constructi-Hart y John Dickinson. no un acto de puro conocimiento" (Ross, *ob. cit.*, pág. 133).

"Si hemos de comunicarnos de algún modo con los dem-Quarterly Review, vol. 61, julio 1945, págs. 302-3: "He seña-y si, como en el caso de las fórmulas más elementales del derecho ya unas cuantas moralejas en el curso de este apartado, pero

4. LA TEXTURA ABIERTA DEL DERECHO: CONSECUENCIAS (APARTADO II, 3)

Es adecuado citar aquí a tres autores: Glanville Williams, Hart y John Dickinson.

a) Dice el primero en "Language and the Law", *The Law Quarterly Review*, vol. 61, julio 1945, págs. 302-3: "He seña-

b) La idea de que la textura abierta del lenguaje apoyadas en el texto. Si bien las reglas tienen una zona de penumbra — conclusión de que no hay órdenes jurídicos sin lagunas — erra, tienen también un área de incuestionable aplicación. Quien sentido que esta última palabra recibe en el texto — está niega esto, dice Hart, está obsesionado por la penumbra (*ob. cit.* en desarrollos de Hart (ver “El positivismo jurídico”, pág. 40).

separación entre el derecho y la moral", en *Derecho y moral*. c) En "The Problem of the Unprovided Case" (Recueil pág. 35 y 38-39). Véase también Kantorowicz, "La lucha", p. 503) Dickinson hace referencia a la noción corriente de que las reglas jurídicas están ligadas de tal manera que no se puede escapar de ellas. Dickinson, halla expresión en la teoría de que no es necesario salir del derecho existente para fundar la solución de los casos nuevos. En otros términos, que el derecho es completo o auto-suficiente (*ob. cit.*, pág. 507). Para sostener el carácter auto-suficiente del orden jurídico hay que presuponer que sus reglas pueden ser extendidas a casos nuevos mediante analogía y que no nos encontremos con sus contornos borrosos. Aquí hay sin duda exageración, pero hay también una genial consideración de otro tipo (*ob. cit.*, págs. 512 y 517). Cuan-

do se produjo la reacción contra ese modo de ver, y se reaccionó con insistencia que los juristas manejaran conscientemente criterios valorativos que venían usando a ciegas, tanto al seleccionar las premisas como al atribuirles sentido, tuvo lugar, en Dickinson, una llamativa paradoja. Quienes más destacaron la necesidad de esa "apertura" sostuvieron también que los valores materiales debían ser considerados parte del derecho. Ello resultaban víctimas de una vieja presuposición: creer que en la formación del derecho no puede entrar nada que no sea derecho. He aquí, con otro ropaje, el dogma de la auto-suficiencia del sistema jurídico (*ob. cit.*, pág. 521).

Dickinson se resiste a admitir que las pautas o *standards* valorativos que los jueces usan para decidir los casos de la penumbra sean considerados parte del derecho. Da para ello tres razones: primero, que esas pautas carecen de claridad y precisión; segundo, que no están revestidas de autoridad (*ob. cit.*, pág. 522). El intento de aplicar a tales criterios valorativos el concepto de "derecho" sigue dos vías principales: 1) Se procura mostrar que ellos poseen la misma claridad, precisión y autoridad que las normas jurídicas en sentido estricto. Este es el camino que toman algunos neo-jusnaturalistas y algunos militantes del sociologismo jurídico; o 2) Se busca mostrar que las normas jurídicas no tienen claridad ni precisión alguna, sino que son solo las consideraciones o pautas valorativas. Este es el camino que toman los llamados realistas jurídicos, que disuelven el derecho en una masa fluida de factores de todo tipo. (*ob. cit.*, págs. 524-25).

Dickinson advierte que la textura abierta del derecho es una fatalidad para el mito de la auto-suficiencia de éste ("Legal Rules: Their Function in the Process of Decision", 79 *Pennsylvania Law Review* 833, especialmente págs. 851, 853, 862; "Legal Rules: Their Application and Elaboration", 79 *University of Pennsylvania Law Review* 1052, especialmente págs. 1072, 1073 y sigtes., 1084-85, etc.; "The Law behind the law", 29 *Columbia Law Review* 113 y 285, especialmente págs. 117 y 314). Ve que los casos no previstos, o casos de la penumbra, son resueltos por aplicación de criterios valorativos, pero no encuentran ventaja alguna en extender el significado de "derecho" para que engloba esas otras pautas. Finalmente, cree que si se pres-

el sentido restringido de "derecho" —y sin perjuicio de admitir la radical insuficiencia de las reglas que quedan incluidas en él— se hace justicia al hecho de que hay numerosísimos supuestos frente a los cuales las reglas no ofrecen dificultades de interpretación. En otros términos, que los casos de la penumbra son, si puede decirse así, patológicos o anormales, aunque sean frecuentes. (Ver "Legal Rules: Their Function in the Process of Decision", págs. 838, 846-47, "The Law behind the law", pág. 116).

Para un intento reciente de restablecer la auto-suficiencia del orden jurídico injertando en él los criterios o *standards* valorativos que permiten dar solución racional a los casos de la penumbra, ver Ronald Dworkin, "Judicial Discretion", en 60 *Journal of Philosophy* 624 (1963). Dworkin no se hace cargo de las razones que tienen Hart y Dickinson para no dar ese paso.

5. LA POSICION FORMALISTA (APARTADO III, 1)

a. Caracterización.

En "Sul formalismo giuridico" (*Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, N.S.I., 1958, págs. 977-998) Bobbio distingue cuatro significados de "formalismo jurídico": 1) una concepción formal de la justicia (para la que "acto justo es aquel conforme a las leyes e injusto aquel que está en desacuerdo con ellas"; 2) una concepción formal del derecho (que lo "presenta como una forma, generalmente constante, respecto a su contenido, generalmente variable"); 3) una concepción de la ciencia del derecho como ciencia formal (es decir, como un "saber que no tiene por objeto hechos... sino calificaciones normativas de hechos, y cuya tarea no es la explicación, propia de las ciencias naturales, sino la construcción, y, en general, el sistema"; y 4) una teoría formal de la interpretación jurídica (caracterizada por la "preferencia dada a la interpretación lógica y sistemática frente a la histórica y teleológica"). En el texto usamos la expresión "formalismo jurídico" en un sentido afín al significado *sub* 4 de Bobbio, y, parcialmente, al significado *sub* 3, en la medida en que la técnica de la dogmática incide (ilegítimamente) en la praxis jurídica y en la teoría de la interpretación.

Para una esclarecedora explicación del origen de esa actitud ante los problemas jurídicos, véase J. Walter Jones, *Historia de la Introducción a la Teoría del Derecho*, Oxford at the Clarendon Press, Oxford, 1940, caps. I y II, y Max Weber, *Economía y Sociedad* (traducción de Eduardo García Maynez y Eugenio Imaz), Fondo de Cultura Económica, México, 1944, tomo I (Sociología del Derecho), págs. 183-85. En esta obra Weber describe con singular precisión la actitud formalista. Sostiene que ella se traduce en la adhesión a estos cinco postulados:

"1) Toda decisión jurídica concreta representa la 'aplicación' de un precepto abstracto a un 'hecho' concreto; 2) es posible encontrar, en relación con cada caso concreto, gracias al empleo de la lógica jurídica, una solución que se apoye en los preceptos abstractos en vigor; 3) el derecho objetivo vigente es un sistema 'sin lagunas' de preceptos jurídicos, o encierra tal tema en estado latente o, por lo menos, tiene que ser tratado como tal para los fines de la aplicación del mismo a casos singulares; 4) todo aquello que no es posible construir de un modo racional carece de relevancia para el derecho; 5) la conducta de los hombres que forman una comunidad tiene que ser necesariamente concebida como 'aplicación' o 'ejecución' o, por el contrario, como 'infracción' de preceptos jurídicos" (*ob. cit.*, t. I, págs. 26-27). Dentro de ese modo de ver se asigna capital importancia a la sistematización jurídica, que "consiste en reorganizar de tal suerte los preceptos obtenidos mediante el análisis que formen un conjunto de reglas claro, coherente y, sobre todo, desprovisto, en principio, de lagunas, exigencia que necesariamente implica la de que todos los hechos posibles puedan subsumidos bajo alguna de las normas del mismo sistema, pues de lo contrario, éste carecería de su garantía esencial" (*ob. cit.*, t. III, pág. 25).

b. Formalismo y positivismo jurídico.

La posición que en el texto llamamos "formalismo" suele ser caracterizada como una variedad de positivismo jurídico. La última expresión es altamente imprecisa; se la usa para designar a diferentes ideas o concepciones que no tienen entre sí

ninguna relación necesaria. El intento más fecundo de clarificación es el de Hart ("El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral", en *Derecho y moral: Contribuciones a su análisis*, págs. 1-64). Allí se expresa que uno de los significados de "positivismo" se identifica con la pretensión de que "un sistema jurídico es un 'sistema lógicamente cerrado' en el que las decisiones... correctas pueden ser deducidas por medios lógicos de normas jurídicas predeterminadas, sin referencia a propósitos sociales, líneas de orientación, *standards* morales, etc." (*ob. cit.*, pág. 16, nota 25, 4). Hart hace un penetrante análisis de lo que cabe entender por "formalismo" y de las relaciones que, se pretende, vinculan aquella actitud con la de pensadores positivistas (véase, además, *El concepto de derecho*, págs. 161-2).

También Bobbio dice cosas importantes y esclarecedoras en su trabajo "Sul positivismo giuridico", en la *Rivista di Filosofia*, LIII, 1961, págs. 14-34 (Hay traducción francesa publicada en *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, Dalloz, Sirey, París, 1961, tomo I). Distínguese allí tres significados de "positivismo jurídico", o, como prefiere decir Bobbio, tres aspectos de las corrientes confusamente identificadas bajo ese rótulo ambiguo: 1) "El positivismo jurídico como modo de acercarse al estudio del derecho" (desde esta perspectiva "positivismo jurídico" se opone a *jusnaturalismo*); 2) El positivismo jurídico como teoría "que vincula el fenómeno jurídico a la formación de un poder soberano capaz de ejercitar la coacción: el estado", o "teoría estatal del derecho" (desde esta perspectiva el positivismo jurídico aparece contrapuesto al sociologismo o al realismo); y 3) "El positivismo jurídico como ideología", que "confiere al derecho que es, por el solo hecho de existir, un valor positivo" (esta ideología es lo que Alf Ross denomina *cuasi-positivismo*, y lo opone al positivismo genuino; ver el artículo del jurista danés "El concepto de validez y el conflicto entre el positivismo jurídico y el derecho natural", publicado en la *Revista Jurídica de Buenos Aires*, 1961, IV, págs. 47-91 (traducción de Genaro R. Carrió y Osvaldo Pascherero)).

Lo que en el texto llamamos formalismo es una variedad exacerbada de positivismo jurídico en el sentido *sub 2* de Bobbio,

o, si se prefiere, es la actitud que resulta de poner un desmedido énfasis en ciertas facetas del aspecto *sub 2* distinguido por aquí. En relación con esto Bobbio hace notar que a “ese segundo aspecto del positivismo jurídico, es decir a la concepción estatal del derecho, están vinculadas algunas conocidas teorías que a menudo son consideradas como características del positivismo jurídico: . . . 3ª) con respecto a las fuentes del derecho, la supremacía de la ley sobre las otras fuentes. . . 4ª) con respecto al orden jurídico en su conjunto, la consideración del complejo de las normas como sistema al que se atribuye el carácter de plenitud o de ausencia de lagunas y, subordinadamente, también la coherencia o ausencia de antinomias; 5ª) con respecto al método de la ciencia jurídica y de la interpretación, la consideración de la actividad del jurista o del juez, como actividad esencialmente lógica, particular, la consideración de la ciencia jurídica como método hermenéutico (escuela francesa de la exégesis) o como dogmática (escuela pandectista alemana)”. Estas teorías entre sí complementarias caracterizan lo que en el texto llamamos formalismo (ver la coincidencia con el punto de vista de Max Weber, reproducido *supra*, en esta misma nota). Del mismo Bobbio véase también “Ancora sul positivismo giuridico”, en *Rivista di Filosofia*, LIII, págs. 335-45. Los tres artículos del jurista italiano que he mencionado en esta nota han sido traducidos al castellano por Ernesto Garzón Valdés, junto con un cuarto —“Giusnaturalismo e positivismo giuridico”, *Rivista di diritto civile*, VIII, 1960, págs. 503-515— para ser publicados en forma de libro bajo el título *El problema del positivismo jurídico*. Agradezco a Garzón Valdés haberme facilitado su traducción; las citas que anteceden están tomadas de ella.

c. Formalismo y jurisprudencia de conceptos.

En ocasión de sus conferencias en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Alf Ross resumió las principales tesis sostenidas por pensadores identificados como positivistas y, entre ellas, destacó la llamada “concepción mecanicista de la función judicial” (nuestro “formalismo”). Distinguió, además, seis corrientes principales dentro de lo que tradiciona-

mente se llama “positivismo jurídico”; una de ellas es la jurisprudencia de conceptos alemana, cuyos cultores más notables han sido, amén del primer Ihering, Windscheid, Merkel, Laband, Binding, etc. (Ver Genaro R. Carrió, “Nota sobre la visita de Alf Ross”, en *Revista Jurídica de Buenos Aires*, 1960, IV, págs. 205-20). Del mismo Ross véase también el importante artículo “El concepto de validez y el conflicto entre el positivismo jurídico y el derecho natural” citado más arriba.

La jurisprudencia de conceptos “reducía al juez a la función de subsumir hechos bajo conceptos jurídicos. De acuerdo con ello, el orden jurídico fue concebido como un sistema . . . ‘completo’ . . . deductivo o analítico. De los conceptos generales provenían conceptos especiales; de los conceptos surgían, por deducción lógica, las reglas jurídicas aplicables a los hechos. Se enseñaba, por lo tanto, que la determinación de conceptos causales permitía a los juristas establecer nuevas reglas. El sistema llegó a ser considerado como una fuente inagotable de ‘material nuevo’. Se entendía que la función de la ciencia jurídica era extraer conceptos causales de las reglas jurídicas establecidas, definir con precisión o, para usar la expresión técnica, ‘construir’ esos conceptos, y erigir con ellos un sistema completo que, a su vez, produjera nuevas reglas. Aun cuando en realidad una regla fuera descubierta con la ayuda de consideraciones prácticas, se pensaba que era necesario representarla como lógicamente derivada de un concepto” (Heck, “The formation of concepts and the jurisprudence of interests”, en *The Jurisprudence of Interests*, citado en nota 1. El párrafo transcripto está en las págs. 102-103).

El método empleado para alcanzar esos resultados era el de la “construcción”. Al aplicarlo se usaba abusivamente de los conceptos clasificatorios —cuya finalidad legítima es expositiva o de presentación— y se los hacía servir como punto de arranque o como base para la deducción de nuevas reglas (Heck, *ob. cit.*, págs. 111, 149 y 153). Esta forma de proceder es llamada por Heck “método de inversión” (*ob. cit.*, págs. 157 y 172-73), o “método jurídico conceptualista”.

La función del juez queda reducida, como dijimos, a “aplicar el derecho, subsumiendo un conjunto dado de hechos bajo

conceptos jurídicos". "Estaba fuera de lugar pensar en una valoración del juez. Se hablaba, en consecuencia, de la aplicación del derecho como de 'un cálculo de conceptos'... "El orden jurídico era considerado 'completo' o 'pleno'... Todo cuanto deba hacer el juez era 'percibir' o 'entender' reglas de derecho... (Heck, *ob. cit.*, pág. 171).

El primer desarrollo coherente de esta actitud metodológica está en Ihering, *El espíritu del Derecho Romano*. En el volumen *La dogmática jurídica* (Ed. Losada, Buenos Aires, 1946) se incluyen los pasajes de esa obra que tienen más interés desde este punto de vista. Véanse, en especial, págs. 28-35, 108 y siguientes, 128, 131 y siguientes, 151-57, etc.

Véase, además, Antonio Hernández-Gil, *Metodología del Derecho*, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1945, cap. IV, "Métodos dogmáticos y constructivos (Positivistas, Formalistas)", págs. 101-47. Cf. también Julius Stone, *The Province and Function of Law*, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1950, págs. 160-62. Para una apreciación de tipo crítico véase el excelente libro de José Puig Brutau, *La jurisprudencia como fuente del derecho*, Bosch, Barcelona, s/f, especialmente cap. I, 3.

6. REACCIONES MODERADAS CONTRA EL FORMALISMO (APARTADO III, 2)

Véase W. Friedmann, *Legal Theory*, 4ª edición, Stevens Sons Ltd., Londres, 1960, págs. 277-80 (sobre Ihering como fundador de la jurisprudencia sociológica), págs. 284-88 (sobre Gény), págs. 289-93 (sobre la jurisprudencia de intereses), págs. 293-99 (sobre la "ingeniería social" de Pound, Cardozo, etc.). Cf. también, Julius Stone, *ob. cit.* en nota 5, págs. 299-301 y 649-51 (sobre el Ihering antiformalista), págs. 151-69 (sobre el aporte crítico de Gény), págs. 164-65 (sobre la jurisprudencia de intereses). El libro de Stone es un intento de desarrollar los puntos de vista de Pound. Ver igualmente Hernández-Gil, *ob. cit.* en la nota 5, págs. 174-183 (sobre Ihering como revisor de los métodos dogmáticos), págs. 205-31 (sobre Gény y la llamada escuela científica francesa), págs. 271-77 (sobre la jurisprudencia

de intereses). El libro de Hernández-Gil, que en otros aspectos es muy completo, carece de toda referencia a la teoría jurídica anglo-sajona.

Véase, además:

1) Ihering, *Der Zweck im Recht*, dos tomos (1877 y 1884); (hay traducción castellana del primer tomo, hecha por Adolfo Posada, *El fin en el Derecho*); *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz*, 1884 (hay traducción castellana de Roman Riaza, *Jurisprudencia en broma y en serio*); Dino Passini, *Saggio sul Ihering*, Ed. Giuffrè, Milán, 1959, con exhaustiva bibliografía.

2) Gény, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, 1899 (hay traducción castellana publicada por la Editorial Reus, Madrid, 1925, 2ª edición); *Science et Technique en droit privé positif*, Sirey, París (1923-24).

3) Sobre la jurisprudencia de intereses, véase el volumen *The Jurisprudence of Interests*, citado en la nota anterior, que contiene trabajos de Max Rümelin, Philipp Heck, Paul Oertmann, Heinrich Stoll, Julius Binder y Hermann Isay; cf. también Heck, *El problema de la creación del derecho* (traducción de Manuel Entenza), Ariel, Barcelona, 1961.

4) Pound, "The scope and purpose of sociological jurisprudence", 24 *Harvard Law Review*, 591 y 25 *idem* 140 y 489; "A survey of social interests" 57 *Harvard Law Review* 1 (hay traducción española de Alberto Ciria, *Examen de los intereses sociales*, Perrot, Buenos Aires, 1959); *Interpretations of Legal History*, 1923 (libro traducido al castellano por José Puig Brutau bajo el título de *Las grandes tendencias del pensamiento jurídico*, Ariel, Barcelona, 1950); *An Introduction to the Philosophy of Law*, edición revisada, Yale University Press, New Haven, 1954; etc. Véase, además, el estudio preliminar de Puig Brutau a *Las grandes tendencias...*, citado más arriba, con abundante bibliografía; Cardozo, *La naturaleza de la función judicial* (traducción de Eduardo Ponssa y prólogo de Cossio). Arayú, Buenos Aires, 1955; *The Growth of the Law*, Yale University Press, New Haven, 1924; *The Paradoxes of Legal Science*, Columbia University Press, New York, 1928.

7. REACCIONES EXTREMAS CONTRA EL FORMALISMO (APARTADO III, 2)

a. La escuela o movimiento del derecho libre. Cfr. Storob. cit. en la nota 4, págs. 164 y 745 y sigs.; Friedmann, *ob. cit.* págs. 299-301, 250-51, 258 etc.; Gnaeus Flavius (Hermann Kantorowicz) *La lucha por la ciencia del derecho* (traducción castellana de Werner Goldschmidt) en el volumen *La ciencia del derecho*, Losada, Buenos Aires, 1949, págs. 323-371; Ehrlich *Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft* (traducido parcialmente al inglés en el tomo IX de las Modern Legal Philosophy Series, *The Science of Legal Method*).

b. El realismo jurídico norteamericano. Véase el excelente libro de Giovanni Tarello, *Il realismo giuridico norteamericano*, Ed. Giuffrè, Milán, 1962 y la abundante bibliografía citada en él; véase igualmente Puig Brutau, *La jurisprudencia...*, cap. I. El expositor más lúcido y más contenido, dentro de los "realistas" es, sin duda, F. S. Cohen, *El método funcional en el derecho*, traducción de Genaro R. Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1962. Para una presentación general de las circunstancias culturales dentro de las que apareció este movimiento, consulte Morton White, *Social Thought in America, (The Revolt against Formalism)*, Beacon Press, Boston, 1957.

Para una crítica certera al "realismo" jurídico norteamericano, véase Hart, *El concepto de derecho*, cap. VII, y Dickenson, trabajos citados en la nota 4.

8. UNA CRÍTICA A FORMALISTAS Y REALISTAS (APARTADO V)

"La creencia errónea en un sistema completo de reglas que puedan hacerse cargo por anticipado de todos los casos de duda subyace también a mucha confusión filosófica. Así, se tiene la sensación de que una regla que deja áreas sin determinar no es en realidad una regla, aunque sea imposible satisfacer el requerimiento de reglas que lo contemplen todo" (Lloyd, *Introducción to Jurisprudence*, pág. 209, nota 26).

Véase especialmente Wittgenstein, *Philosophical Investigations*,

tions, parágrafos 68, 84, 99 y 100. Dice Pole, *The late philosophy of Wittgenstein*, 1958, pág. 33: "Una regla está propiamente formulada cuando cumple su función en el contexto para el que fue concebida. Nuestro error radica en pretender reglas perfectas y completas".

He aquí otro ejemplo de la aceptación del falso dilema por un jurista incurso en formalismo: "El problema consiste en elegir entre dos posibilidades: una regla fija, que quizás a veces no concuerde en todo con el propósito de que el ciudadano puede regirse y ser regido por ella, o una valoración de intereses inconstante e imprevisible, por obra del juez" (von Thur, *Derecho Civil*, tomo I, Prefacio, pág. 5). He tomado esta cita del ensayo del Dr. Orgaz, "El problema de la interpretación de la ley", incluido en *Nuevos estudios de Derecho Civil*, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1954, págs. 298 y sigs. El Dr. Orgaz parece aceptar la idea de von Thur.

TERCERA PARTE

SOBRE LOS DESACUERDOS ENTRE LOS JURISTAS

Me ocuparé ahora de las controversias o desacuerdos entre los juristas, en la medida en que tales discrepancias están relacionadas con problemas del lenguaje. Por razones de precisión terminológica quiero aclarar que uso aquí la palabra "juristas" en un sentido amplio: ella comprende no sólo a los cultores de la dogmática jurídica, sino también a los teóricos del derecho político y a los filósofos del derecho.

La relación que existe entre aquellos desacuerdos y los problemas del lenguaje es muy grande; mucho más de lo que de ordinario advertimos. Hasta se podría decir, sin pecar de exageración, que la mayor parte de las agudas controversias que, sin mayor beneficio, agitan el campo de la teoría jurídica, deben su origen a ciertas peculiaridades del lenguaje y a nuestra general falta de sensibilidad hacia ellas.

Comenzaré señalando algunas cosas generales, muchas de las cuales han sido expresadas, presupuestas y/o sugeridas en la primera parte.

I. GENERALIDADES: RECAPITULACION

a) Todo lenguaje es un sistema o conjunto de símbolos *convencionales*. Esto último quiere decir que no hay ninguna relación necesaria entre las palabras, por un lado, y, por el otro, los objetos, circunstancias, hechos o sucesos, en relación con los cuales aquéllas cumplen sus múltiples funciones. La convención que acuerda a una palabra o expresión una función determinada

puede ser explícita y *ad hoc*, como ocurre en el caso de un lenguaje artificial cualquiera, o tácita y general, como ocurre en el caso de los lenguajes naturales.

b) El "significado" de una palabra o expresión lingüística depende, por lo tanto, de una convención. Definir una palabra es hacer explícitas las reglas de uso de la misma, esto es, decir para qué sirve, y señalar cuáles son las oportunidades, circunstancias o fenómenos en presencia de los cuales es "correcto" — según esas reglas de uso — valerse de la expresión definida. Tal reglas pueden ser más o menos precisas.

Alcanzan su precisión máxima en las ciencias formalizadas. Allí la regla de uso incluye un conjunto de condiciones siempre necesarias y suficientes para el empleo de la palabra, cualquiera sea el contexto en que ella aparezca. De ese modo, los objetos a que la misma se aplica constituyen una clase rígida e inequívocamente delimitada.

Ya vimos que no es así como se usan y definen las palabras de que nos valemos en los lenguajes naturales para hacer referencia a los fenómenos de la realidad. Decir esto, y afirmar que las palabras son actual o potencialmente vagas, o que el lenguaje exhibe una irremediable textura abierta, es, para estos fines, decir la misma cosa.

Si la palabra es *vaga*, cualquier definición que intente recoger con fidelidad sus reglas de uso en vigor, tendrá por fuerza que recoger la imprecisión de la palabra definida. Si por alguna razón particular deseamos dar a la palabra una precisión que ella no tiene (por ejemplo: "para estos fines definiremos 'ciudad' como todo conglomerado humano de más de 60.000 habitantes"), entonces estamos haciendo una cosa distinta de lo que hacemos cuando nos limitamos a recoger el significado que la palabra tiene según los usos lingüísticos vigentes. Ahora estamos *estipulando* un significado o, si cabe la expresión, legislando una *nueva* regla de uso, de aplicación circumscripta.

c) Las definiciones del primer tipo son llamadas *léxicas*. Ellas describen, en forma resumida, un uso lingüístico vigente, y, pueden ser calificadas, por lo tanto, de verdaderas o falsas. Tal es el caso, por ejemplo, de las definiciones de los diccionarios corrientes.

Las otras, es decir, aquellas que delimitan para ciertos fines el campo de acción de una palabra vaga, o se deciden por uno de los significados múltiples de una palabra ambigua o, más típicamente, *introducen* un *nuevo* símbolo en reemplazo de una descripción (por ejemplo "llamaremos 'cinerama' a este nuevo sistema de filmación y proyección de películas, que presenta tales características"), esas otras definiciones son llamadas *estipulativas*. Ellas carecen de valor de verdad; podrán ser útiles o inútiles, cómodas o incómodas, pero no son verdaderas ni falsas. No son aserciones, sino *decisiones* lingüísticas.

Uno y otro tipo de definición, por lo tanto, son definiciones *de palabras*. Proporcionan algo así como una traducción del símbolo verbal o, mejor aún, un compendio de las reglas de su uso, vigentes o propuestas. Se ha hablado tradicionalmente, y se sigue hablando, de un tercer tipo de definiciones, las llamadas "definiciones reales". Esto es, no definiciones de palabras, sino de "cosas". Pero ese modo de hablar es fuente de numerosos equívocos, que nos demorarán más adelante.

d) La tarea de definir léxicamente —vale decir, de explicar reglas de uso vigentes o, en otros términos, de expresar el significado o significados vigentes de una palabra— no sólo tropieza con la dificultad de la indeterminación o textura abierta del lenguaje, ya aludida. Tropieza con muchas más. Me interesa aquí volver a destacar dos de ellas:

1) Por un lado, el hecho de que una misma palabra puede tener significados radicalmente distintos, o poseer un significado central y extensiones figurativas o metafóricas de fácil comprensión, o ser aplicable a una familia de diversos objetos, hechos, situaciones, etc., que no poseen propiedades en común. La presencia de propiedades comunes no es el único justificativo para usar una misma palabra en relación con distintos objetos individuales. Estos pueden exhibir un "parecido de familia", o hallarse vinculados de modos muy diversos a un caso central, etcétera.

2) La otra dificultad es que muchas palabras tienen además de significado o significados descriptivos, un *significado emotivo*. Esto es, una disposición permanente para provocar ciertas reacciones anímicas en quienes las oyen o leen, unida a

cierta aptitud permanente para constituirse en vehículos mediante los cuales quienes las usan dejan escapar, por decir así, sentimientos. Hay palabras que prácticamente no tienen otro significado que el descriptivo; otras un significado puramente emotivo; y en el medio, palabras que exhiben una variadísima gama de combinaciones de uno y otro ingrediente. El significado emotivo puede quedar atenuado, o aun cancelado, por el contexto. Otras veces puede operar en forma encubierta. De allí la enorme flexibilidad y riqueza del lenguaje persuasivo.

En el curso de esta recapitulación preliminar he destacado algunas características del lenguaje, a cuyo olvido o ignorancia puede atribuirse el carácter aparentemente insoluble de muchas controversias entre juristas. Porque sucede que al participar en la disputa estos suelen pasar por alto algunas de las siguientes cosas —muy ligadas entre sí— o todas ellas:

1) Las palabras no tienen otro significado que el que se les da (por quien las usa, o por las convenciones lingüísticas de la comunidad). No hay, por lo tanto, significados “intrínsecos”, “verdaderos” o “reales”, al margen de toda estipulación expresa o uso lingüístico aceptado. Es vana la tarea de “descubrir” tales significados inexistentes; por esa vía no es dable alcanzar ninguna información valedera.

2) Es una ilusión la de que a cada palabra le corresponde un significado y sólo uno; la gran mayoría de ellas tiene pluralidad. También es ilusoria la creencia de que el uso de una misma palabra para denotar objetos diversos presupone necesariamente —salvo los casos de mera homonimia— que todos esos objetos tienen una propiedad o un conjunto de propiedades en común, que integran o componen una entidad que la palabra nombra. El hecho de que estamos usando una misma palabra no garantiza que nos estamos refiriendo a la misma cosa. Suele ser esclarecedor, empero, el esfuerzo por desentrañar la regla tácita —si la hay— que rige el uso de la palabra común.

3) No puede hablarse, por lo tanto, sin grave riesgo de equívocos, de dar “definiciones reales”, o de “describir el significado intrínseco o esencial de un término o expresión”, o de “determinar la naturaleza de la entidad designada por la palabra

Es verdad que los hombres hemos pretendido, y seguimos pretendiendo, hacer estas cosas, pero también lo es que al amparo de estos rótulos oscuros se hacen muchas cosas distintas, que no deben ser confundidas. De lo contrario se multiplican los equívocos, favorecidos por la ambigüedad, no siempre advertida, de preguntas tales como “¿Qué es democracia?” “¿Qué es usufructo?” o “¿Qué es derecho?”.

4) Es verdad que quien se vale de una palabra apartándose del significado usual que en contextos análogos ella recibe, o escogiendo como único aceptable uno de los significados usuales con exclusión de los otros, corre el riesgo de que los demás no lo entiendan, o lo entiendan mal, si no hace explícita la estipulación o ella no resulta del contexto. Pero tal estipulación no puede ser calificada de verdadera ni de falsa, y, por lo tanto, no puede ser probada ni refutada mediante la invocación de hechos. Tampoco pueden serlo los enunciados que se derivan directamente de ella.

5) No todas las palabras u oraciones se usan exclusivamente para describir. Otras se usan, además (o únicamente), para recomendar, aprobar o desaprobar, o, también, para llamar la atención sobre algo previamente desatendido colocándolo, por decir así, en un sorpresivo primer plano que destaca su importancia.

II. DISTINTOS TIPOS DE DESACUERDO

Veamos ahora en qué medida las discrepancias o desacuerdos de los juristas son tributarios de inadvertencias respecto de esas cosas.

1. SEUDO-DISPUTAS ORIGINADAS EN EQUIVOCOS VERBALES

Se suele creer —y los teóricos del derecho no somos inmunes a tal creencia— que cada palabra tiene un significado intrínseco o propio, que no puede ni debe confundirse con las extensiones que la licencia lingüística pretende añadirle. Esto tie-

ne graves consecuencias. Empezamos preguntando por el significado de la palabra "derecho" (dando por sentado que sólo uno es legítimo), y de allí hay un solo paso —y muy breve— la pregunta por la "naturaleza" o la "esencia" del Derecho, pregunta que sólo puede ser contestada —presuponemos— describiendo las características de la entidad en que el significado de la palabra "derecho" consiste. Todo ello se ve favorecido por la ambigüedad de la pregunta "¿Qué es derecho?", en que no está claro si estamos pidiendo se nos indique el significado (o significados) de la palabra "derecho", o que se nos describan las propiedades o características típicas de los fenómenos usualmente designados con ella, o alguna otra cosa.

Pero es el caso que la palabra "derecho" tiene muchos significados, no uno solo. Para que cualquier discusión sobre las características de los fenómenos designados por ella sea una ruina discrepancia —y no el fruto de un simple equívoco verbal— tiene que mediar *acuerdo previo* sobre el significado que la disputa, damos a las palabras claves.

Porque de lo contrario puede ocurrir que uno de los antagonistas las use en un sentido, y el otro en un sentido diferente. En tal caso, aunque las propiedades que atribuyan a los objetos de que uno y otro hablan sean absolutamente incompatibles, habrá entre ellos ninguna contradicción. Sólo habrá una ilusión de contradicción. Es inútil que nos pongamos a discutir sobre las características que tiene o deja de tener "el derecho", si previamente no nos ponemos de acuerdo sobre cuál de los sentidos de la multívoca palabra está en juego. Sería tan absurdo como ponerse a discutir fervorosamente si Carlos Gómez es o no jubilado ferroviario, sin tomar previamente la precaución de averiguar si estamos hablando del mismo Carlos Gómez.

Todo esto parece trivial, pero es el caso que hay muchas controversias entre juristas que tienen ese origen, y, constituyen por lo tanto, monumentos a la esterilidad. Para evitar que ocurra hay que observar esta precaución obvia: no embarrarse nunca en una discusión sin estar absolutamente seguros de cuál es el sentido con que nuestro oponente está usando las palabras claves.

2. SEUDO-DESACUERDOS DE HECHO EN TORNO A PROPOSICIONES ANALÍTICAS

Supongamos que siguiendo el consejo antedicho hemos llegado a precisar en qué sentido nuestro contendor usa una palabra o expresión ambigua. El es un jurista naturalista y usa la expresión "orden jurídico" con el sentido de "régimen normativo coactivo, compuesto de reglas intrínsecamente justas". Supongamos, además, que en el curso de su exposición nuestro contendor afirma: "todos los órdenes jurídicos son justos". Supongamos, por último, que yo, que en la hipótesis soy un jurista convencido, quiero *refutar* esa apreciación, que me parece falsa, o, por lo menos gruesamente exagerada.

Pues bien, si no me hago cargo exactamente de la situación, es muy probable que todos mis esfuerzos dialécticos sean estériles, pues cada vez que señale a mi adversario ejemplos de órdenes coactivos injustos, su respuesta será la misma: "Sí, pero eso no es un orden jurídico". Y si le pregunto por qué no lo es, me contestará lisa y llanamente, "porque es injusto".

Su enunciado, por lo tanto, resulta irrefutable. No tengo manera de probar la falsedad de lo que ha dicho, mientras él siga coherentemente refugiado en la definición que le sirve de inexpugnable fortaleza. ¿Cómo es posible esto? La respuesta es simple: el enunciado de ese tipo *no puede* ser refutado alegando hechos contrarios, por la sencilla razón de que no es una aserción de hecho; ese enunciado no nos suministra *ninguna información* sobre los fenómenos del mundo.

Solo es síntoma o indicio de cómo usa la expresión "orden jurídico" mi interlocutor. Pero nos dice tan poco sobre el mundo como un enunciado del tipo de "todos los gatos negros son negros". La diferencia con enunciados de este último tipo es puramente externa, y radica en que "todos los órdenes jurídicos son justos" no exhibe, a primera vista, su carácter tautológico. Este sólo se hace presente cuando advierto que mi adversario usa la expresión "orden jurídico" con el sentido de "orden coactivo justo". Mientras tal cosa no se advierte, "todos los órdenes jurídicos son justos" se parecerá mucho a "todos los órdenes jurídicos penan el homicidio", proposición que no es tautológica,

siempre que esté dispuesto a reconocer que es falsa si alguien señala un orden jurídico donde no esté penado el homicidio más claramente, siempre que no me niegue a aplicar el rótulo "orden jurídico" a un sistema coactivo que no pena el homicidio o para ser más claro aún, siempre que mi definición de "orden jurídico" sea *independiente* de que el orden normativo en cuestión castigue o no el homicidio.

Muchas disputas entre juristas se originan y perduran no advertir estas cosas. Se pretende refutar y apoyar enunciados que sólo explicitan parte de la definición de un término apelando para uno y otro fin, a argumentos de hecho. Claro está que esta disputa resulta así mal encaminada y la situación parece no tener salida. ¿Significa ello que frente a un enunciado del tipo de "los dos órdenes jurídicos son justos" puesto en boca de un jurista, no tenga más alternativa que limitarme a decirle "Bueno, eso es una mera tautología resultante de su decisión previa de reservar el rótulo 'orden jurídico' para los órdenes justos"? Esto puede ser una manera rápida de poner fin a una conversación fastidiosa, pero no es, claramente, la única alternativa.

Porque siempre cabe la posibilidad de argumentar acerca de las *desventajas* de una definición que hace depender la aplicación de una palabra de un determinado criterio en cierto modo subjetivo; o siempre cabe sostener que tal limitación del uso del "orden jurídico" divide artificialmente un campo que, por razones de *conveniencia teórica*, es *preferible* mantener unido, o que las características estructurales son lo suficientemente analogas y los puntos de analogía lo suficientemente importantes como para que la ciencia se *beneficie* con un tratamiento unificado de problemas similares. Son muchas las razones de este tipo o de tipo semejante que cabe dar, pero todas ellas tienen carácter valorativo (teórico o práctico) y ninguna de ellas fuerza conclusiva.

3. DISPUTAS SOBRE CLASIFICACIONES

Otras veces las discrepancias entre los juristas presuponen una creencia errónea sobre el papel o función que desempeñan las clasificaciones. Este es un vicio que no es privativo de

juristas, pero que asume entre ellos rasgos particularmente nocivos.

Tal vez ello se deba a que la teoría jurídica se maneja, en casi todos sus sectores, con clasificaciones heredadas, muchas de las cuales traen el aval de un enorme prestigio y de una tradición milenaria. Los juristas creen que esas clasificaciones constituyen la *verdadera* forma de agrupar las reglas y los fenómenos, en lugar de ver en ellas simples instrumentos para una mejor comprensión de éstos. Los fenómenos —se cree— deben acomodarse a las clasificaciones y no a la inversa.

Buena parte de las controversias entre juristas consisten en problemas de clasificación, abordados como si se tratara de cuestiones de hecho. No se advierte que no tiene sentido refutar como "falsa" una clasificación —o sus resultados— y postular en su reemplazo otra "verdadera", como si se tratara de dos modos excluyentes de reproducir con palabras ciertos parcelamientos y subdivisiones que están en la "naturaleza de las cosas".

Las clasificaciones no son ni verdaderas ni falsas, son *serviciales* o *inútiles*; sus ventajas o desventajas están supeditadas al interés que guía a quien las formula, y a su fecundidad para presentar un campo de conocimiento de una manera más fácilmente comprensible o más rica en consecuencias prácticas deseables.

Siempre hay múltiples maneras de agrupar o clasificar un campo de relaciones o de fenómenos; el criterio para decidirse por una de ellas no está dado sino por consideraciones de *conveniencia* científica, didáctica o práctica. Decidirse por una clasificación no es como preferir un mapa fiel a uno que no lo es. Porque la fidelidad o infidelidad del mapa tiene como *test* una cierta realidad geográfica, que sirve de tribunal inapelable, con sus ríos, cabos y cordilleras reales, que el buen mapa recoge y el mal mapa olvida. Decidirse por una clasificación es más bien como optar por el sistema métrico decimal frente al sistema de medición de los ingleses. Si el primero es preferible al segundo no es porque aquél sea verdadero y éste falso, sino porque el primero es más cómodo, más fácil de manejar y más apto para satisfacer con menor esfuerzo ciertas necesidades o conveniencias humanas.

Las disputas clasificatorias de los juristas pueden ser interminables si en lugar de allegar argumentos valorativos en favor de un modo de clasificar, los contendores se empeñan en mostrar que la clasificación propia —y no la ajena— refleja la verdadera “naturaleza de las cosas”, o es la única clasificación compatible con la “esencia” de los objetos clasificados. Mucho tiempo y mucha tinta se habrían ahorrado con sólo recordar cosas tan simples.

4. CONTROVERSIAS SOBRE LA “NATURALEZA JURIDICA” DE UNA INSTITUCION

Hay otro tipo de discrepancias, directamente conectadas con las anteriores, que se originan en algo que parece ser una enfermedad profesional de nuestro gremio. Me refiero a la proclividad a pesquisar la llamada “naturaleza jurídica” de una institución de un hecho o de una relación que preocupa a los juristas, y a la facilidad con que éstos entran en polémicas sobre el punto. Sin embargo, no se trata de una debilidad peculiar de los juristas, sino que de algún modo responde a una inclinación general, derivada a su vez —en sus formas no legítimas— de falta de seriedad frente a problemas de tipo lingüístico.

Muchas veces cuando, en contextos no jurídicos, preguntamos “¿Qué es X?”, esta pregunta ambigua no busca, como en otros casos, una definición de la palabra “X”, ni una descripción de la cosa X, ni un encasillamiento de ella respecto de una particular propiedad que tenemos tácitamente en mira. Lo que buscamos es una *clave* que nos brinde el acceso a todos los hechos relevantes acerca del objeto X en una fórmula breve. En otros términos, pedimos que se nos destaque un hecho acerca de la cosa X del que se pueda deducir todo lo que es verdad respecto de ella. Así, para valarme de un ejemplo de Richard Robinson —a quien sigo en esta parte— cuando preguntamos “¿Qué es el Cristianismo?”, o “¿Cuál es la esencia del mensaje de Cristo?” esperamos que se nos dé una respuesta breve, quizás una so-

¹ *Definition*, Oxford University Press, Oxford, 1954, pág. 163.

máxima, de la que puedan derivarse todas las enseñanzas de Jesús.

Buscamos —dice Robinson— una especie de llave única para un gran edificio. Tal cosa, posible en la geometría, no se puede conseguir siempre. Esas supuestas definiciones claves tienen que incluir, o presuponen, una decisión estipulativa. Porque “es muy improbable —dice nuestro autor— que alguna definición o fórmula breve pueda generar afirmaciones verdaderas acerca de todos los tipos de fenómenos efectivamente cubiertos por el uso común de la palabra, ya que es muy improbable que la palabra cubra un campo totalmente homogéneo”.

Es eso lo que buscan los juristas, me parece, cuando tratan de hallar, por encima o por detrás de las reglas positivas del sistema, en cierto campo o sector, la “naturaleza jurídica de una determinada institución”. De allí brotan en tropel una multitud de teorías encontradas. Las pesquisas y las polémicas suelen estar, desde el comienzo, envueltas por una espesa maraña de confusión acerca del verdadero alcance de la tarea que se cumple y de los desacuerdos que sus distintos resultados originan. En ciertos casos, parece imposible alcanzar claridad o avenimiento. Y ello, porque no sabemos bien qué es lo que quiere decir la afirmación: “Tal es la naturaleza jurídica del concordato”, ni sabemos bien en qué consiste precisamente la discrepancia cuando otro nos refuta “No, la naturaleza jurídica del concordato no es esa sino esta otra”, ni tampoco sabemos bien cuál es el criterio para decidimos por una de las dos afirmaciones discrepantes.

Hace algunos años escribí estas palabras, quizás un poco duras, que vienen ahora al caso ².

Las afanosas pesquisas de los juristas por “descubrir” la naturaleza jurídica de tal o cual institución o relación están de antemano y en forma irremisible destinadas al fracaso. Entre otras razones, porque lo que se busca, tal como se lo busca, no existe.

Al preguntarse por la “naturaleza jurídica” de una institución cualquiera los juristas persiguen este imposible: una justificación

² Prólogo a la excelente monografía de Eugenio Bulygin, *Naturaleza jurídica de la letra de cambio*, Abeledo-Perrot, 1961.

NATURALEZA JURIDICA, INTERROGANTE
ESTÉRIL.

ficación *única* para la solución de todos los casos que, ya en forma clara, ya en forma imprecisa, caen bajo un determinado conjunto de reglas. Es decir, aspiran a hallar un último criterio de justificación que valga tanto para los casos típicos como para los que no lo son. Por supuesto que no hay tal cosa. El fin de ella, sin embargo, no obedece meramente a un obstinado capricho. Varios factores ayudan a explicar el fenómeno:

a) El deseo de los juristas de procurarse una *guía* para resolver aquellos casos cuya solución no puede extraerse de las normas del sistema;

b) El deseo —muchas veces no consciente— de conseguir el propósito expresado sin abdicar de estas dos ideas, que definen cierta forma de positivismo jurídico: 1) el orden jurídico es completo, no tiene lagunas: las soluciones de *todos* los casos concretos pueden ser deducidas de las normas del sistema, siempre que sepamos integrar a éstas con una adecuada captación de la naturaleza jurídica de las figuras que aquéllas diseñan; 2) no se puede de buena ley fundar la decisión frente al caso concreto en las consecuencias de adoptar tal o cual solución;

c) El deseo de hallar un punto de partida incontestable para la ulterior tarea de clasificación y sistematización;

d) En cierta medida, el deseo de emparentar las instituciones de aparición reciente con otras de linaje ilustre, atenuando así el choque de la novedad mediante su absorción por un modo familiar de ideas ya elaboradas.

La conclusión que entonces aventuré fue ésta: no es prudente hablar de la "naturaleza jurídica" de tal o cual institución, ya que ello, si bien contribuye a preservar la ilusión de que el orden jurídico es autosuficiente, lo hace al alto precio de proporcionar una guía inadecuada para la solución de los casos difíciles y una base poco fructífera de sistematización.

A ello quiero agregar ahora que las discusiones sobre las puestas naturalezas jurídicas, en cuanto los contendores hacen claramente cargo de lo que están buscando, ni de la verdadera causa de su desacuerdo, son a la vez estériles e insolubles. El despilfarro de esfuerzos se origina, en este caso, en lo siguiente: se piensa que cada vez que un conjunto de reglas se presenta con una determinada unidad, que lo hace acreedor a una

nación unificadora, esa designación es el nombre de una entidad *sui generis*, poseedora de alguna característica o propiedad central (su naturaleza jurídica) de la que derivan, como quien dice en forma genética, todas las reglas del sector en cuestión, y también otras que, si bien no están contenidas expresamente en él, son "engendradas" —al igual que las primeras— por la fecunda idea central, o naturaleza jurídica. Este modo de presentar las cosas es, según Heck³, un resabio del pensamiento de la Escuela Histórica, que ha perdurado en la teoría jurídica de Europa Continental mucho después que las banderas de aquel movimiento romántico fueron arriadas.

Se trata, en suma, de un exceso cometido al amparo de la pretensión de dar definiciones reales, o de explicitar el verdadero, único o último significado de ciertas expresiones de estructura y comportamiento muy complejos.

Parásitas de las controversias sobre la naturaleza jurídica de tal o cual institución, son las numerosas polémicas que versan sobre si determinada característica es de la "esencia" de una institución, o simplemente de su "naturaleza". No vale la pena detenerse en ellas.

5. CONTROVERSIAS GENERADAS POR UN DESACUERDO VALORATIVO ENCUBIERTO

Existen muchos otros tipos de desacuerdos o seudodesacuerdos dignos de presentación y análisis. Como no puedo ocuparme de todos ellos prefiero dedicar lo que resta a un tipo especial, estrechamente conectado con el uso o función emotivos de ciertas palabras que aparecen con frecuencia en el campo de la teoría jurídica y en el de la teoría política.

Cuando están de por medio esas palabras, la pretensión de dar "definiciones reales", esto es, de "descubrir" el significado "verdadero" de una palabra o expresión, asume la forma de lo

³ *Begriffsbildung und Interessensjurisprudenz*, traducido al inglés en el volumen *The Jurisprudence of Interests*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1948, págs. 99-256.

que Stevenson ha llamado "definiciones persuasivas". De ellas me ocupé, rápidamente, en la primera parte⁴.

Una definición persuasiva es una especie de trampa verbal que se tiende al oyente o al lector. Tomemos una palabra que en el uso común tiene una fuerte carga emotiva, por ejemplo "cultura". Esta palabra tiene, a la vez, un uso neutro o puramente descriptivo, que es el que se le da en los tratados de antropología. Allí se habla de la cultura de los arunta o de los hotentotes, sin que ello importe sugerir que estos caballeros hayan alcanzado un aceptable grado de refinamiento en algún aspecto. En el uso corriente, por el contrario, el sustantivo "cultura" y el adjetivo "culto" tienen, como señalé, un fuerte significado emotivo, de naturaleza, claro está, aprobatoria, mientras que el significado descriptivo de ambas palabras es altamente impreciso. No todo el mundo quiere decir lo mismo cuando califica a un hombre de "culto", aunque en todos los casos ello evidencia una actitud aprobatoria y de recomendación. En tales circunstancias adjudicar a la palabra "cultura" un significado descriptivo preciso por vía de supuesta definición, y sostener por ejemplo, que la verdadera cultura es el conocimiento de las ciencias físicas, matemáticas y de las técnicas derivadas de ellas, o que la verdadera cultura no es eso sino el conocimiento de las humanidades, o que un hombre verdaderamente culto no es el que conoce cosas, sino el que sabe conducirse sin hacer papelones en ciertos círculos sociales, etc. es una manera de dirigir la carga emotiva de la palabra en una determinada dirección, para colocar bajo una luz favorable ciertas actividades, como si ellas, y sólo ellas, fueran dignas de encomio, desde el particular punto de vista del juego.

Formular una "definición persuasiva" es, por lo tanto, recomendar un ideal, modificando el significado descriptivo de la palabra sin cambiar su significado emotivo. Otras veces lo que se procura es destacar la importancia de ciertos aspectos o circunstancias que se consideran injustamente desatendidos. Tal es el papel de las llamadas definiciones "re-enfáticas" (Stevenson, *Ethics and Language*, XIII, 3).

⁴ Ver *supra*, págs. 23-24.

Estos juicios de valor encubiertos no sólo se ocultan tras la apariencia de definiciones. También suelen cubrirse con el ropaje de descripciones, en cuyo caso generan disputas que parecen disputas sobre hechos. Esto último ocurre con frecuencia en el campo de la teoría jurídica, donde abundan las discrepancias valorativas disfrazadas de otra cosa.

No hace mucho me ocupé de una de ellas, y como me parece buen ejemplo, volveré sobre el particular. Me refiero a la encendida polémica que se ha generado en torno a la verdad o falsedad de una proposición de cuatro palabras: el lacónico y explosivo enunciado "los jueces crean derecho"⁵.

III. "LOS JUECES CREAN DERECHO" (Examen de una polémica jurídica)

1. LA CONTROVERSIA

El enunciado que sirve de título principal a este apartado ocupa el centro de una agitada polémica entre nuestros juristas. Puede decirse sin exageración que éstos se hallan divididos, a su respecto, en dos bandos irreconciliables: los que afirman enfáticamente que es verdadero, y los que, con igual énfasis, sostienen que es falso. Para los primeros, la posición de los segundos importa negar una característica obvia de la práctica del derecho, y —se suele agregar— ello sólo puede explicarse como una forma de ceguera o de torpeza mental. Para los segundos, la posición de los primeros importa desconocer una distinción tan elemental como la que existe entre las nociones de creación

⁵ Lo que sigue es una reproducción, con ligeros retoques, de mi trabajo "Los jueces crean derecho", publicado en *Revista Jurídica de Buenos Aires*, 1961-IV. En la exposición oral hice una síntesis del mismo; la lectura de la versión taquigráfica me hizo ver la conveniencia de reproducir aquí (sin cortes) la versión original. Ello evitará —creo— riesgos de confusión. Ya el profesor Ves Losada ha sostenido que mi trabajo constituye una apreciable contribución al caos (ver su comentario al mismo en el número 1 de *Notas de Filosofía del Derecho*, pág. 48). No quiero hacerme realmente acreedor a ese reproche.

y aplicación de normas jurídicas, negar la evidente fuerza obligatoria del derecho y, por lo tanto, fomentar la anarquía y el caos, lo que —se suele agregar— sólo puede explicarse como una forma de predilección por el mal.

La polémica ha asumido en ocasiones un tono de particular vehemencia. Poco y nada se ha progresado, empero, en la eliminación del desacuerdo. Por el contrario, éste parece haberse agravado por la misma discusión. En tales circunstancias puede resultar útil, ensayar un bosquejo de análisis de algunos aspectos del significado o significados de “los jueces crean derecho”, para procurar esclarecer el alcance de la controversia. Tal es la finalidad de estas líneas.

Antes de entrar en tema quiero destacar dos cosas. Primero, que todo cuanto se expresa en lo que sigue se refiere a la afirmación de “los jueces crean derecho” (y a su negación) con el significado que efectivamente tienen dichos enunciados en el contexto polémico en que aparecen. Segundo, que lo que diré ha sido pensado teniendo en vista la disputa tal como se presenta entre los juristas del ámbito jurídico de Europa continental, en particular del nuestro; en el mundo del *common law* jueces y otros factores que requerirían una consideración especial que no puedo dedicarle aquí.

2. ¿ES UNA CUESTION DE HECHO?

La situación es, a primera vista, profundamente desconcertante. El desacuerdo versa, al parecer, sobre qué es lo que hacen los jueces. Unos dicen que crean derecho; otros lo niegan rotundamente. ¿Será posible, cabe preguntar, que los juristas no hayan podido ponerse de acuerdo respecto de un hecho tan fácilmente verificable? La labor de los jueces no se desarrolla en el misterio sino a la vista de todo el mundo; constituye un aspecto central del funcionamiento de cualquier sociedad organizada. Los miembros de la magistratura no se reclutan entre los iniciados de alguna secta esotérica; tienen el mismo adiestramiento básico que los protagonistas de la controversia. Los fallos judiciales se publican, analizan, discuten

impugnan. ¿Cómo es posible, entonces, que los teóricos del derecho sigan discrepando acerca de qué es lo que hacen los jueces? ¿Qué esperanzas podemos razonablemente depositar en una empresa con pretensión científica que no consigue acuerdo sobre una cuestión al parecer tan circumscripita? ¿Qué pensaríamos de la ciencia botánica y de sus cultores si en su ámbito persistiera una encendida controversia acerca de la verdad de la proposición “los robles producen bellotas”? Estas preguntas reflejan el desconcierto aludido más arriba y reclaman una urgente respuesta.

3. ¿ES UNA CUESTION PURAMENTE VERBAL?

Hay una manera seductoramente simple de terminar con el problema: sostener que el desacuerdo no versa sobre hechos sino que es puramente terminológico, una mera cuestión de palabras. El argumento podría desarrollarse más o menos así:

A diferencia de “los robles producen bellotas”, “los jueces crean derecho” es un enunciado altamente ambiguo. Los términos que lo componen tienen muchos diferentes significados posibles, y también los tiene el todo. En algunos significados el enunciado es verdadero y en otros es falso. Si reemplazamos la fórmula originaria ambigua por el conjunto de proposiciones diversas que la aparente unidad de aquélla encubre, los protagonistas de la disputa concordarán en cuanto a la verdad o falsedad de cada una de las proposiciones resultantes. Quedará demostrado así que la discrepancia inicial era consecuencia de no haber precisado el sentido de los términos en uso. Una vez efectuada esa clarificación desaparece todo desacuerdo pues este es puramente terminológico.

Para ello bastaría, quizás, con:

a) precisar si en la disputa la expresión “los jueces” se usa como sinónimo de (1) “cada uno de los jueces” o de (2) “el conjunto de los jueces, o los jueces como cuerpo”;

b) estipular un significado libre de vaguedad —en sentido restringido— para el vago término “crean”⁶ y, una vez hecho eso,

⁶ “Crear”, “creador”, “creación” son palabras vagas; en muchos casos el uso no nos indicará con claridad si la situación queda adecuada-

precisar si, en el contexto, "crean" significa (3) "siempre crean" o (4) "dadas ciertas circunstancias crean"; y

c) precisar el significado o significados que, en el contexto de la polémica, puede tener la multívoca palabra "derecho" que tanto puede querer decir allí (5) "normas generales sancionadas por el legislador", o (6) "normas generales, legislativas o no, impuestas por el poder público, incluido los jueces", o "normas generales, legislativas o no, impuestas por el poder público, incluidos los jueces, o normas individuales que no son mera deducción a partir de aquellas normas generales", o "normas —generales o individuales— impuestas por el poder público, incluidos los jueces".

Si para eliminar la ambigüedad de "los jueces crean derecho" sustituimos ese enunciado por las proposiciones que resultan de las clarificaciones y precisiones sugeridas, desaparece toda discordancia. Pues entonces aquel enunciado puede que decir, simplemente, algunas de estas cosas:

I) "El conjunto de los jueces, dadas ciertas circunstancias elaboran, normas generales" (significado incluido en [(2) (4) + (6)]);

mente descripta por ellas. En nuestro caso, ¿vamos a exigir una creación *ex nihilo*? ¿Nos vamos a conformar con la introducción de un cambio sustancial en lo existente, incluso con la de cualquier modificación o añadido? Y si adoptamos el *test* del cambio sustancial que por un lado reduce el peligro de que "crear" quede sin aplicación posible y, por otro, no trivial el uso de esa palabra, ¿qué habremos ganado con sustituir un término vago por una fórmula que incluye otro, "sustancial", que por la vaguedad en persona? Quien resuelve un caso por aplicación de una regla que resulta de combinar otras reglas de modo original, ¿ha "creado" algo, en el sentido del *test* intermedio que examinamos? La misma pregunta puede formularse respecto de aquel que adjudica sentido a un término vago frente a un caso no típico que se presenta por vez primera. Las dificultades para atribuir a "crear" uno o varios significados descriptivos precisos son enormes, y en ello, —así como en la fuerte carga emotiva que en el contexto lleva consigo la palabra— está, quizás, la raíz de la controversia. Ver *infra* apartado 4 (v). Aquí asumimos, a riesgo de dejar a un lado algo demasiado importante, que las partes estipulan un significado descriptivo unívoco (o varios) para "crean".

II) "Los jueces, es decir cada uno de ellos, siempre dictan sentencias" [significado incluido en (1) + (3) + (8)];

III) "En ciertas circunstancias los jueces dictan sentencias que no son el resultado de una mera deducción a partir de normas generales preexistentes" [significado incluido en (1) + (4) + (7)].

La afirmación (I) importa reconocer el carácter de fuente de derecho autónoma pacíficamente asignado a la jurisprudencia. La afirmación (II) es una verdad de Perogrullo que no ha de conmover a nadie y con la que nadie puede honestamente disentir. La afirmación (III) tampoco suscitará divergencias siempre que las partes entiendan lo mismo por "mera deducción".

Paralelamente puede ser que al sostener la falsedad de "los jueces crean derecho" todo cuanto se quiera decir sea una de estas dos cosas, o ambas:

IV) "Es falso que los jueces, ya actuando individualmente, ya como cuerpo, dicten leyes" [significado (1 y 2) + (3 y 4) + (5)];

V) "Es falso que los jueces actuando en forma individual dicten normas generales" [significado (1) + (3 y 4) + (6)].

Es perfectamente posible que los antagonistas originarios concuerden acerca de (IV) y (V), sin que al sostener la falsedad del enunciado "los jueces crean derecho" se pretenda, por lo demás, negar la verdad de (I) y [(II) o (III)], que, por otra parte, sería todo lo que quieren afirmar quienes lo afirman.

Al comienzo de este apartado dije que reducir la controversia a una cuestión puramente verbal era una vía seductoramente simple. Quiero decir ahora que, además, es una manera engañosamente fácil de terminar con el problema. Es concebible, en efecto, que después de efectuadas todas las sustituciones del caso, y exhibidas las concordancias existentes, una de las partes exprese: "Todo está muy bien, pero cuando yo sostengo que los jueces crean derecho no me limito a afirmar cosas tan obvias como 'los jueces dictan sentencias' o 'la jurisprudencia es elaborada por los jueces'. Tampoco me limito a admitir el hecho indiscutible de que, a veces, las sentencias judiciales no son mera deducción a partir de la ley". Es concebible, además, que a otra parte agregue: "Y cuando yo digo que los jueces no crean

derecho no me limito a negar que los jueces sancionan leyes, que la sentencia de un juez sea una norma general obligatoria para sus colegas".

Uno y otro pretenden que "los jueces crean derecho" algo más que en lo que nuestro análisis le hemos hecho. Y respecto de ese "algo más" el desacuerdo subsiste, porque ambas partes pueden decir a dúo: "Estamos de acuerdo en todo lo que usted ha señalado, a saber (1) que los jueces nunca dictan leyes; (2) que el conjunto de los jueces, en ciertas circunstancias, establecen jurisprudencia; (3) que los jueces siempre dictan sentencias; (4) que las sentencias judiciales, en ciertos casos, no constituyen una pura deducción a partir de la ley; y (5) que una sentencia judicial no constituye una norma general obligatoria para otros jueces. Pero no obstante ello estamos en desacuerdo respecto de una cosa *distinta*, a saber, si los jueces crean derecho".

A esta altura de las cosas podemos tomar uno de dos caminos: o hacemos oídos sordos a estas protestas, decretando que ellas son ininteligibles, un mero sinsentido, o bien tratamos de explicarnos la trama de tan pertinaz desacuerdo. Me parece preferible el segundo.

4. LA CONTROVERSIA COMO DESACUERDO DE ACTITUD

Reduciré lo que sigue a la enunciación de una serie de hechos que creo que pueden demostrarse, pero cuya demostración no voy a intentar aquí:

i) Es cierto que la divergencia entre los juristas que afirman "los jueces crean derecho" y los que lo niegan no es un desacuerdo de hecho sobre lo que hacen los jueces (Ver supra, p. 2). Tampoco es una disputa puramente verbal (ver *supra*, p. 2). Aunque hay de por medio, claro está, la elección de ciertas palabras verbales. Se trata, en lo sustancial, de lo que con terminología de Stevenson llamaremos un "desacuerdo de actitud".

⁷ Charles L. Stevenson, *Ethics and Language*. Yale University Press, Cap. 1, "Tipos de acuerdo y desacuerdo"; apartado 2, "Desacuerdo de creencia y desacuerdo de actitud". "Comencemos distinguiendo amplias clases de desacuerdos. Podemos hacer esto de una manera totalmente general, suspendiendo en forma temporaria cualquier decisión

ii) Este desacuerdo de actitud versa sobre dos cosas: a) sobre lo que *deberían* hacer los jueces; y b) sobre lo que *deberían* hacer los juristas al teorizar acerca de la labor judicial. Para quienes afirman "los jueces crean derecho", los jueces deberían impuñar más resueltamente el haz de sus atribuciones y actuar con clara conciencia de la importante función que les toca cumplir en la sociedad; y los juristas deberían atender más a los hechos y problemas concretos que aparecen al nivel de la función judicial y dedicar menos atención al irreal mundo de las normas generales. "Los jueces crean derecho" resume o destaca esta doble actitud, del mismo modo que, en el contexto de la polémica, su negación resume o destaca la actitud opuesta.

iii) El significado de "los jueces crean derecho" y el de su negación *tienen* que ser aprehendidos en el contexto en que típicamente se formulan ambos enunciados, que es el de la polémica a que he venido refiriéndome. El uso que reciben allí esos enunciados *no es descriptivo*. Al sostener "los jueces crean de-

recho" se afirma de qué clase es más típica de la ética normativa, y extrayendo nuestros ejemplos de otros campos. Los desacuerdos que tienen lugar en la ciencia, en la historia, en la biografía y en sus contrapartidas en la vida cotidiana, sólo requerirán breve consideración. Los problemas sobre la naturaleza de la transmisión de la luz, los viajes de Leif Ericsson, y la fecha en que Jones llegó tarde a tomar el té, se asemejan todos en que ellos pueden encerrar una oposición que es primariamente de creencias... En tales casos un hombre cree que p es la respuesta, y otro cree que es no-p, o bien uno trata de dar algún tipo de prueba de su opinión, o revisarla a la luz de información adicional. Llamaremos a esto 'desacuerdo de creencias'. Hay otros casos, que difieren agudamente de éstos, que pueden ser llamados 'desacuerdos' con igual propiedad. Ellos implican una oposición, a veces insinuada y gentil, a veces enérgica, que no es de creencias, sino de actitudes, es decir, una oposición de propósitos, aspiraciones, necesidades, preferencias, deseos, etc. Llamaremos a los desacuerdos de este tipo 'desacuerdos de actitud'... Los dos tipos de desacuerdo difieren principalmente a este respecto: el primero tiene que ver con la forma como las cosas han de ser fielmente descriptas y explicadas; el último tiene que ver con la forma como han de ser preferidas (*favoured*) o no preferidas, y, por ello, con la forma como ellas han de ser conformadas por los esfuerzos humanos". (La traducción es mía). Ver también Stevenson, *The Nature of Ethical Disagreement*, en Feigl y Sellars, *Readings in Philosophical Analysis*, Appleton Century-Crofts Inc., 1949, pág. 587.

CREACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO. CUESTIÓN DISCUTIDA. SOLUCIÓN.

recho" no se pretende suministrar cierta información sobre que hacen los jueces, sino destacar o subrayar, para fines prácticos y teóricos, la enorme *importancia* que tiene la labor judicial en la dinámica de los fenómenos jurídicos. Se apela para a un *slogan* vívido, encaminado a obtener que quienes han entendido crónicamente la función judicial por considerarla actividad secundaria se sientan movidos a ocuparse de ella. En el contexto de la polémica "los jueces crean derecho" no tiene a describir el quehacer judicial sino que procura suscitar o provocar ciertas reacciones. El enunciado "los jueces no crean derecho", en ese mismo contexto, es vehículo de la actitud opuesta.

iv) El *slogan* que nos ocupa puede llegar a alcanzar una formulación extrema que tiene cierto aire de paradoja. Allí, quizás, se hace más patente el carácter no descriptivo del enunciado. De "los jueces crean derecho" se pasa a la expresión, mucho más fuerte, "sólo los jueces crean derecho" o "todo el derecho es creado por los jueces" (John Chipman Gray, *The Nature and Sources of the Law*, 125). Tal es el grito de batalla del realismo jurídico norteamericano, movimiento que ha procurado por sobre todo reformar el estado de cosas existente, no describirlo⁸.

v) La verdadera índole de la cuestión queda usualmente encubierta porque el enunciado "los jueces crean derecho" (como su negación) pareciera estar describiendo el quehacer de los jueces. En presencia de casos como éste podemos hablar de enunciados "pseudo-descriptivos" o, tal vez mejor, de un "pseudo-descriptivo" del lenguaje. La expresión "crear derecho" posee una poderosa carga emotiva que es factor central en esa dimensión "pseudodescriptiva" del enunciado. "Crear" significa, en la mayoría de los contextos, que lo que se hace es importante. Llamar a alguien el "creador" de algo, y a este algo "creación", traduce, bastante claramente, una actitud de aprobación o reconocimiento.

⁸ Kelsen analiza "all the law is judge-made law" en *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945, pág. 150. Sobre el realismo jurídico y el llamado "escepticismo ante las reglas" véase Hart, *Derecho y Moral: Contribuciones a su análisis*, Depalma, 1961, págs. 24/40. El *Concepto de Derecho* Abeledo-Perrot, 1963, Cap. I, "Formalismo y escepticismo ante las reglas", págs. 155 y sigtes.

No es necesario abundar mucho, por otra parte, para poner de manifiesto el carácter encomiástico que tiene, prácticamente en todos los contextos, la palabra "derecho". El agregado "crear derecho" tiene el significado emotivo de "hacer algo muy importante y digno", significado emotivo que obviamente no posee "dictar sentencias".

vi) En relación con esto último cabe señalar, además, que el carácter "pseudo-descriptivo" (y encubiertamente emotivo-descriptivo) está en función de la altura de nivel, por decir así, a que se pretende colocar la referencia. Tomemos un ejemplo de Perelman. Frente a la misma situación de hecho podemos contestar a la pregunta "¿Qué está haciendo Fulano?" de las siguientes maneras: "Fulano está fabricando tornillos", o "está trabajando en la fabricación de topadoras", o "se está ganando el sustento", o "está colaborando en el esfuerzo económico nacional", etc. En cierto sentido todas estas proposiciones se refieren al comportamiento de Fulano. Pero resulta patente que a medida que "ascendemos" de nivel, las proposiciones van perdiendo significado descriptivo y adquiriendo mayor significado emotivo. Puede sostenerse, me parece, que "los jueces crean derecho" está, respecto de "los jueces dictan sentencias", en una relación semejante a la que tienen entre sí "Fulano está colaborando con el esfuerzo económico nacional" y "Fulano está fabricando tornillos".

vii) El uso de expresiones pertrechadas de una alta dosis de carga emotiva para dirigir las actitudes o el comportamiento humano es característico del vocabulario político, en sentido amplio. Dichas formas de expresión están destinadas a proporcionar

⁹ Al preparar las conferencias advertí algo que no había visto cuando escribí el artículo. A saber, que la palabra "derecho" puede tener en el contexto de esta polémica, por lo menos para uno de los sectores, un sentido paradójicamente peyorativo: el de "restricción a la libertad propia impuesta por otros hombres, con independencia de nuestro consentimiento". En tal supuesto el agregado "crear derecho" presenta el significado emotivo de "hacer algo muy importante y de consecuencias graves para la libertad individual". Este matiz adicional no afecta, me parece, lo sustancial del desarrollo hecho en el texto, aunque obligaría a afinar el análisis.

nar una "imagen" o "cuadro" capaz de provocar adhesión, subrayar ciertos aspectos insuficientemente atendidos. Ellas describen nada o, al menos, no es ese su uso primario¹⁰. "Los jueces crean derecho" (o su negación), tal como se da en la polémica que le sirve de contexto, pertenece a esa familia de enunciaciones. No debemos olvidar las numerosas y ramificadas implicaciones políticas que tiene nuestro enunciado. Algunas apuntan al controvertido principio de la división de los poderes y su significado actual; otras remiten al problema de las relaciones entre los organismos legislativos, elegidos por sufragio popular y la judicatura, generalmente designada por métodos no democráticos; otras se refieren al conflicto entre el principio de legalidad considerado como bastión del liberalismo político, y ciertas concepciones de justicia totalitaria que ha conocido nuestro siglo, etcétera.

viii) El hecho de que la divergencia sea básicamente un desacuerdo de actitud: a) explica que la controversia puede subsistir aunque se logre una completa concordancia en cuanto a los hechos y se llegue a estipular una notación descriptiva unívoca y precisa; y b) pone de manifiesto lo inadecuado de la postura de quienes se empeñan en ventilar la controversia como si se tratara de una divergencia sobre lo que hacen los jueces. Tal es el resultado que del problema conduce a una interminable reiteración de posiciones originarias y, en definitiva, a la exasperación y cansancio.

¹⁰ Ver Margaret Mac Donald, "The Language of Political Thought", publicado en *Essays on Logic and Language*, editados por A. G. Flew, 1ª Serie, Blackwell, 1960, pág. 167. Ver también Stephen Min, *Reason in Ethics*, Cambridge at the University Press, 1960, págs. 195-199.

NOTAS Y COMENTARIOS

1. EL CARACTER CONVENCIONAL DEL LENGUAJE (APARTADO I)

Ya San Agustín dividió a los signos en naturales y convencionales. Los primeros son aquellos que, con independencia de toda intención o deseo de usarlos como signos, conducen al conocimiento de algo distinto; así, por ejemplo, el humo es signo de fuego. La conexión se basa en la experiencia (*De la doctrina cristiana*, Libro II, cap. 1, ap. 2). Los signos convencionales, en cambio, son aquellos que los seres vivos intercambian mutuamente con el propósito de mostrar sus sentimientos, percepciones o pensamientos (*ob. cit.*, Libro II, cap. 2, ap. 3). Entre estos signos el lugar principal corresponde a las palabras (*ob. cit.*, Libro II, cap. 3, ap. 4). En cuanto a signos convencionales, ellas afectan el espíritu según las convenciones vigentes en la comunidad donde cada hombre vive, y afectan los espíritus de los distintos hombres de distinta manera. Ello es así porque esas convenciones son diferentes. Los hombres no se han puesto de acuerdo en usar las palabras como signos porque éstas tengan ya significado; por el contrario, ellas tienen ahora significado porque los hombres se han puesto de acuerdo al respecto (*ob. cit.*, Libro II, cap. 24, ap. 37).

La distinción entre signos naturales y convencionales, y la inclusión de las palabras entre los últimos, son hoy moneda corriente (ver, por ejemplo, Ross, *Sobre el derecho y la justicia*, pág. 109).

2. LAS DEFINICIONES EN LAS DISCIPLINAS FORMALES FUERA DE ELLAS (APARTADO I)

Expresa Max Black en "Definition, Presupposition and Assertion", incluido en *Problems of analysis*, Routledge & Kegan Paul, Londres 1954, págs. 24-45: "Cuando los lógicos hablan de la definición de un término, por lo común tienen en mente el análisis o la descripción de la connotación de ese término. Aquí un enunciado característico: 'Definir un término es expresar su connotación o enumerar los atributos que implica. Así, el paralelogramo como figura cuadrilátera de lados paralelos'. Una definición de ese tipo proporciona una condición necesaria y suficiente para la aplicación del término; de ese modo, una definición es correctamente llamada 'paralelogramo' si y solo si es una figura cuadrilátera y tiene lados paralelos. Otra manera de plantear la cuestión es decir que las cosas a las que se aplica el término (esto es, su extensión) constituyen una clase delimitada en forma tajante: todo cuanto existe tiene que hallarse totalmente dentro de la clase de los paralelogramos o totalmente fuera de ella. El criterio necesario y suficiente para la aplicación del término 'paralelogramo' proporciona un *test* concluyente para determinar la pertenencia a la extensión de ese término, esto es, la pertenencia a la clase correspondiente".

"No es accidental que los ejemplos favoritos de este tipo de definición tradicional de definición *per genus et differentiam* se extraigan de las matemáticas. Porque en un *calculus* tales definiciones suelen ser prácticas y útiles. Puesto que los términos de tal *calculus* suelen ser 'no interpretados', las reglas que los conectan pueden ser tan rígidas como las del ajedrez. Pero tan pronto como pasamos de la matemática 'pura' a la 'aplicada' se hace difícil hallar una definición del tipo tradicional que sea precisa y útil. El tipo de definición que consiste en dar la connotación de un término en la forma de una condición necesaria y suficiente que determine una clase, lejos de ser normal o solita, es algo excepcional y notabile".

Seguidamente Black se ocupa de los problemas que surgen con la definición de términos actual o potencialmente vagos, como son "todos los términos familiares de las artes y oficios, del

recho, de la política, de la educación, de la estética, etc." (*ob. cit.*, pág. 28). Aquí no es posible usar aquella técnica de definición. Ella tiene que ser reemplazada por la exhibición de 'paradigmas' y la elucidación de los múltiples y complejos criterios de aplicación de la palabra, que no acota una clase nítidamente deslindada, sino un campo de contornos imprecisos" (ver en el texto, Primera Parte, III, 3 y 4).

3. DEFINICIONES LEXICAS Y ESTIPULATIVAS (APARTADO I)

Sobre esto (y, en general, sobre el problema de la definición) véase el libro de Richard Robinson, *Definition*, Oxford at the Clarendon Press, Oxford, 1954. El cap. III se ocupa de las definiciones léxicas y el IV de las estipulativas.

En cuanto a las llamadas "definiciones reales", véase el cap. VI, donde Robinson analiza con gran penetración las diversas actividades que ese rótulo común encubre, y concluye por sugerir la conveniencia de reservar la palabra "definición" para las definiciones de palabras (o "nominales"). "Propongo que por 'definición' signifiquemos siempre un proceso relativo a símbolos... y que nunca usemos 'definición' para referirnos a un proceso que no es acerca de símbolos, porque con ese uso aquel término es ambiguo y debería ser reemplazado por palabras más específicas" (*ob. cit.*, pág. 191). Sobre algunas de las heterogéneas actividades cubiertas por el rótulo común "definiciones reales" y sobre su incidencia en el problema que aquí nos ocupa, ver en el texto Apartado II, e *infra*, notas 5 y 7.

4. SOBRE LOS SIGNIFICADOS "INTRINSECOS", "VERDADEROS" O "REALES" (APARTADO I)

Ya hemos visto, con San Agustín, que el lenguaje es convencional (*supra*, nota 1). No obstante ello, desde tiempos remotísimos, y hasta nuestros días, los hombres se afanan en buscar el significado "intrínseco", "verdadero", "real", etc., de las

palabras, como si en ellas residiera algún valor propio, independiente de las reglas de uso que les asignan tal o cual función. La denuncia de la inutilidad de esa pesquisa y de los peligros que ella implica, véase Weldon, *The vocabulary of politics*, Routledge, Londres, 1953, págs. 11-12 y 17-30, Kantorowicz, *A definition of law*, Cambridge at the University Press, 1958, p. I (hay una reciente traducción castellana editada por Revue de Occidente, con errores difícilmente excusables); Robinson, *ob. cit.*, págs. 153-56, etcétera.

Weldon (*ob. cit.*, págs. 11-12) critica la "creencia primitiva, y generalmente no cuestionada, de que las palabras, y especialmente las que normalmente aparecen en las discusiones políticas —términos tales como 'Estado', 'ciudadano', 'derecho', 'libertad'— tienen significados intrínsecos o esenciales, que los filósofos políticos deben descubrir y explicar. Sócrates, con esas investigaciones comienza la filosofía occidental, dio por sentado que 'justicia', 'coraje', 'templanza', así como 'Estado', nombres de cosas, y se puso a descubrir las cosas que esas palabras nombran".

Ese tipo de creencia fue "peligrosamente equívoco, porque condujo insensiblemente a la presuposición adicional de que el análisis de las palabras y de las formas lógicas podía por sí mismo proporcionar información sobre cuestiones de hecho. Se creía que con solo pensar, sin ninguna observación o consideración de los hechos concretos, era posible hallar los significados verdaderos de las palabras, y que este proceso, por alguna vía indefinible, tenía que dar información sobre la naturaleza y relaciones de las cosas a las que las palabras se refieren. ...

... La investigación, sin embargo, está condenada a la esterilidad, porque las palabras no tienen significado en ese sentido; simplemente tienen usos. No hay nada divino o mágico acerca de 'justicia' o 'libertad'; solo son parte del aparato verbal de que nos valemos para describir y criticar ciertos tipos de conducta humana. Ellas no son el nombre de Ideas o arquetipos... porque no son el nombre de nada. Conocer sus significados es saber cómo usarlas correctamente, esto es, de modo que sean generalmente inteligibles" (*ob. cit.*, pág. 19).

5. DEFINICIONES REALES (APARTADO I)

Robinson comienza así el capítulo VI de *Definition*: "Los capítulos anteriores, salvo el primero, han versado sobre la definición de palabras. Según un gran número de excelentes pensadores hay también otro tipo de definición, a saber, la de cosas. Los inventores de la noción de definición, Sócrates y Platón, obviamente sólo pensaban en las definiciones de cosas y en modo alguno en la de palabras. La búsqueda de la definición de piedad en el *Eutifron* es ciertamente una pesquisa acerca de la cosa piedad, no acerca de la palabra "piedad". Sócrates no le pregunta a Eutifron qué es piedad porque esa palabra sea nueva para él, o porque no se le ocurra un método efectivo para enseñar el uso de ella a quienes no lo conocen. Sócrates no formula una pregunta sobre la palabra 'piedad', sino que usa esa palabra para formular una pregunta sobre la cosa piedad, y da por sentado que su interlocutor y él ya conocen el uso de la palabra" (*ob. cit.*, pág. 149).

Robinson señala poco más adelante que la creencia de que hay algo así como definiciones de cosas ha sido sustentada por pensadores ilustres, y se pregunta si ella es verdadera. "Mi respuesta es que la búsqueda de definiciones reales, iniciada por Sócrates y seguida hasta nuestros días, no ha sido una actividad de tipo único; ha incluido varias clases distintas de actividades. Quienes las practican no han percibido esas diferencias y han considerado que tales actividades son una misma cosa: definición. Una de ellas, al menos, es decididamente mala, porque presupone algo falso, mientras que las otras son malas en el confuso estado en que aparecen bajo el rótulo de definición, pero pueden ser buenas si se las desenmaraña" (*ob. cit.*, pág. 152).

A continuación distingue doce actividades diferentes que se ocultan bajo aquella engañosa denominación unitaria. Me interesa aquí recordar cinco de ellas:

1) La definición real como búsqueda de una inexistente identidad de significado (*ob. cit.*, págs. 152-53).

2) La definición real como búsqueda de esencias (*ob. cit.*, págs. 153-56);

3) La definición real como tautología directamente derivada de una definición nominal (*ob. cit.*, págs. 158-61);

4) La definición real como búsqueda de una clave (*ob. cit.*, págs. 162-65); y

5) La definición real como adopción y recomendación de ideales (*ob. cit.*, págs. 165-71).

En la nota 7 se verá, espero, por qué destaco esto.

6. LA AMBIGÜEDAD DE LA PREGUNTA "¿QUÉ ES X?" (APARTADO I)

En el libro citado en la nota anterior Robinson se pregunta por qué tantas actividades han sido confundidas bajo el rótulo de definición real. Esta es su contestación: "En la vida muy importante el nacimiento y larga vida de este concepto, definición real, se debe sin duda a la aparición del lenguaje, o por lo menos en los lenguajes indo-europeos, de la forma de pregunta: "¿Qué es x?". La definición real aparece por primera vez en la literatura como respuesta a preguntas de esa forma, hechas por Sócrates. Y el carácter confuso del concepto de definición real es un efecto de la vaguedad de la fórmula "¿Qué es x?". Porque esa es la forma más vaga de pregunta salvo un gruñido inarticulado. La definición real florece por eso, florece la forma de pregunta '¿Qué-es-x?'; y esto último ocurre precisamente porque esa fórmula es vaga. Nos ahorra la molestia de pensar y expresar con exactitud qué es lo que queremos saber acerca de x. Al decir '¿Qué es x?' podemos dejar a nuestro interlocutor la tarea de descubrir qué información buscamos acerca de x buscamos. Podemos usar esa forma de pregunta para expresar un deseo general de recibir cualquier información acerca de x". (*ob. cit.*, pág. 190).

Sobre este mismo problema véase Hart, *Definition Theory in Jurisprudence*, Oxford University Press, 1953 (traducción castellana de Genaro R. Carrió bajo el título "Definición y teoría en la ciencia jurídica", en *Derecho y Moral*, págs. 93-138): "Preguntas como las que he mencionado: '¿Qué es derecho?', '¿Qué es derecho subjetivo?' presentan

ambigüedad. La misma forma verbal puede emplearse para pedir una definición, o bien la causa, propósito, justificación u origen de una institución jurídica o política".

7. DISTINTOS TIPOS DE DESACUERDOS ENTRE JURISTAS (APARTADO II)

En el texto se distinguen cinco tipos de desacuerdos. Esa lista, que no es ni pretende ser exhaustiva, puede parecer rápida o arbitraria. Creo, sin embargo, que hay "some method in its madness". Está inspirada, en gran medida, en el análisis de las (pretendidas) "definiciones reales" que hace Robinson (ver *supra*, nota 5). He aquí una somera explicación:

a) No hay disciplina menos liberada de "magia verbal" que la que nosotros llamamos, bastante pomposamente, "ciencia del derecho". La búsqueda de significados "reales", "intrínsecos" o "verdaderos" es actividad casi *full time* de los juristas. Tal actitud se conecta con el hecho de que buena parte de los juristas están enrolados, consciente o inconscientemente, en una postura formalista (ver en el texto Parte Segunda, Apartado III, 1). Una de las tesis centrales del formalismo, si no la definitiva, es la que postula la auto-suficiencia del orden jurídico y, con ello, veda recurrir a elementos de juicio valorativos, para argumentar en términos de consecuencias, para fundar soluciones. Solo queda, por lo tanto, el recurso a los conceptos "consuetudinarios" a partir de las reglas positivas.

b) En esa (pretendida) tarea de hallar significados "verdaderos" y formular las correspondientes "definiciones reales" los juristas no siempre coinciden. Mejor dicho, discrepan con alar frecuencia. De hecho aquella faena encubre actividades heterogéneas, mal disimuladas. Esas actividades son, precisamente, algunas de las que Robinson trae a luz. Ellas suelen conducir a conclusiones discrepantes, lo que genera abundantes polémicas que tienen garantizada una vida perdurable. A veces, porque sólo hay una posición de desacuerdo; otras, porque las tesis en juego son rigurosamente irrefutables, pero también rigurosamente vacuas; otras, porque los contendores discuten mal, es decir, no se hacen cargo

de la índole del desacuerdo y dirigen equivocadamente la llería de su argumentación.

c) En el texto se puntualizan y examinan, muy rápidamente, cinco tipos de desacuerdos entre juristas. Los del primer punto (seudo-disputas originadas en equívocos verbales) y los del tercero (disputas sobre clasificaciones) se vinculan a las actividades que Robinson examina bajo los títulos "la definición como búsqueda de una inexistente identidad de significado" y "la definición real como búsqueda de esencias". Los del segundo punto (seudo-desacuerdos de hecho en torno a proposiciones analíticas) se conectan con la actividad que aquél llama "la definición real como tautología directamente obtenida de una definición nominal". Los del cuarto punto (controversias sobre "naturaleza jurídica de una institución") tienen que ver con la actividad que Robinson llama "la definición real como la búsqueda de una clave". Los del quinto y último punto (controversias generadas por un desacuerdo valorativo encubierto) relacionan con la actividad que el nombrado llama "la definición real como adopción y recomendación de ideales".

8. SEUDO-DISPUTAS ORIGINADAS EN EQUIVOCOS VERBALES (APARTADO II, 1)

Véase Hume, *Treatise*, Sección VIII, Parte I, 62: "It may reasonably be expected in questions which have been canvassed and disputed with great eagerness, since the first origin of science and philosophy, that the meaning of all the terms, at least should have been agreed among the disputant; and our enquiries, in the course of two thousands years, been able to pass from words to the true and real subject of the controversy. . . . From the circumstance alone that a controversy which has been long kept on foot remains still undecided, we may presume that there is some ambiguity in the expressions, and that the disputant affix different ideas to the terms employed in the controversy". Véase también Aristóteles, *Tópica*, Libro VIII, cap. 3; Descartes, *Reglas* . . . ; Regla XIII; Bacon, *Novum Organon*, Libro I, Aforismos 43, 59-60; Locke, *Essay* . . . , Libro III, cap. V, ap. 4-11 y

cap. IX, ap. 16-17 y 21, cap. X, ap. 21 y 22 y cap. XI, ap. 6 y 7.

En particular, y con referencia al enfoque que aquí adoptamos, consúltese Robinson, *ob. cit.*, pág. 152-3; Weldon, *ob. cit.*, pág. 13; Glanville Williams, "Language and the Law" IV, *The Law Quarterly Review*, vol. 61, oct. 1945, págs. 384-90. De este último autor véase también "The controversy concerning the word 'law'", en Laslett, *Philosophy, Politics and Society*, Blackwell, Oxford, 1956, págs. 134-56, especialmente págs. 148 y sigtes. Williams enumera allí distintos factores, estrechamente ligados entre sí, que, a su juicio, hacen que subsistan muchas disputas jurídicas, que no son otra cosa que "meras cuestiones verbales".

Se ha criticado a Williams que su intento de disolver la mayoría de las discrepancias jurídicas en "meras cuestiones verbales" es demasiado simplista. Se ha sostenido también que, en el mejor de los casos, las afirmaciones de dicho autor solo pueden valer como paradojas, dirigidas a mostrar en forma llamativa que tales desacuerdos no son semejantes a las discrepancias de hecho comunes. Para la crítica véase Hart, "Definición y Teoría . . .", en *Derecho y Moral* . . . , págs. 95-96, y *El concepto de derecho*, págs. 6-7. La apreciación mencionada en segundo término es de Wisdom, "Gods" y "Philosophy, Metaphysics and Psycho-Analysis", artículos incluidos en *Philosophy and Psycho-analysis*, Blackwell, Oxford, 1957 (ver págs. 157-58 y 249-54).

La creencia de que se tiene firmemente asido el significado único y propio del sustantivo "derecho" y del adjetivo "jurídico" suele ser fuente de afirmaciones intrépidas. Véase, por ejemplo, la admirable ingenuidad del autor de la nota publicada en *La Ley*, tomo 45, págs. 839-46 (especialmente Apartado I, El Derecho en tanto objeto).

Hay un ejemplo mayúsculo de controversia jurídica incurablemente afectada por los dos males que denunciarnos en el apartado II, puntos 1 y 2, del texto. Nos referimos a la ya secular polémica en torno a la noción de "causa" de las obligaciones. Es normal que los juristas empiecen distinguiendo dos acepciones de la palabra causa: 1) como "causa-fuente" y 2) como "causa-fin". La primera acepción suele ser descartada co-

mo no problemática y el examen doctrinario, con su secuencia de disputas, suele converger sobre la segunda. Una vez hecha esa distinción, el método de esclarecimiento cambia. De la palabra causa, en el oscurísimo sentido de "causa-fin", se salta inmediato a la supuesta *entidad* que —se cree— aquella palabra nombra. Irrumpe entonces la pregunta "¿Qué es la causa?", pregunta que es generalmente formulada con la seguridad de que aquella tosca distinción terminológica basta para garantizar un fructífero intercambio de ideas y, eventualmente, la seriedad de la discusión.

Esa pregunta ha recibido numerosas respuestas heterogéneas. Se ha dicho que la causa es la finalidad abstracta, impersonal y objetiva, que cada tipo de acto jurídico lleva en sí el fin inmediato y determinante que las partes han tenido en mira al otorgar el acto; o los motivos expresados en él; o la función económica o social del mismo; o un elemento justificativo de la fuerza obligatoria atribuida al acuerdo de voluntades; y muchísimas cosas más.

Un lego inteligente podría preguntarse cómo es posible que los protagonistas de la polémica no adviertan que, cada uno por su lado, están hablando de cuestiones distintas. Ese mismo lego podría extrañarse ante el hecho de que la tarea de clarificación, que permitió distinguir entre "causa-fuente" y "causa-fin" como dos centros de problemas distintos, se haya detenido tan prematuramente. Y si nuestro lego llegase a leer la completa revista de las posiciones doctrinarias que trae Busso (*Código Civil Anotado*, III, págs. 114 y sigtes.), recibiría, junto con el *shock* de estremecimiento, la impresión de que eso no tiene remedio.

Porque ¿cuántos significados distintos de la palabra causa están en juego en la controversia? ¿Qué sentido tiene preguntarse cuál de ellos es el verdadero? (¿Por qué no indagar también si el significado real de "causa" es "causa-fuente" o "causa-fin"?). ¿Cómo es posible que pensadores serios invoquen seriamente afirmaciones que no son otra cosa que desarrollos analíticos de una decisión previa (la que asignó a la palabra causa el sentido X), para "refutar" otras afirmaciones que, a su vez, no son más que desarrollos analíticos de una decisión pre-

distinta (la de otro pensador que asignó a la palabra causa el sentido Z)? ¿Hay acaso una misma entidad —la causa— que es para unos una finalidad impersonal y abstracta, para otros un cúmulo de móviles concretísimos, para otros un standard valorativo, etc.? ¿O todo cuánto hay como elemento unificador del debate es una misma *palabra*?

Sólo en medio de un clima de gran confusión se pueden decir cosas de este tipo: "El neocausalismo coincide, con la teoría clásica en afirmar la necesidad de que a la causa se la considere un elemento de la realidad jurídica, pero discrepa fundamentalmente en cuanto a determinar qué debe entenderse por causa" (Busso, *ob. cit.*, III, 118). Esto no parece mucho más juicioso que decir, por ejemplo, que Juan y Pedro están de acuerdo en que la democracia es el sistema político más adecuado, pero discrepan totalmente acerca del significado de la palabra "democracia", al punto de que para el primero no es aplicable a los regímenes comunistas y para el segundo sólo es aplicable a ellos.

9. SEUDO-DESACUERDOS DE HECHO EN TORNO A PROPOSICIONES ANALÍTICAS. (APARTADO II, 2)

"Siempre que hallemos que una persona está absolutamente segura respecto de algún enunciado de vasta generalidad, es prudente investigar si el enunciado es verdadero por definición y, por ende, carente de importancia práctica, aun cuando su sostenedor crea que se trata de una valiosa pieza de psicología o de otra ciencia positiva" (Robinson, *ob. cit.*, pág. 159-60).

10. DISPUTAS SOBRE CLASIFICACIONES (APARTADO II, 3)

Para un examen esclarecedor del papel que los juristas erróneamente asignan a las clasificaciones, ver Heck, "The formation..." en *The Jurisprudence of Interests*, págs. 107, 111, 149-155, 157, 171-75, 195, 213, 217-35. En el apéndice titulado "Las controversias de construcción y la posibilidad lógica de la de-

finición múltiple de conceptos", se examinan las estériles proposiciones que aquella actitud origina (*ob. cit.*, págs. 235-43). En el mismo volumen véase el trabajo de Rümelin "Developments in legal theory and teaching during my lifetime", págs. 3-27, en especial págs. 10-13.

11. CONTROVERSIAS GENERADAS POR UN DESACUERDO VALORATIVO ENCUBIERTO (APARTADO II, 5)

Cf. Robinson, *ob. cit.*, págs. 165-70. Ver también págs. 76-77, donde el autor expone y censura el procedimiento de tipular una definición "neutra" para un término con carga emotiva, y usarlo después con todas las implicaciones que la definición pretendía excluir.

En "Language and the Law" - V, *The Law Quarterly Review*, vol. 62, oct. 1946, págs. 389-90, Glanville Williams ocupa de aquel abuso de lenguaje que tiene lugar "cuando el uso emotivo de palabras es disfrazado estratégicamente de enunciación referencial. En lugar de expresar francamente emoción por el uso de palabras adecuadas a ese propósito (tal como los enunciados de 'deber ser' y los adjetivos 'bueno' y 'malo') ... la frecuencia nos encontramos con que resulta más convincente usar en lugar de aquéllas, la terminología de los enunciados referenciales (tal como el indicativo 'es' y los adjetivos 'verdadero' y 'falso'). Incluso puede ocurrir que la persona que habla se da cuenta de engañar por su propio lenguaje, y crea que está expresando un enunciado de hecho. Esta tendencia a vestir los enunciados emotivos con el ropaje de los enunciados referenciales es endémica en los trabajos de filosofía, sociología y teoría jurídica. Tal como este tipo de literatura tiende a confundir las proposiciones de hecho con definiciones, así también tiende a confundir las proposiciones de hecho con juicios de valor. La mayor parte de lo que conocemos como filosofía política, ciencia política y teoría jurídica, consiste en elaboradas definiciones, mezcladas con juicios de valor. El todo va usualmente disfrazado de enunciación de hecho. Buena parte de la literatura es polémica: cada autor expone su propio conjunto de definiciones y juicios de valor."

oposición a otros autores. Como ni una definición ni un juicio de valor pueden en última instancia ser lógicamente refutados, resulta imposible arribar a ninguna solución definitiva sobre el "punto".

Sobre las definiciones y las aserciones re-enfáticas, ver Stevenson, *Ethics and Language*, cap. XIII. Véase también Hart, *El concepto de derecho* (págs. 293-94), quien señala que las afirmaciones de los juristas que cita en el capítulo primero "son formas paradójicas o exageradas de destacar algunos aspectos del derecho que, según la opinión del respectivo autor, son oscurecidos por la terminología jurídica ordinaria o bien han sido indebidamente desatendidos por los teóricos anteriores. En el caso de cualquier jurista importante, es frecuentemente provechoso proponer la consideración de la pregunta acerca de si sus enunciados sobre el derecho son literalmente verdaderos o falsos, y examinar en primer término las razones detalladas dadas por él en apoyo de sus enunciados y, en segundo término, la concepción o teoría que sus enunciados tratan de desplazar. Es familiar en el campo de la filosofía un uso similar de afirmaciones paradójicas o exageradas, como método para destacar verdades desatendidas".

12. DESACUERDOS DE CREENCIAS Y DE ACTITUD (APARTADO III, 4)

Cf. Ross, *Sobre el derecho y la justicia*, págs. 297-306.

13. EL REALISMO JURIDICO NORTEAMERICANO COMO MOVIMIENTO PRIMORDIALMENTE REFORMADOR (APARTADO III, 4)

"Los primeros realistas, Holmes entre ellos, estaban muy interesados en promover una actitud nueva, más experimental y más constructiva, frente a la vida social y al pensamiento sobre lo social, pero se abstuvieron de formular proyectos específicos. ... (Lloyd, *Introduction to Jurisprudence*, págs. 207-8). "Los 'realistas' han cumplido su parte en provocar un cambio de enfoque y actitud frente al sistema jurídico y a la función del dere-

cho y de los juristas en la sociedad. Tal cambio se ha hecho sentir prácticamente en todas las facultades de derecho del mundo del *common law*, salvo las más tradicionales" (*ob. cit.*, p. 209). Véase también Morton White, *Social Thought in America; The Revolt against Formalism*, cap. V.

En el prólogo a la sexta impresión de *Law and the Modern Mind* (noviembre de 1948), dice Jerome Frank: "La verdad es que, como a la mayoría de los 'escépticos constructivos' [entre los que Frank da a los realistas] a mí me guiaba un deseo ávido—quizás demasiado ávido— de reformar nuestro sistema judicial, de inyectar, en cuanto fuese practicable, más razón y justicia en su funcionamiento cotidiano" (Anchor Books edición, New York, 1963, pág. xxx).

II

ALGUNAS PALABRAS SOBRE LAS PALABRAS DE LA LEY

El 5 y el 12 de setiembre de 1970 pronuncié dos conferencias en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, como parte de un ciclo que contó con la participación de varios juristas. Se trataba, según entendí, de aportar algunas contribuciones, desde distintas perspectivas, a la clarificación del cúmulo de problemas que los teóricos del derecho tratan bajo el confuso rótulo de "interpretación".

El presente ensayo reproduce lo que juzgué útil y apropiado decir en esa oportunidad. No he modificado el texto de las conferencias sino en aspectos de detalle.

Agradezco a la Universidad de Belgrano por haberme invitado a hablar en ese ciclo y expreso mi reconocimiento a Eduardo A. Rabossi por sus observaciones críticas al manuscrito original.

CAPÍTULO I

INTRODUCCION

Siguiendo una vieja y aceptable práctica voy a comenzar por el principio. Hace ya unos años —siete, para ser preciso— dicté tres clases en un ciclo organizado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, a cuyo cuerpo docente por ese entonces pertenecía. No recuerdo con exactitud el título general con que bauticé a mis clases; sólo recuerdo que era largo y atroz. Dos años más tarde, en 1965, las conferencias fueron publicadas. Introduje en ellas algunas modificaciones de detalle y muy pocos agregados. Además, les adosé un apéndice, consistente en comentarios al texto y en referencias bibliográficas. El resultado fue un pequeño volumen que apareció bajo el título de *Notas sobre derecho y lenguaje*¹.

Durante el tiempo que medió entre las conferencias y la publicación del libro advertí que había incurrido en no pocos errores. No intenté enmendarlos entonces ni lo he hecho hasta ahora. Alguna vez trataré de hacerlo. Ninguno de esos errores, empero, afecta de manera sustancial las ideas centrales que expuse en relación con los problemas que los juristas examinan bajo el rótulo impreciso de "interpretación".

Algunas de esas ideas han dado lugar a malos entendidos. Sería una inaceptable presunción de mi parte suponer que las incomprensiones no me son imputables, ni siquiera parcialmente. Más bien me inclino a creer que no supe expresarme con

¹ Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1965.

claridad. Como ese defecto es remediable, trataré de poner remedio.

Utilizaré como guía para hacer las aclaraciones y/o rectificaciones del caso las críticas que me ha formulado el Profesor Sebastián Soler en su reciente y notable libro *Las palabras de la ley*². He elegido ese camino por tres razones de distinto po y peso. Primero, porque pienso que si un lector tan lúcido e informado como Soler ha entendido mal ciertos pasajes de mi obra esos pasajes adolecen de oscuridad. Segundo, porque creo que la discrepancia polémica, cuando se ejerce con altura y respeto mutuo, y cuando hay el sincero intento de comprender el punto de vista ajeno, constituye un motor indispensable para el progreso de una disciplina como la Teoría General del Derecho. Finalmente, porque entiendo que si Soler me ha hecho el alto honor de criticar en detalle cosas que yo he escrito, tengo el deber — sé si moral o académico — de ocuparme de sus objeciones. Ser por lo menos una falta de urbanidad dejarlas caer en el vacío.

Dividiré la exposición en dos partes. La primera consistirá a) en una síntesis de los puntos de vista principales que, en relación con algunos aspectos de la llamada "interpretación" o "interpretación de la ley", sostuve y defendí en el ensayo de 1965 y b) en una síntesis de las críticas que a esos puntos de vista ha hecho Soler en su libro. Así quedarán planteados los términos del desacuerdo, que parece ser abismal.

En la segunda parte confrontaré las críticas con las tesis criticadas. Examinaré en qué medida las últimas resisten el embate de las primeras, si es que lo resisten. Veremos entonces si las objeciones obligan a reformular las tesis objetadas y, en su caso, qué aspectos de estas últimas requieren tal reformulación y hasta dónde la hacen necesaria.

CAPÍTULO II

SINTESIS DE LAS POSICIONES ENCONTRADAS

1. SINTESIS DE LA POSICION CRITICADA

Las tesis o puntos de vista en juego, que han sido blanco directo o indirecto de críticas, son los que se resumen a continuación.

A. El lenguaje del derecho, esto es, el de las normas o reglas jurídicas, es lenguaje natural. Aquí la expresión "lenguaje natural" se opone a la expresión "lenguajes formalizados". Estos últimos se caracterizan porque sus términos son absolutamente precisos y rigurosamente inequívocos. Tal es lo que ocurre, por ejemplo, en el campo de la lógica simbólica y en el de la geometría pura, disciplinas muy poco proclives al eufemismo y al *calembour*. Las palabras de los lenguajes naturales, entre ellas las que aparecen en las normas jurídicas, no poseen aquellas características. Como el derecho es una técnica de control social cuyas reglas se usan para dirigir u orientar acciones humanas concretas, para posibilitar acciones humanas concretas y para juzgar acciones humanas concretas, sus reglas *tienen* que estar formuladas en lenguaje natural o ser definibles en palabras pertenecientes a este último.

B. Los lenguajes naturales exhiben ciertas notas que es pertinente destacar aquí. Antes de indicar someramente cuáles son, vale la pena señalar que, pese a las mismas, que desde el punto de vista de los lenguajes formalizados, o de las disciplinas que se valen de ellos, suelen verse como deficiencias de los lenguajes naturales, éstos son y serán una insustituible herramienta de comunicación para todos los fines de la vida práctica.

² Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1969.

Las notas aludidas son las siguientes:

a) Los lenguajes naturales contienen expresiones *ambiguas*. Esto quiere decir que una misma palabra, en tanto fonema o morfema, puede tener distintos significados según los diferentes contextos en que vaya insertada, o bien que una misma palabra puede tener distintos matices de significado en función de esos contextos diversos. Quiere decir también que junto a los usos propios de un vocablo hay extensiones metafóricas y figurativas.

Con estas características se conecta, además, el hecho importante de que una misma palabra puede ser usada para designar una multitud de objetos que no tienen propiedades comunes a todos ellos. Existen reglas complejas, muchas veces no detectables sin esfuerzo, que suministran los criterios de aplicación de esa palabra. La existencia de propiedades comunes es sólo una de las muchas razones que pueden justificar el uso de una misma palabra para referirse a una variedad de hechos, situaciones o fenómenos concretos aparentemente disímiles. Muchas veces éstos se hallan unidos por intrincadas relaciones de parentesco que, por un lado, no responden a la existencia de propiedades comunes a todos los objetos y, por otro, fuerzan a descartar la pretensión de que todo cuanto hay es una mera homonimia.

Pongamos un ejemplo que puede ayudar a entender mejor el fenómeno que me interesa destacar. La palabra "derecho" quiere decir cosas distintas —o, en todo caso, no quiere decir exactamente lo mismo— en las siguientes frases:

- i) La esclavitud es una institución contraria a derecho.
- ii) El derecho francés se asemeja más al derecho español que al inglés.
- iii) Los padres tienen el derecho de guiar la educación de sus hijos.
- iv) Hasta hace unos treinta años las mujeres argentinas no tenían derecho a votar.
- v) Mientras que la Física y la Astronomía son ciencias naturales, el Derecho y la Historia no lo son.
- vi) El doctor Eduardo A. Vázquez es profesor de Introducción al Derecho.
- vii) Francisco Real era un hombre derecho.

Sería muy interesante, sin duda, que nos detuviéramos a examinar en qué difieren estos usos y cuáles son las reglas lingüísticas que justifican el empleo de la palabra "derecho" con significados o matices de significación distintos en esos distintos contextos. La tentación es grande pero no podemos ceder a ella sin riesgo de desarticular la exposición.

b) Los lenguajes naturales contienen palabras *vagas*. Con esto quiero referirme al siguiente fenómeno: muchas veces el foco de significado es único, y no plural ni parcelado, pero el uso de una palabra tal como de hecho se la emplea, hace que sea incierta o dudosa la inclusión de un hecho o de un objeto concreto dentro del campo de acción de ella. Hay casos típicos frente a los cuales nadie en su sano juicio dudaría en aplicar la palabra en juego. Hay casos claramente excluidos del campo de aplicación del vocablo. Pero hay otros que, a diferencia de los primeros y de los segundos, no están claramente incluidos ni excluidos.

Estos hechos u objetos, de clasificación dudosa, están ubicados, por decirlo así, en una *zona de penumbra* que circunda el área de significado claro de la palabra. La duda es legítima y no surge de un desconocimiento de las propiedades del objeto a clasificar. No es como la duda que puedo tener sobre si la sombra que veo en el jardín es proyectada por un árbol o por un visitante furtivo. A esa duda puedo disiparla examinando las cosas más de cerca. La otra duda, la que aquí nos interesa, no se origina en ignorancia acerca de los hechos del mundo, sino que es producida por las características de muchas de las palabras clasificadoras que empleamos. Por eso no puede ser aventada de aquella misma manera. Dichas palabras son periféricamente indeterminadas. Para incluir o excluir el caso marginal es menester tomar una decisión.

No todas las palabras vagas lo son de la misma manera ni lo son por las mismas razones. La vaguedad de las palabras "noche" y "día", que priva de sentido a la pregunta "¿a qué hora precisa comenzó la noche (o el día)?", es de distinto tipo que la vaguedad de la palabra "edificio". No hay duda de que el Palacio del Congreso es un edificio y de que la Venus de Milo

no lo es. Pero ¿qué diremos de una tapera, de una casa fabricada, de un faro, de una atalaya, del Coliseo Romano, un igloo, de un galpón, de la Pirámide de Cheops, de un refugio antiaéreo subterráneo, de un palomar, del Puente del Río de la Plata, de una gigantesca burbuja de material plástico donde se aloja una exposición o de la tumba de Rivadavia?

A diferencia de lo que ocurre con palabras como "noche", "día", "joven", "viejo", "alto" y "bajo", en cuyo uso normal el lenguaje recoge propiedades que se presentan en la forma de un continuo que sólo puede recortarse nítidamente pagando un precio de la arbitrariedad, en el caso de "edificio" el uso determina con precisión cuáles son las condiciones necesarias y suficientes que debe satisfacer un ejemplar concreto para ser "correctamente" llamado "edificio".

c) Los lenguajes naturales exhiben una *textura abierta*. Esto quiere decir que aún en el supuesto del empleo de palabras que no son de hecho usadas con vaguedad pueden presentar perplejidades o desconciertos legítimos. Ello ocurre cuando aparece un caso lo suficientemente anómalo como para poner en crisis los criterios de aplicación de las palabras, criterios que genuamente creíamos delimitados y precisos. No es posible elaborar la descripción de un objeto material. Por ello tampoco podemos prever todos los aspectos del mismo en que puede darse una modificación relevante ni, por supuesto, los alcances o efectos de tal modificación. No todas las características no connotadas por una palabra están por ello excluidas como irrelevantes. Algunas no han sido consideradas.

Supongamos que en un rincón inexplorado del planeta habita una comunidad de individuos que, súbitamente, toman contacto por vez primera con un grupo de hombres. Esos individuos tienen forma humana; hablan un lenguaje traducible con gran esfuerzo al idioma de los hombres que los han descubierto; imprimen y leen libros; aman, odian, sufren y se alegran como nosotros y por motivos semejantes a los nuestros; han desarrollado ciencias y artes; poseen una tecnología avanzada y viven bajo instituciones políticas semejantes a las nuestras. ¿Estarían dispuestos a llamarlos "hombres" —en el sentido corriente y vulgar de esta palabra— si, además de esas características,

vieran una estatura promedio de quince centímetros y durmieran durante todo el invierno? ¿Y si su estatura y hábitos de descanso fueran como los nuestros pero vivieran trescientos años? ¿Y si vivieran lo que vivimos nosotros pero su existencia fuera discontinua, esto es, salpicada de eclipses totales de variada duración? Es evidente que nuestro lenguaje no está equipado para hacerse cargo de hechos o situaciones que divergen considerablemente de las usuales o que se dan en una coyuntura o se proyectan en un trasfondo totalmente inesperado.

Este fenómeno de la textura abierta o vaguedad potencial de las palabras afecta a *todas* las que usamos para hablar del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. Cuando se presenta el caso anómalo, su inclusión o exclusión bajo el dominio de la palabra en juego no están guiados por los usos lingüísticos vigentes. Si lo incluimos o excluimos es en base a otras consideraciones.

C. Es verdad que desde mucho tiempo atrás los juristas se han preocupado por dar precisión a los términos que emplean, muchos de los cuales son ininteligibles para los legos, o tienen un sentido distinto del que la misma palabra posee en el habla común. También es cierto que ese esfuerzo de los juristas se ve reflejado en las reglas de derecho positivo, que han acogido muchas de esas expresiones técnicas. A pesar de todo, aunque atenuadas, las incertidumbres subsisten. Y ello es así por algo que ya señalamos. A saber, porque el derecho no podría cumplir sus funciones de guiar actos humanos y posibilitar su apreciación si sus palabras no fueran definibles en términos del lenguaje natural.

Por lo tanto, las características de los lenguajes naturales que señalé en el apartado anterior aparecen también, en mayor o menor grado, en las normas jurídicas.

D. Los hechos que acabo de destacar influyen obviamente sobre la situación del juez, o de cualquier otra persona que, a semejanza de éste, tiene que determinar si un caso concreto dado se encuentra o no comprendido por las palabras generales de una regla o de un conjunto de ellas. El juez tiene frente a sí hechos o situaciones que muestran una enorme riqueza y

variedad de notas y matices, y debe alojarlos en los casilleros diseñados de antemano por las reglas generales.

Hay casos concretos que quedan comprendidos por el claro de significado central de las reglas, pero también hay otros que quedan ubicados en la zona de penumbra de ellas. La solución de los casos claros no ofrece problemas. Los problemas se presentan cuando se trata de resolver los casos dudosos. Las reglas no dictan la solución. Para que ésta no sea arbitraria, y no tiene por qué serlo, tendrá que estar fundada en consideraciones no recogidas por el insuficiente lenguaje de aquéllas.

E. De lo que llevamos dicho se sigue:

a) Que las reglas del sistema no solucionan todos los casos concretos; para resolver los que se hallan ubicados en la zona de penumbra los jueces tienen que adoptar decisiones propias y fundarlas en otros criterios de justificación.

b) Que, por eso mismo, para ser un buen juez no basta con conocer las normas vigentes. Además hay que tener una conciencia sensible a los valores morales, económicos y políticos —en sentido amplio— que están en juego, así como una adecuada información de hecho relacionada con esos problemas valorativos.

c) Que si bien las normas del sistema no dictan las soluciones de los casos de la penumbra, sí estructuran y organizan innumerables situaciones de hecho concretas que quedan comprendidas por el área central de significado de aquellas reglas. Los casos litigiosos, por fortuna, son una minoría. Si hay zona de penumbra es porque hay focos de luz.

F. Hay pensadores que son ciegos frente a los problemas de la penumbra y creen —o prefieren creer— que todos los casos concretos pueden ser resueltos con fundamento exclusivo en las reglas del sistema, o en combinaciones de ellas. Se los ha llamado “formalistas”.

Hay otros pensadores que, obsesionados por los problemas de la penumbra, no advierten —o no quieren advertir— el problema primordial que las reglas desempeñan en la vida cotidiana de una sociedad. Se los ha llamado “realistas”.

Unos y otros están equivocados. No estamos compelidos a optar entre un mundo de reglas rígidas e inflexibles y un caos de decisiones individuales. No tenemos que elegir entre el paraíso de los conceptos jurídicos justamente satirizado por Ihering y el infierno que sería una sociedad sometida a los reflejos condicionados de los jueces de Jerome Frank. Si se me permite una metáfora lúdica diré que no estamos forzados a decidir entre el ajedrez y el *catch*, actividades ciertamente disímiles pero que, no obstante su radical desemejanza, o, paradójicamente, quizás por ella, tienen algo importante en común. A saber, que pueden fácilmente prescindir del árbitro, porque en la primera casi no hay zonas de penumbra y en la segunda casi no hay reglas.

Aún a riesgo de incurrir en el pecado de abusar de una metáfora, diré que el “juego” del derecho no se puede jugar bien sin árbitro, porque a diferencia de lo que ocurre en el *catch*, en el derecho hay muchísimas reglas, y todas ellas, o casi todas ellas, a diferencia de lo que ocurre en el ajedrez, están circundadas por una zona de penumbra.

Los “formalistas” y los “realistas” están equivocados. El dilema “o reglas inflexibles y completas o ausencia total de normatividad” es manifiestamente falso, pese a que recibe la adhesión expresa o tácita de ambos bandos. La verdad es que hay reglas y que ellas desempeñan una función primordial en la vida de toda sociedad, pero esas reglas no resuelven todos los problemas concretos. La expresión “reglas inflexibles” no es tautológica y la expresión “reglas periféricamente indeterminadas” no es contradictoria.

2. INTERMEDIO

Tales son, sintéticamente expuestos, los puntos de vista que hace ya varios años, sostuve en relación con algunos aspectos de los numerosos y heterogéneos problemas que los juristas examinan bajo el rótulo espuriamente unificador de “la interpretación de la ley”. Esas enunciaciones, por supuesto, están muy lejos de agotar el tema. Este tiene muchos otros aspectos que yo no he tocado.

Para concluir con esta síntesis haré referencia a algunas —o aparentemente opuestas— con mayor grado de precisión. En el capítulo primero de *Notas sobre derecho y lenguaje* creí conveniente distinguir entre dos posibles fuentes de confusión capaces de afectar o frustrar una comunicación lingüística. Una de ellas es manifiesta en aquellas situaciones en las que nos sentimos concertados porque no sabemos cómo tomar algo que hemos escuchado o leído. Esto es, porque tenemos dudas acerca de su fuerza.

Con otros términos, no sabemos si se trata de una expresión de un ruego, de una amenaza, de una orden, de la imposición de un propósito, de una promesa, de una pregunta o de algunas de las muchas otras cosas que se pueden hacer con palabras.

Es cierto que introduje ese tema y que me detuve en el tiempo suficiente como para cometer algunas equivocaciones que preferiría no haber cometido. Pero no traje a cuento ese tema sólo para conectarlo con ninguno de los llamados problemas de "interpretación", someramente examinados en el capítulo II del libro. Lo hice para conectarlo con las disputas entre los juristas, cuestión que examiné, también someramente, en el capítulo III.

En ninguna parte sostuve que la incertidumbre o la duda acerca de la fuerza de un enunciado constituía un factor esencial de imprecisión en la labor interpretativa que realizan los jueces. Quizás no hubiera sido desacertado haber dicho algo al respecto; lo cierto es que no lo dije.

Veremos seguidamente cuáles son las críticas que la posición reseñada ha merecido o, en todo caso, que ha recibido. Enfrentaré cada tesis con su intento de refutación porque, más allá de ser de ejecución difícil, ese método afectaría la coherencia interna de la postura crítica, que deseo presentar con claridad y sin distorsiones. Para eso trazaré un cuadro general de ella, dividido en aseveraciones separadas, que no se corresponden una a una con las que acabo de resumir como sustentadas por mí.

En la segunda parte, como dije, haré un balance de los dos enfoques y trataré entonces de analizar las posiciones opuestas

3. SINTESIS DE LAS CRITICAS

La posición que sustenté en el ensayo de 1965 ha sido severamente criticada por Soler. La crítica, aunque cortés, ha sido implacable. Puede sintetizarse de la manera siguiente.

A. Para advertir cuáles son las características del lenguaje jurídico —esto es, el de las normas de derecho— no hay que leer a estas últimas como las lee el juez en trance de dictar sentencia. Hay que leerlas como las leen los hombres corrientes en cuanto miembros de una *polis* para la cual las palabras de las normas constituyen derecho positivo. Ver al derecho tal como lo ve el juez en el momento en que tiene que interpretarlo es concebir al derecho como derecho judicial. Ese es un error de graves consecuencias.

B. Es cierto que el lenguaje común es ambiguo y vago. También es verdad que el lenguaje jurídico no es, ni podría ser, un lenguaje formalizado. Lo que ocurre es que la sola inserción de un modo expresivo en el contexto de una norma convierte en *expresión técnica* a la más común de las palabras. Esa transformación basta para corregir las deficiencias del lenguaje común. No es que la ciencia del derecho cree un sistema de significaciones precisas que cede en préstamo al legislador. El proceso real se produce precisamente en la dirección inversa.

C. Tal transformación del sentido vulgar de las palabras en sentido técnico y preciso está ligada a cinco fenómenos o procesos que —se dice— son distinguibles. Se trata de los siguientes:

a) *Operatividad*. La incorporación de un modo expresivo a la estructura de una norma jurídica hace que esa expresión adquiere un inequívoco sentido dispositivo. No narra, ni aconseja ni se burla; manda, y entiende mandar una cosa precisa. Esto significa, pues, que cuando la ley emplea una expresión ésta tiene un sentido preciso y dispositivo.

b) *Definición*. Cuando la ley habla, siempre acota, limita, define. La ley no puede mandar y prohibir la misma cosa simultáneamente. El principio normativo de no contradicción lima las asperezas de las palabras comunes. Las pulen, limpian y decora siempre a su gusto y voluntad.

c) *Cuantificación*. La cuantificación de lo cualitativo es uno de los procedimientos técnicos típicos del derecho. Las palabras de la ley juegan con fuego. Es menester prestar atención suficiente al destino operativo específico del lenguaje jurídico. Es verdad que la palabra "calvo" es vaga. Pero si la cuestión fuera la de cobrar impuestos a los calvos o de imponerles multas, es seguro que ese estado de hecho relevante habría sido definido de alguna otra manera. Así ocurre con todas las otras palabras cualitativas. La ley civil, la comercial, la penal, fija límites absolutamente precisos para determinar, decretar e imponer cuándo un sujeto es "joven", "adulto", "capaz", "imputable", etc. Todo eso es un medio técnico para que la autoridad o el juez puedan en efecto decir "sí" o "no", eliminando ese "quién sabe" que el realismo parecería postular.

d) *Tipificación*. El objeto de la ley finca en la necesidad de tipificar para regular, es decir, en construir esquemas abstractos que constituyen efectivamente las hipótesis desencadenantes de la coacción jurídica. Una vez que la realidad ha sido tipificada, es decir, transformada en un esquema, en una abstracción, lo fluido queda solidificado, lo borroso recortado. Aun en aquellos casos en que la ley ha tomado del lenguaje vulgar una palabra y la ha tomado con orla y todo, es como si a ésta el derecho mismo la hubiera puesto con deliberación. Cuando la ley se expresa debe entenderse que ha querido decir algo y que, además, ha querido decir precisamente lo que dice. Si lo que dice es vago, esto significa que para ella es indiferente el matiz siempre que el valor sea como tal reconocido.

e) *Constitución*. Hay, por último, otro procedimiento técnico que salva plenamente los peligros y asechanzas de las palabras comunes. La ley crea su propia terminología; inventa palabras que antes no existían. Es inútil buscar indefiniciones, es

fumaduras o borrones en esos conceptos, porque se trata de conceptos constituidos al modo como la geometría construye los suyos. Son en sí mismos definiciones y nada más que definiciones, fuera de cuyos límites no hay nada y si hay algo es exactamente como si no lo hubiera. Las palabras de ese tipo no nombran una realidad fluida, sino una figura o estructura precisa y cerrada. El intento de borrar o esfumar una figura jurídica no puede prosperar. Las abstracciones son siempre muy resistentes.

Así si alguien arguye, por ejemplo, que frente a un caso concreto pueden suscitarse dudas razonables acerca de si la transacción que se examina fue una compraventa o una donación encubierta, porque existió una significativa desproporción entre el valor de la cosa y el dinero que a cambio de ella se recibió, basta con hacerle ver al borroneador recalcitrante que su esfuerzo es vano porque *no puede* haber lugar para ninguna duda razonable, ya que si en lugar de precio hay falso precio la venta se transforma en donación.

D. ¿Cuáles son las características del lenguaje del derecho, visto, como se propugna, desde el punto de vista del súbdito, una vez que los procedimientos técnicos resumidos han producido efecto? Lo que se ve es esto:

a) Todo lo que hay para estudiar y conocer se encuentra en el plano de lo posible. En él todo es anterior al hecho. Dentro de la serie infinita de actos posibles el derecho selecciona los actos debidos, para lo cual tiene que recurrir forzosamente a abstracciones conceptuales o tipos que hacen referencia a series o clases de acciones.

b) Las reglas que constituyen esos tipos no pueden ser sino reglas fijas. Esta expresión es pleonástica y hace referencia al carácter inflexible de toda regla. Por supuesto que las normas de derecho positivo no son universales y eternas. Pero no pueden dejar de ser inflexibles, porque si no lo fueran no reglarían nada.

c) Para delimitar los actos debidos el derecho acota clases de actos que contendrán determinadas notas relevantes y una in-

finidad de notas indiferentes, que no forman parte del cuadro abstracto. Todo lo que la ley no ha puesto como definitivo de la figura queda por ello descartado como carente de relevancia.

d) La cara que el derecho presenta a los súbditos por rasgos propios que lo asemejan a un objeto ideal. Los objetos del conocimiento jurídico son, desde ese punto de vista, finos, precisos y exactos. Para que podamos actuar, nuestro cálculo jurídico tiene que fundarse en datos normativos sólidos y seguros. Esa es la característica del conocimiento dogmático, que se da en el sistema jurídico desde adentro.

e) El conocimiento dogmático no toma en cuenta el principio de la infinitud de lo real. Por eso se diferencia netamente del conocimiento predicativo. Este último será siempre mutable, creciente, perfectible, revisible, objetivo, teórico. El conocimiento dogmático, en cambio, que contempla a su objeto desde adentro y está sometido al mismo movimiento que el objeto, ve a éste como algo quieto, invariable, intemporal. Los enunciados normativos, vistos desde adentro, son preceptos concluyentes, cerrados en sí mismos. Están constituidos exclusivamente por las notas que se consideran suficientes para fundar la consecuencia jurídica. De las normas, así consideradas, no fluye una corriente inagotable de predicaciones posibles. El conocimiento dogmático no responde a la ley derivada de la infinitud de lo real. Lo que aquí interesa conocer es siempre un esquema. Un esquema rígido, completo y seguro de sí mismo.

f) El conocimiento de esos esquemas rígidos, completos y seguros de sí mismos no puede crecer en forma indefinida; tiene topes límites más allá de los cuales se torna inválido. Es un conocimiento *para*; no es un conocimiento en sí, desinteresado, invisible y perfectible.

g) Estas son las características que el derecho exhibe cuando nos referimos al sistema de normas en cuanto componentes de la acción humana y reguladoras de la conducta social. En vez de buscar el derecho en la jurisprudencia debemos buscarlo en su momento vital y dinámico. Precisamente porque estamos

localizados en el plano de la *praxis* existe una correspondencia precisa que supera todas las imperfecciones del lenguaje y que no se da en el plano puramente teórico.

E. Concebir el derecho pensando en el momento de su interpretación por los jueces y señalar además, que las normas jurídicas suelen ser ambiguas y/o vagas, y que poseen necesariamente una textura abierta, es adoptar una posición escéptica ante las reglas. Esta posición no se hace cargo de las características especiales que tienen las palabras de la ley para el conocimiento dogmático.

Ella paga tributo a un nominalismo que se entretiene en juegos verbales que a veces pueden ser ingeniosos pero que siempre son inconducentes. O, más grave aún, ese modo de ver las cosas no es otra cosa que la unión ilegítima del nominalismo con el realismo nihilista, mortal y artero enemigo de la seguridad jurídica, que se complace en exagerar las imperfecciones del lenguaje para alojar en ellas las pretendidas facultades creadoras de los jueces.

F. Distinguir entre casos claros de aplicación de una regla y casos dudosos de aplicación de ella (casos de la zona de penumbra), y sostener, además, que la distinción entre uno y otro tipo de casos no es nítida o tajante, significa negar la distinción inicial y sumir en la penumbra a toda la normatividad. Ello equivale, en definitiva, a la negación del derecho como norma. Otra vez nos damos con el maridaje espurio del nominalismo con el realismo nihilista.

G. Es absolutamente erróneo invocar como motivo escéptico adicional la posible ambigüedad de la fuerza de una expresión dada. Las normas jurídicas jamás pueden ser ambiguas en ese sentido porque su fuerza operativa es una sola: mandar. Transferir al campo de las normas jurídicas las perplejidades o desconciertos que podemos tener frente a la fuerza de una expresión, constituye, en el mejor de los casos, una generalización precipitada. El error de ese enfoque escéptico consiste en querer trasladar a las normas jurídicas las posibles dudas que pueden suscitar enunciados de otro tipo.

Ya hemos visto, en forma resumida, cuáles son las propuestas y cuáles son las objeciones a ellas. En la segunda te procuraré hacer un balance imparcial de unas y otras. Esto no incurriré en balance falso. Si bien me comprenden las generales de la ley, me esforzaré por ser sincero, objetivo y veraz. Remos qué ocurre.

CAPÍTULO III

CONFRONTACION Y BALANCE DE LAS DOS POSICIONES

1. INTRODUCCION

En la parte preliminar anuncié que, siguiendo una vieja y aceptable práctica, iba a comenzar por el principio. Después, tras una especie de obertura, la exposición se desarrolló en dos movimientos. En el primero resumí algunos aspectos salientes de la posición sostenida por mí en *Notas sobre derecho y lenguaje*. En el segundo, resumí algunos aspectos, también salientes, de una posición aparentemente contrapuesta a la anterior, sustentada por el Profesor Sebastián Soler en su libro *Las palabras de la ley*. De aquí en adelante, por razones de comodidad, llamaré "posición A" a la primera (esto es, la que yo sostuve en las conferencias de 1963 y en el ensayo de 1965) y "posición B" a la segunda (esto es, la que sostuvo Soler en su libro de 1969).

La primera parte concluyó con una promesa. Prometí que procuraría hacer un balance imparcial, con ánimo constructivo, de la posición A y de la posición B. Vale decir, una confrontación de ambas, para ver en qué medida la primera resistía los embates de la segunda, si es que los resistía; para examinar si las objeciones hechas obligaban a reformular las tesis objetadas y, en su caso, qué aspectos de estas últimas requerían tal reformulación y hasta dónde la hacían necesaria.

Esto es lo que me proponía hacer ahora. Los lectores podrán decir, al final, si he hecho eso o una cosa distinta.

Recordaré, ante todo, que las posiciones A y B parecían crepar, en forma casi abismal, acerca de un tópico, o familia de tópicos, que los juristas estudian bajo el rótulo "la interpretación de la ley".

Estaba sinceramente dispuesto a transitar por esa forma nigna y beneficiosa de esquizofrenia que consiste en ver las ideas propias con objetividad, para rectificarlas o atenuarlas en función de aquello en que sean erróneas o exageradas. Pero cuando me aproximaba a emprender esa noble y difícil tarea advertí algo en cierto modo paradójico. Advertí que pese a que mis primeras palabras invocaron la arraigada práctica de comenzar por el principio yo había sido infiel a esa práctica; no había comenzado por el principio. Entre las circunstancias que precedieron y en cierto modo condicionaron las conferencias de 1963 y el volumen de 1965 —la posición A— hubo una cosa muy importante que yo había omitido consignar y que es casi indispensable para comprender en sus justos alcances el significado de esa posición: saber, que ella configuraba, en medida importante, una respuesta o intento de crítica a otra posición, que llamaré B', y que esta había sido sostenida poco antes por el mismo Soler en su libro *La interpretación de la ley*³. Ese libro se conoció en Buenos Aires en mayo de 1963. Mis clases, lo reitero, fueron dictadas en junio de ese mismo año.

Exponer la posición A —como lo hice en la primera parte— sin relacionarla con la posición B' (o, mejor dicho, con la inteligencia que en 1963 atribuí a la posición B'), constituyó, sin duda, una forma poco feliz de desarrollar mis argumentos. La mutilación despojó a la posición A del contexto adecuado para comprenderla cabalmente.

Lo que correspondería ahora, en estricto rigor, sería desarrollar en forma resumida la posición B', para hacer más inteligible la posición A e, indirectamente, la posición B. Sin embargo no voy a hacer eso; no voy a desarrollar en forma resumida la posición B' (las cosas que Soler dijo en su libro *La interpretación de la ley* y contra las que reaccioné en las *Notas sobre derecho y lenguaje*). La técnica del *racconto* suele resultar atra-

³ Ediciones Ariel, Barcelona, 1962.

en manos de los cineastas de talento. Usarla aquí sería, en cambio, francamente imperdonable.

2. UNA INTERPRETACION DE "LA INTERPRETACION DE LA LEY"

En vez de hacer una síntesis de la posición B' voy a indicar la médula de lo que creí ver en ella y que me movió a criticarla en la forma en que lo hice. Creí que el autor de *La interpretación de la ley* se había propuesto, primordialmente, decirnos qué es lo que hacen los jueces cuando, teniendo frente a sí una cuestión o una disputa concreta, la deciden por aplicación de reglas generales. Nunca vi bien claro, para ser sincero, si el autor quería explicar qué es lo que realmente hacen los jueces de carne y hueso en tal situación, o bien recomendar lo que deberían hacer para ser buenos jueces. Pero de lo que no dudé entonces fue de esto: que la expresión "la interpretación de la ley" designaba paradigmáticamente, en el contexto del libro que lleva ese título, cierta tarea que los jueces despliegan (o deben desplegar) al dictar una sentencia.

Consideré entonces que, en relación con esa faena, muchas de las descripciones (o quizás prescripciones) contenidas en *La interpretación de la ley* mostraban una manifiesta falta de sensibilidad frente a los numerosos problemas que surgen cuando empleamos palabras generales clasificadoras para identificar como un caso de aplicación de ellas un fenómeno, situación o hecho concreto dado. Esa tarea de reconocer en un fenómeno concreto un caso de aplicación de una regla general cualquiera, está expuesta a las frecuentes pero remediabiles incertidumbres que se originan en la ambigüedad y vaguedad de muchas de las expresiones de los lenguajes naturales, y a la irremediable incertidumbre que nace del hecho de que esos lenguajes tienen una textura abierta.

Tuve la impresión de que el autor de *La interpretación de la ley* no había visto ni vislumbrado esas incertidumbres de origen semántico, tal como otros juristas, ubicados en las antípodas de dicho autor, sólo tienen ojos para ellas. Con apoyo en las ense-

ñanzas de Hart traté de presentar una vía media, libre, a la vez de aquella forma de ceguera y de esta morbosa atracción por lo patológico. Esa vía media, me pareció, reproduce, además, con aceptable fidelidad, lo que de hecho ocurre en toda sociedad medianamente organizada en la que hay reglas y también pleitos.

Ese fue el punto de vista general desde el que concebí la parte crítica desarrollada en el capítulo II de las *Notas sobre derecho y lenguaje*. Es posible que allí haya dicho más de lo que de no haber estado inspirado por un afán polémico, hubiera pensado prudente decir. Por eso estaba dispuesto a rectificarme a conceder todo lo que fuese razonable conceder.

3. ¿FUE CORRECTA ESA INTERPRETACION?

Resulta, empero, que algunos pasajes del libro *Las palabras de la ley* (pasajes que integran la posición B), parecen privar de toda pertinencia a la mayor parte de las cosas sostenidas en la posición A (la de las *Notas sobre derecho y lenguaje*). Esos pasajes parecen transformar el intento de confrontar las posiciones A y B, para sacar alguna enseñanza de esa confrontación en una empresa tan poco sensata como sería la de proponer extraer valor elucidatorio o didáctico de un diálogo entre esos dos.

Veamos esto más de cerca, con citas concretas. En las páginas 166/167 de *Las palabras de la ley* se dice textualmente:

"Dejemos de lado, sin embargo, la consideración del valor de lo que los realistas han creado sobre tales bases, para ocuparnos ahora de examinar especialmente las críticas al lenguaje legal, tema que les proporciona la base y punto de partida para su construcción. Eso sí, recordaremos una vez más que entendemos siempre referirnos a las palabras de la ley, de la ley misma. Para evitar equívocos, no pensemos leerlas como las lee el juez para dictar una sentencia. Más bien supondremos que éste las leerá como nosotros, como los habitantes de una polis, para la cual esas palabras constituyen el derecho positivo. Desde esta posición mediremos las afirmaciones escépticas y trataremos de discernir su verdad o su error

y las consecuencias que de ellas se derivan. En una palabra, una vez más veremos al derecho antes de su transgresión y en su relación con la acción humana. Lo que dirá el juez después, o lo que deberá decir, es tema separado".

Ese pasaje corrobora, como en él se expresa, lo dicho en otros de la misma obra. Así, por ejemplo, en la página 56 se lee que "hay otro tipo de enunciados que solamente son comprensibles bajo el supuesto de concebir el derecho como derecho judicial, pensando en el momento de su interpretación por parte de los jueces. Nos parece típica en tal sentido la exaltación de la vaguedad o equivocidad de los textos legales como un valor..." (La bastardilla es mía).

La posición A se había apoyado, en medida importante, en la crítica a ciertos puntos de vista por considerar que ellos constituían, por lo menos, una inadecuada descripción de lo que hacen los jueces cuando identifican un caso concreto individual como incluido en el campo de aplicación de una regla o de un conjunto de ellas. Ahora bien, si los puntos de vista criticados por esa posición no pretenden referirse a lo que hacen los jueces cuando fallan, sino a otra cosa, entonces aquélla no merece ser tenida siquiera en cuenta.

La posición A parece quedar en una situación bastante desairada, por no decir ridícula. ¿Qué hacer? Estoy dispuesto, como dije, a incursionar en una forma benigna de esquizofrenia, pero no a entregarme a prácticas masoquistas. Por ello creo necesario decir algo en favor de la posición A, como excusa, o quizás como justificación, por haberla sustentado. A tales fines me parece justo señalar que si yo entendí mal al autor del libro *La interpretación de la ley*, este libro favoreció la desinteligencia y lo hizo en una medida tal que, en todo caso, habría una manifiesta culpa concurrente.

Podría multiplicar las transcripciones de distintos pasajes del libro *La interpretación de la ley* que sustentan con holgura la teoría de la culpa concurrente. Pero ya que como muestra hasta un botón, me voy a limitar a hacer una sola transcripción, desusadamente larga, pero que considero necesaria. Los pasajes transcriptos arrancan en la página 72 del libro y forman parte

del capítulo VIII, que se llama "Imposibilidad de eliminar el proceso de interpretación".

"Supongamos una norma que diga: se aplicará prisión de un mes a seis años al que defraude a alguien mediante ardid. Con el planteamiento a que nos venimos refiriendo, pareciera que el proceso interpretativo consistiera solamente en la acción concreta del juez, el cual, frente a una determinada estafa, crea la pena que impone a un sujeto, entre un mes y seis años: creación dentro del marco legal.

"Es evidente, sin embargo, que la consideración de este aspecto de la actividad del juez no significa apreciar completamente la acción que ese órgano cumple. Desde luego que es un problema el de elegir entre un mes y seis años, y que en él la voluntad del juez se mueve con bastante amplitud, aunque cuando ésta no sea tanta como algunos teóricos parecen inclinados a creer, pues la determinación de una pena concreta dentro de un sistema de escalas penales está, a su vez, regulada en gran medida por otras normas distintas de las que hemos tomado como ejemplo, normas contenidas en todos los sistemas de derecho positivo y que constituyen otros tantos marcos a los cuales el órgano debe ajustar su acción.

"Hemos elegido deliberadamente ese ejemplo, sin embargo, por otro motivo, y es éste: en la referida norma hay un elemento cuantitativo que se presta dócilmente a la imagen del marco; pero que se presta igualmente para ocultar la parte de la norma que plantea propiamente la tarea de la interpretación. La doctrina que estamos examinando procede aquí con una especie de escamoteo, al transformar el tema de la interpretación como tema de libre arbitrio judicial, y ahí reside el error.

"En el caso referido, además de la tarea de escoger entre un mes y seis años, está el de saber, comprender o entender el significado de 'defraudar' y de 'ardid', porque con respecto a esos elementos de la ley es absolutamente claro que no es cierto que será *defraudar* y será *ardid* lo que los jueces digan efectivamente que lo es. No es un problema de elección libre de invento. Acaso sea exacto en algunos casos seguir hablando de un marco, pero nos inclinamos a creer que no; que esos conceptos más bien responden a la idea del sí o no, estos compuestos por un conjunto de notas que se dan o no se dan, y, en consecuencia, son o no son. La idea de marco dentro del cual nos movemos libremente no parece convenir en absoluto para definir la actividad desarrollada en este punto por

el juez; parece convenir más bien la idea de umbral; lo importante no es lo que haremos una vez que estemos adentro de la casa; lo importante es decidir si entramos o no entramos: estamos frente a un dilema. En el caso recordado, pues, no negaremos que sea un problema el de escoger una pena correcta entre un mes y seis años y no dudamos también que en esta tarea de aplicación el juez cumple una función específica en la cual dispone, a veces, de verdaderos marcos, más o menos amplios. Nos parece dudoso, sin embargo, que a esa actividad se la llame 'interpretación' y, en todo caso, negamos que esa sea la totalidad de la tarea del juez y que ella constituya el tipo de la actividad cumplida por él, es decir, que esa operación de determinar la pena sea exactamente igual a la de determinar si existe o no existe defraudación. Esta es la determinación que la doctrina examinada parece inclinada a no considerar en sus caracteres específicos...".

"Si bien es exacto que a veces la ley deja librada al órgano de aplicación la elección entre varias posibilidades conceptuales previstas o no expresamente, es también cierto que al tomar ese aspecto del proceso de interpretación como el único, se descuida que aun en ese supuesto el órgano inferior debería asumir una doble tarea: 1º determinar cuál es el margen de facultades; 2º escoger dentro del margen determinado. La primera determinación no solamente reaparecerá en cada supuesto que pongamos, sino que por poco que nos detengamos a considerar el tema, deberemos lealmente reconocer que constituye por excelencia el cuerpo de toda resolución judicial. Aunque el juez no diga expresamente que está interpretando la ley, es decir, entendiéndola y aplicándola de determinada manera, es lo cierto que eso constituye, cuando menos, la mitad de su tarea. La otra mitad consiste en la fijación e interpretación de los hechos, operación también penetrada de conceptos jurídicos, porque todo hecho procesal es un hecho jurídicamente calificado.

"La posición que estamos examinando, acaso movida por un espíritu realista, de hecho se ha alejado de la realidad de manera profunda. Basta pensar en lo que es ordinariamente un pleito para convencerse de la incorrección de aquel planteamiento. Basta abrir un repertorio de jurisprudencia... Lo que se discute siempre es si algo constituye o no un contrato, si un acto es nulo o no, si una obligación subsiste o está prescrita, si un sujeto es capaz o incapaz, si un hecho es o no un delito, si un término procesal está o no vencido, si un crédito debe ser pagado antes o después de otro. Y ese debate,

que es un verdadero debate y no una conferencia, asume por esencia forma dialéctica, es decir de afirmación y negación contrapuestas, resultando la contraposición de las formas discrepantes de fundarse en el precepto jurídico.

"Y ahí tenemos el problema planteado ante el juez. La imagen del marco (creación dentro del marco normativo) debe ser directamente desechada como descripción adecuada de la tarea del juez, porque lo que éste debe hacer, lo que de él se espera, no es que cree nada, sino que decida, que se pronuncie a favor de una u otra pretensión, que escoja determinado marco y no otro".

4. INTENTO DE CONCILIACION

Ahora bien, admitamos provisionalmente que para apreciar las características del lenguaje de las reglas jurídicas hay que abandonar el punto de vista del juez en trance de dictar sentencia, tal como lo preconiza la posición B. Surge entonces, en forma casi inevitable, esta pregunta: ¿por cuál habremos de sustituirlo?

Una manera posible de contestarla, que halla sustento en la equivocidad de la expresión "la interpretación de la ley", sería decir que el punto de vista adecuado es el del jurista dogmático que, con pretensión científica, organiza y expone en la forma de un sistema coherente el contenido de las normas de un orden positivo dado o, más plausiblemente, de sectores de él de varias dimensiones.

Tal respuesta daría pie, por ejemplo, a estas dos aserciones prometedoras: 1) que desde el punto de vista de la ciencia dogmática del derecho el concepto de compraventa es absolutamente rígido y fijo, pues está constituido por tres notas y nada más que por ellas: acuerdo para transferir el dominio; cosa cuyo dominio se transfiere por virtud de ese acuerdo; y precio; y 2) que, por lo tanto, ninguna de las tribulaciones por las que tienen que pasar los jueces para decidir si una transacción concreta es o no una compraventa, afecta la fijeza y rigidez del concepto, ni su carácter de esquema abstracto, cerrado en sí mismo.

La ambigüedad y vaguedad de muchas de las expresiones de los lenguajes naturales, y la textura abierta de éstos, sólo ten-

drían relevancia al nivel de la faena judicial. Esto es, cuando los jueces tienen que preguntarse ¿es este X concreto un individuo comprendido por el significado de la regla 1? y dar una respuesta fundada a esa pregunta o a preguntas similares. Pero esas características de los lenguajes naturales no introducirían incertidumbre alguna en la tarea de los tratadistas o expositores dogmáticos de un derecho dado, porque ellos, a diferencia de los jueces, no tienen que clasificar individuos concretos sobre la base de criterios generales de clasificación, sino simplemente decirnos, en forma sistemática, libre de incongruencia y de superposiciones, cuáles son esos criterios.

Si esa fuera la salida, resultaría que la posición A no sería incompatible con una posición que viera el paradigma de "la interpretación de la ley" en lo que hacen los juristas dogmáticos. Ambas posiciones serían compatibles, porque la primera tomaría las cosas donde la segunda las deja. Una y otra serían verdaderas y útiles en sus respectivos campos.

5. FRACASO DEL INTENTO DE CONCILIACION

Infelizmente en nuestro caso, donde se trata de comparar constructivamente las posiciones A y B, no podemos resolver el diferendo existente entre ambas mediante una sencilla operación de deslinde y amojonamiento, seguida de un tratado que obligase a los contendores de ayer, hoy reconciliados, a respetar los límites establecidos. Esos límites deslindarían dos campos distintos. En uno reinaría la posición B y en el otro la A, y los respectivos reinados serían indisputables.

Para ver por qué no está a nuestro alcance una solución tan sencilla, tan agradable, tan civilizada, hay que tomar en cuenta algunas cosas, que expondré en forma resumida.

A. La posición B se rehúsa a adoptar el punto de vista del juez en trance de dictar sentencia. Pero no lo desecha para sustituirlo por el de los juristas dogmáticos. Lo descarta para reemplazarlo por el de los hombres corrientes, los miembros de la *polis* para los que las normas de cuya interpretación se trata son derecho positivo.

Se afirma, además, que para el súbdito, que ve el derecho desde adentro, éste posee rasgos que lo asemejan a un objeto ideal. Los objetos del conocimiento jurídico son, desde ese punto de vista, fijos, precisos y exactos. Para poder actuar, los hombres corrientes necesitamos que nuestro cálculo jurídico se funde en datos normativos sólidos, seguros. Los enunciados normativos vistos por el hombre corriente desde el interior del sistema, son preceptos conclusivos, cerrados en sí mismos. El objeto por conocer es quieto, invariable, intemporal. Lo que interesa conocer para poder actuar, son esquemas rígidos, completos y seguros de sí mismos.

B. Ese hombre corriente o miembro de la *polis*, que ve el derecho así, con aquellos rasgos de fijeza y rigidez que convierten en hueco parloteo a todas las observaciones sobre la ambigüedad, vaguedad y textura abierta de los lenguajes naturales, ese ciudadano común cuya mirada da fijeza y rigidez absolutas al contenido de las reglas, porque si no las viera así no podría actuar, ese arquetipo o paradigma del sujeto cognoscente del derecho es, lo digo sin vacilaciones, un personaje mítico. Una suerte de Superman jurídico, sembrador infatigable de precisiones y claridades.

Permítaseme agregar que si los hombres comunes vieran el contenido de las reglas jurídicas con la claridad y precisión con que las ve ese personaje mítico, estaríamos de más los abogados. Quizás haya buenas razones para recomendar una rápida y radical eliminación de nuestro gremio pero, sin duda, *esa* no es una de ellas.

C. El ciudadano corriente que tiene que tomar una decisión concreta en la que esté involucrada la interpretación de normas jurídicas —y no deseo cuestionar la afirmación de que prácticamente no hay decisión humana en la que de un modo u otro no esté de por medio una o más reglas de derecho— ese ciudadano corriente, digo, se encuentra en una situación semejante a la del juez que tiene que decidir un pleito o una causa aplicando normas generales. Frente a una mayoría de casos el ciudadano común sabrá a qué atenerse en ese respecto, esto es, sabrá cómo la decisión concreta que contempla se inserta en el orden jurídico

o qué sentido recibe de éste. No tiene necesidad de consultar a un abogado para saber si puede o no válidamente comprar un paquete de cigarrillos o regalarle un tapado a su mujer. Y si se lleva mal con ésta, al punto de que la vida en común con ella le resulta intolerable, el ciudadano común sabe, sin necesidad de consultar a un abogado, que no está facultado para matarla. Esos son casos claros. Pero si la decisión a tomar tiene ingredientes más complejos y se trata, por ejemplo, de saber si es o no constitutivo de monopolio un determinado contrato que la sociedad anónima que nuestro imaginario ciudadano común preside proyecta celebrar con otra sociedad, es muy probable que nuestro ciudadano tenga enormes dudas sobre el particular y que se decida a consultar a un abogado, cuyas dudas serán quizás mayores. Ni el ciudadano común ni el abogado ven a las figuras diseñadas por la ley represiva de los monopolios como esquemas rígidos, precisos, fijos, cerrados en sí mismos, etcétera. Las ven como lo que son, como caracterizaciones que si bien permiten reconocer con facilidad los casos concretos típicos, están circundadas por una considerable zona de penumbra en la que tendrán cabida los casos concretos dudosos, frente a los que decir tajantemente "sí" o "no" puede constituir una muestra de admirable aplomo, pero también de ignorancia o de irresponsabilidad, o de ambas cosas a la vez.

Con otros términos, la situación del hombre corriente que se ve en la necesidad de tomar una decisión concreta, y que tiene que saber, para adoptarla, cuál es el significado que las reglas generales del sistema acuerdan a lo que proyecta hacer, se asemeja mucho a la del juez. A veces la acción proyectada queda comprendida en el área central de significado de una regla o de un conjunto de ellas; a veces no, y si ocurre lo último el hombre común duda y su duda es razonable. Si consulta a un abogado consciente puede ser que éste le resuelva el problema en un santiamén, pero también puede ocurrir que le pida unos días para estudiar el problema. Esto es lo que nos enseña la experiencia de todos los días.

D. Tanto el hombre corriente como el juez se encuentran con alguna frecuencia frente a casos dudosos, ubicados en la zona

de penumbra. Esto es así porque no es verdad que el derecho elimina todas las posibles áreas de indeterminación mediante cinco procedimientos que resumí en la segunda mitad de la primera parte. Examinémoslos brevemente uno a uno. Se denominaban "Operatividad", "Definición", "Cuantificación", "Tipificación" y "Constitución".

a) *Operatividad*. La posición B sostiene, según dijimos, la incorporación de un modo expresivo a la estructura de la norma jurídica hace que esa expresión adquiera un inequívoco sentido dispositivo. Ella transforma en expresión técnica — afirma — a la más común de las palabras. Además, la ley narra, ni aconseja ni se burla: manda y entiende mandar una cosa precisa. Cuando la ley emplea una expresión, ésta tiene un significado preciso y dispositivo.

Este primer fenómeno no surte, ciertamente, todos los efectos que se le atribuyen. Aunque fuera exacto que las leyes hacen otra cosa que mandar, es innegable que puede haber órdenes confusos, ambiguos, vagos e imprecisos. Del hecho de que algo sea una orden no se sigue que ese algo tiene un significado preciso. "¡No te demores demasiado!" y "¡Quedate aquí!" pueden ser órdenes, no obstante su manifiesta falta de precisión, si las expresiones son proferidas por las personas adecuadas, a las personas adecuadas y en el contexto adecuado.

Además las leyes no sólo mandan, es decir no sólo crean deberes mediante órdenes y prohibiciones. También confiere derechos, autorizaciones, permisos precarios, privilegios, exenciones, inmunidades, etcétera. Otras veces imponen cargas o condiciones que no son deberes. En circunstancias dadas puede constituir un problema arduo determinar con precisión cuál de las cosas ha hecho la ley, problema que algo tiene que ver, si no me engaño, con la "fuerza" específica del enunciado normativo. Pero no es esa la objeción principal. La objeción principal a la posición B, en este respecto, es que no es cierto que la mera incorporación de una palabra o expresión en el texto de una norma jurídica convierte a esa palabra o expresión en técnica y precisa.

El ejemplo que trae *Las palabras de la ley* en la parte final de la página 171 y a comienzos de la 172 es suficientemente

ilustrativo de una situación opuesta a la que se pretende ejemplificar con él. Transcribo: "En el derecho argentino se puede probar, por ejemplo, que la expresión 'bajo la influencia de la fiebre puerperal' a la que los médicos tienden a acordar, explicable, pero ingenuamente, un sentido médico, quiere técnicamente decir más o menos 'algún tiempo no muy largo'...".

Dudo que esta última expresión sea técnica, pero ciertamente no es precisa.

b) *Definición*. Ya vimos que la posición B sostiene que cuando la ley habla, siempre acota, limita, define, porque la ley no puede mandar y prohibir la misma cosa simultáneamente. El principio normativo de no contradicción — dice la posición B — lima las asperezas de las palabras comunes. Las pulen, limpia y decora siempre a su gusto y voluntad.

Para mostrar con fuerza de convicción que no siempre que la ley habla hace todo eso, bastan algunos contraejemplos tomados de las recientes modificaciones introducidas al Código Civil argentino. Igual resultado se obtendría examinando algunas de las recientes reformas hechas al Código Penal.

—Así, el art. 152 bis, inc. 2º del Cód. Civ., establece que podrá inhabilitarse judicialmente a los "disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el art. 141 de este Código, el Juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio".

—El nuevo art. 954, 2º párrafo del Cód. Civ. dispone que "también podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en casos de notable desproporción de las prestaciones".

—El nuevo art. 1071 del mismo código reza: "El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contrarie los fines que aquélla tuvo en mira al reco-

nocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena moral y las buenas costumbres".

—El nuevo art. 1198, 2º párrafo del Cód. Civ. expresa "en los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato".

Pues bien, frente a estas nuevas disposiciones podemos preguntarnos qué grado de precisión ha añadido a las palabras expresiones claves que figuran en ellas el "hecho político" de inserción en un texto legislativo. Esto es, cuál es el territorio que esas expresiones ahora acotan, limitan y definen, de modo de eliminar los casos concretos dudosos.

La pregunta tiene una respuesta sencilla. Obviamente ninguna de esas expresiones delimita o acota un territorio preciso cuya clara delineación permita contestar siempre con un rotundo "sí" o con un rotundo "no" a quien nos interroga si un caso concreto dado está o no incluido en las reglas respectivas. La situación es muy distinta a la que se da cuando alguien nos pregunta si un número cualquiera dado es par o impar. A diferencia de lo que ocurre en este último supuesto, los criterios de aplicación que presiden el uso en concreto de aquellas expresiones a veces no sirven para presentar las cosas en blanco y negro. Hay zonas grises y no puede de menos que ser así. En el campo de enunciados predicativos el principio de no contradicción no contribuye a abolir las vacilaciones que uno puede sentir antes de decidirse a sostener que un individuo dado es o no calvo.

c) *Cuantificación.* Es cierto que en el derecho, como en otros campos normativos —por ejemplo en muchos juegos— utiliza el proceso de cuantificar lo cualitativo para ganar en certeza, al precio, muchas veces, de una buena dosis de arbitrariedad. (¿Por qué una jugada brusca debe ser sancionada con un penalti si se ha cometido cinco centímetros dentro del área, y con

simple tiro libre si, con igual intensidad y mala intención, la falta se hubiera cometido cinco centímetros afuera de ella?). Pero en contra de lo que sostiene la posición B, no todas las palabras cualitativas son cuantificables. Por lo pronto no lo es la palabra "capaz" que en *Las palabras de la ley* se pone como ejemplo. Y no lo es, entre otras razones, porque no lo es la noción de "persona disminuida en sus facultades" que aparece en el ya citado art. 152 bis, inc. 2º del Cód. Civ. y que está en juego cuando se trata de determinar si una persona es o no capaz. ¿Y cómo haríamos para cuantificar la palabra "obsceno"?

d) *Tipificación.* Es cierto que la ley tipifica para regular y que ese procedimiento consiste en crear esquemas abstractos, compuestos por un número finito de notas relevantes. Pero la aserción de que todo lo que la ley no pone como relevante es *eo ipso* indiferente o irrelevante, no pasa de ser un dogma, que puede muy bien ser postulado por un pensador decidido a construir sobre esa base un sistema para su uso personal o para recomendarlo a quienes deseen seguirlo, pero que no se compadece con lo que ocurre en la realidad.

A cada rato vemos que los jueces se rehúsan a incluir un ejemplar concreto en el esquema rígido del tipo porque el ejemplar en cuestión exhibe características especiales, en aspectos concomitantes, que lo hacen atípico, o porque el trasfondo de circunstancias generales sobre las que el caso se proyecta es tan inesperado o insólito que el encasillamiento del caso singular en el tipo, en tales circunstancias, sería una evidente muestra de falta de inteligencia en el intérprete.

¿Por qué no se sanciona como incursos en prevaricato a los camaristas en lo civil que han resuelto que la conformidad expresa de los hijos mayores de edad, que son a la vez los únicos descendientes de un matrimonio, habilita a los integrantes de éste a adoptar un niño, no obstante que la ley de adopción argentina dice que quienes tienen hijos de sangre no pueden adoptar?

¿Y qué opinaríamos de un agente de tránsito que, imperturbable, se ocupara concienzudamente de hacer boletas por circular de contramano a todos los conductores de automóvil que, explicablemente despavoridos, huyesen por la calle Corrientes,

en dirección al Once, ante una sorpresiva invasión de broncosaurios que avanzaran implacablemente por esa arteria desde río?

La concesión que la posición B expresa cuando admite la posibilidad de que las "palabras de la ley" recojan un término cotidiano o vulgar, "con orla y todo", no se hace cargo adecuadamente del problema. Esa concesión, que conduce a afirmar con cierto aire de paradoja, que en esos casos la ley ha querido ser precisamente imprecisa, pone límites artificiales a la zona de imprecisión sin advertir que ésta se caracteriza por la ausencia de límites definidos. Con otros términos, cuando "las palabras de la ley" recogen un vocablo circundado por una zona de penumbra, lo problemático es cómo clasificar los casos dudosos: eso no puede describirse adecuadamente diciendo que la ley ha deliberadamente imprecisa en cuanto acepta como válidos todos los matices que caben en la zona de penumbra, porque ello equivaldría a pretender delimitar esta zona con precisión, lo que es imposible. Si fuera posible, no cabría hablar de zona de penumbra, sino de una simple ampliación del concepto, que quedaría tan delimitado como antes, sólo que ahora con un mayor radio de acción.

e) *Constitución*. Es cierto que el lenguaje del derecho es un lenguaje integrado, parcialmente, con palabras inventadas o constituidas por él, que no corresponden a términos del lenguaje vulgar, pero importan haber adjudicado a éstos un sentido radicalmente distinto. Admitamos que la palabra "compraventa" —o el concepto que ella expresa— es una de esas palabras inventadas. Admitamos también que sus notas son tres y sólo tres: consentimiento, cosa y precio. No obstante ello la clasificación de una transacción concreta como un caso concreto de compraventa puede dar origen a dudas, porque las palabras con que esas notas se definen rematan necesariamente en términos dotados de textura abierta.

Supongamos que el Jardín Zoológico de Buenos Aires quiere de un explorador un curioso espécimen de figura simio que durante las primeras semanas de cautiverio se comporte como sus congéneres. Con el transcurso del tiempo el primate va mostrando una admirable capacidad de imitación. La ad-

misión llega al colmo cuando se comprueba que, aunque en forma rudimentaria, ha aprendido a imitar el habla de los empleados que limpian su cubículo. El simio no sólo repite lo que sus cuidadores habitualmente dicen, sino que comienza a armar frases por su cuenta, la mayor parte de ellas incomprensibles o incoherentes, pero otras dotadas de sentido. Claro está que su dicción dista mucho de ser impecable; es una media lengua contaminada de gruñidos aunque en muchos aspectos se asemeja al habla humana. Su temática es monacorde pero en lo que le interesa consigue darse a entender. Sus modales siguen siendo zafios; difícilmente sería aceptado como socio por el Círculo de Armas. Con todo, es posible mantener una conversación con él sobre aspectos muy elementales del mundo que lo rodea. Así, por ejemplo, no expresa convicciones políticas pero suele tener duras palabras de crítica para la comida que se le suministra.

Enterado de todas estas sorprendentes novedades el explorador que vendió el simio pide la nulidad de la venta, alegando que lo vendido no fue una cosa sino un ejemplar de hombre primitivo. Al mismo tiempo, y sobre la base de consideraciones similares, un abogado de esta capital, que se ha hecho merecidamente famoso por su activa defensa de los derechos humanos, interpone un *habeas corpus* en favor del extraño cautivo.

¿En qué medida el juez que debe pronunciarse sobre la validez o nulidad de la compraventa es inmune a los peligros y asechanzas de las palabras comunes por el hecho de que el término "compraventa" es una palabra de factura jurídica, construida al modo como los geómetras construyen sus objetos, si su problema depende de decidir si el ser animado objeto de la transacción es un mono que habla o un hombre primitivo? ¿En qué medida el juez que tiene que pronunciarse en el *habeas corpus* se ve libre de aquellos mismos peligros por el hecho de que la expresión *habeas corpus* también es de factura jurídica, si su problema central es determinar si el beneficiario del recurso es o no un hombre?

Por otra parte, si alguien sostiene que la clasificación de una transacción concreta como "compraventa" o "donación encubierta" depende de la proporción o desproporción que exista entre el valor intrínseco de la cosa y el de la cantidad de dinero

que se da a cambio de ella, y que esa clasificación puede ser dudosa e incierta, el que sostenga eso no quedará satisfecho con la respuesta de que no puede haber problema alguno porque el precio es falso o no, y si ocurre lo primero hay donación mientras que si ocurre lo segundo hay compraventa. No quedará satisfecho porque aunque enriquezcamos nuestro arsenal de conceptos con el concepto de "falso precio" siempre quedará subsistente frente a un caso concreto, la posibilidad de que haya dudas razonables acerca de si éste debe o no ser clasificado como un caso de "falso precio". El concepto de "falso precio" carece de límites precisos y definidos en lo que concierne a su aplicación a los casos concretos, tal como carece de límites semejantes el concepto de "hombre de edad madura", que podría quizás invocarse para pretender eliminar la vaguedad de "joven" y "viejo". Esa técnica reduce la vaguedad pero no la elimina. El concepto "falso precio" introduce su propia zona de penumbra, y la posible determinación subsiste, quizás atenuada. Elló no impide, por cierto, que en la realidad se den muchos casos frente a los cuales no haya dudas de que el precio es falso.

6. ALGUNAS CONCLUSIONES

A esta altura de la exposición podemos hacer las observaciones siguientes:

Primero. La posición A, correctamente reformulada, o liberada de las exageraciones con que, quizás, fue originariamente expuesta, no es incompatible con una disciplina como la dogmática jurídica, que expone y caracteriza a los conceptos jurídicos como compuestos por una cantidad finita de notas precisamente indicadas.

Segundo. La posición A, en cambio, con su formulación primitiva o con su reformulación más cuidadosa, es incompatible con una posición que niega la existencia de dudas justificadas en la aplicación de reglas generales a algunos casos concretos o en la clasificación de estos casos concretos bajo reglas generales, o que esa tarea de clasificación la ejerza un juez al resolver

pleito o una causa, sea que la ejerza un particular para determinar en concreto qué curso de conducta seguir, o aconsejar a un tercero que siga.

Tercero. Por lo tanto, la posición A no es compatible con la posición B, en la medida en que ésta niega la existencia de casos de la penumbra cuando se trata de determinar si un caso concreto es o no un ejemplar de una regla general. La posición A, reformulada y liberada de exageraciones polémicas, es preferible a la posición B porque hace más justicia a los hechos y tiene mayor poder explicativo. Lo tiene porque ayuda a entender una cantidad de fenómenos de la experiencia cotidiana del derecho que, en caso de adoptarse la posición B, quedarían como aberraciones inexplicables e incluso inconcebibles (votos en disidencia, sentencias revocatorias, dictámenes fiscales no coincidentes con los fallos, cambios de jurisprudencia, discrepancias de buena fe entre litigantes que no concuerdan en la forma de calificar hechos sobre cuya ocurrencia coinciden, etcétera).

Cuarto. La posición A, que reconoce abiertamente la fundamental importancia que tienen las reglas en toda sociedad organizada, y que limita la incertidumbre a los casos que se presentan en la zona periférica de las reglas, no puede ser considerada una posición de escepticismo frente a éstas. El cargo es manifestamente inmerecido.

No hay puntos de contacto fundamentales entre la posición A y el realismo nihilista. Sólo los une tener un enemigo común: la posición B y sus congéneres.

Quinto. La posición A afirma que entre los casos concretos claros y los casos concretos dudosos (casos de la penumbra) no hay una distinción nítida y tajante, porque esa distinción depende de la noción de zona de penumbra, que es vaga. La posición B objeta que eso significa negar la distinción inicial y sumir en la penumbra a toda la normatividad. Tal reproche es equivalente a este otro y tiene la misma —escasa— fuerza de convicción: si alguien afirma que en una habitación hay un foco de luz que gradualmente va transformándose en penumbra, sin que pueda decirse con precisión dónde concluye la luz y dónde empieza la penumbra, la persona que afirma eso está negando la

distinción entre zona de luz y zona de penumbra y está sumado en penumbra toda la habitación.

Sexto. La posición A no ha introducido ningún factor adicional de escepticismo frente a las reglas al destacar las distintas "fuerzas" que pueden tener las expresiones lingüísticas. La posición A no ha dicho nada al respecto, aunque, como suena más arriba, quizás pudo y debió haberlo dicho.

7. FINAL

Terminaré con dos últimas observaciones de un tipo distinto a las anteriores.

En primer lugar, considero de estricta justicia decir que no habría advertido ciertas extralimitaciones en que incurri mis *Notas sobre derecho y lenguaje*, si no me las hubieran señalado, con amable insistencia, mis amigos Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin. Agradezco a ambos su amabilidad y también su insistencia.

En segundo lugar, espero que nada de lo que he sostenido en este ensayo sea interpretado como expresión o indicio de una actitud desconsiderada frente a las ideas que he criticado ni frente a quien las ha expuesto con extraordinario brillo. Constituye un alto honor para mí polemizar en un tono de cordial discordancia con quien es, sin duda, uno de los más destacados juristas de nuestra lengua.

III SOBRE EL CONCEPTO DE DEBER JURIDICO